課程名稱：刑法09

00:00:01 - 00:00:03
那個,今天戴墨鏡上課,

00:00:03 - 00:00:06
因為禮拜三我去做那個眼袋內開的手術,

00:00:06 - 00:00:08
到今天為止那個眼睛還是腫的,

00:00:09 - 00:00:11
左眼的結膜出血,

00:00:11 - 00:00:14
那個眼鏡拿下來會有點恐怖,好像血輪眼一樣

00:00:14 - 00:00:16
所以今天就先戴墨鏡上課

00:00:17 - 00:00:18
cosplay黃猿這樣

00:00:18 - 00:00:22
那個，昨天我有問班內，說可不可以停課

00:00:22 - 00:00:25
我覺得這樣上課有點狼狽，但是

00:00:25 - 00:00:32
同事跟我說停課比較麻煩啦，因為日後要補課的話，可能教室時間不好喬什麼的

00:00:32 - 00:00:34
我想說，算了，反正今天身心狀況應該還可以，

00:00:35 - 00:00:36
所以就，就這樣上課，

00:00:37 - 00:00:41
所以這個，戴眼鏡是為了怕嚇到大家啦，

00:00:41 - 00:00:44
因為我這邊還貼膠帶啊什麼的，今天傍晚才要去拆掉，

00:00:45 - 00:00:47
所以希望下個禮拜就恢復正常了。

00:00:47 - 00:00:49
禮拜三當天，真的好可怕。

00:00:50 - 00:00:52
這個，我沒有做全身麻醉，

00:00:52 - 00:00:54
就是在處理那個眼袋的時候只有局部麻醉，

00:00:55 - 00:00:56
就感覺眼在那邊被拉扯，

00:00:56 - 00:00:59
這個，以後應該不會有這樣的經驗了。

00:00:59 - 00:01:00
唯一一次，應該是這樣。

00:01:02 - 00:01:04
好，所以今天，對，今天就是，

00:01:05 - 00:01:07
那我就想說苦中作樂一下嘛。

00:01:07 - 00:01:12
啊戴墨鏡上課，我就想說，那我是否要穿一件對應的T-shirt？

00:01:12 - 00:01:15
那我想說，我沒有戴墨鏡的圖啊。

00:01:15 - 00:01:17
對啊，我想說好，那就，那就穿這件。

00:01:18 - 00:01:19
對啊，這有一點像。

00:01:19 - 00:01:23
所以沒辦法了，眼睛腫，眼睛受傷，所以只能戴這個墨鏡來上課。

00:01:24 - 00:01:27
好，我們今天都拿到了這本講義了吧？

00:01:27 - 00:01:28
都拿到了。

00:01:28 - 00:01:29
好,

00:01:29 - 00:01:31
終於，我們來看一下。

00:01:53 - 00:01:54
好,

00:01:54 - 00:01:59
這一本講義的話，以後上課請同學每一次都要帶到，

00:01:59 - 00:02:00
這一本。

00:02:00 - 00:02:01
每次一定都會用到。

00:02:01 - 00:02:08
裡面我收集的應該是從105到115,總共10年間的國考刑法考題。

00:02:09 - 00:02:11
原則上應該是都有收,

00:02:11 - 00:02:14
除非是有少數的我可能沒有收,

00:02:14 - 00:02:15
比如說那個,

00:02:17 - 00:02:17
那個什麼？

00:02:18 - 00:02:22
有些話，像比如說高考二級，跟你們講一下，

00:02:22 - 00:02:26
高考二級這個考試，它的刑法是有包含到特別刑法，

00:02:27 - 00:02:29
就是有毒品、有貪汙、有槍砲什麼的，

00:02:29 - 00:02:32
高考二級的刑法它有包含到特別刑法。

00:02:32 - 00:02:38
所以，高考二級的有些題目，如果我過濾下來發現它是純粹特別刑法的話，

00:02:39 - 00:02:40
那種我就不會收入。

00:02:40 - 00:02:41
有的是這樣，

00:02:41 - 00:02:43
那有些，應該大部分都有收錄啦，

00:02:43 - 00:02:45
如果沒有的話，可能是我漏掉，但不多啦。

00:02:45 - 00:02:46
應該幾乎都有。

00:02:46 - 00:02:47
來,

00:02:48 - 00:02:52
這一本的話，我當然不可能每一題全部都講，不可能,

00:02:52 - 00:02:53
因為這個題目這麼多,

00:02:54 - 00:02:59
所以我每講到一個段落的時候，我會挑一些重要的題目來講。

00:02:59 - 00:03:02
所以我們就來看一下，有些我們沒有講過的，

00:03:02 - 00:03:04
來，我們就從第一頁開始看。

00:03:45 - 00:03:49
所以我們今天一開始會先花一些時間，補講一些我們前面沒有講到的題目。

00:03:50 - 00:03:54
有些題目啊，前面我可能有口頭帶到，但口頭帶到同學可能都忘記了，

00:03:54 - 00:03:57
所以我們大概再看一下，增加同學的記憶。

00:04:00 - 00:04:07
還用通訊軟體跟他的好友視訊，也藉以洩漏該次的底標，讓乙用最低價得標。

00:04:08 - 00:04:12
那乙就成為這個廠商，因此而獲利數十萬，請問假設犯何罪？

00:04:13 - 00:04:14
來，這題在考什麼知道吧？

00:04:15 - 00:04:17
刑法上公務員的認定，我們記得哦。

00:04:18 - 00:04:24
公立學校的老師，原則上是不是刑法上的公務員？不是，為什麼？因為沒有法定職務權限，對不對？

00:04:25 - 00:04:29
只有在什麼時候有可能呢？在他做政府採購案件的時候。

00:04:29 - 00:04:33
所以各位啊，公立學校的老師他不是刑法上的公務員。

00:04:34 - 00:04:37
但是當他們碰到政府採購案件的時候。

00:04:37 - 00:04:42
他們會變什麼呢？會變成刑法上的授權公務員，他在考這個東西，你知道嗎？

00:04:45 - 00:04:51
所以喔，因為甲是處理政府採購案件的人，所以甲是刑法上的授權公務員。

00:04:51 - 00:04:53
好,那他,那你說他涉及什麼罪？

00:04:53 - 00:04:56
這裡的話兩條我們還沒有學，你先寫沒關係。

00:04:56 - 00:04:57
兩條話。

00:04:58 - 00:05:00
一個是132的洩密。

00:05:00 - 00:05:03
132第一項，洩漏國防以外秘密。

00:05:03 - 00:05:07
再來的話,他讓廠商獲利,那個叫做131的圖利。

00:05:07 - 00:05:08
這兩條知道嗎?

00:05:08 - 00:05:09
132還有131號。

00:05:10 - 00:05:12
洩漏國防以外的秘密,還有圖利罪。

00:05:12 - 00:05:13
涉及這兩條犯罪。

00:05:15 - 00:05:15
好。

00:05:16 - 00:05:18
再來第二題也是一個非常基本的題目。

00:05:18 - 00:05:21
在考你刑法上公務員的認定。

00:05:21 - 00:05:22
我前面就跟同學講過了。

00:05:23 - 00:05:30
涉及刑法上公務員認定的考題，你除了要講說行為人是或不是刑法上的公務員之外。

00:05:30 - 00:05:33
他是哪一種，或者他不是哪一種。

00:05:34 - 00:05:36
這個也請同學務必說清楚，這個都跟同學講過了。

00:05:36 - 00:05:37
好。

00:05:37 - 00:05:39
所以我們來看一下第二題這邊。

00:05:41 - 00:05:47
未經國家考試，而由政府聘僱在戶政事務所的櫃檯辦理戶政業務的人。

00:05:48 - 00:05:49
我們前面講過了。

00:05:49 - 00:05:53
約僱人員有沒有可能成為刑法上的公務員？

00:05:53 - 00:05:54
有，當然有可能。

00:05:54 - 00:05:56
只要他並不是從事機械性的事務。

00:05:57 - 00:05:59
只要他具有法定的職務權限。

00:05:59 - 00:06:00
那他就是刑。

00:06:00 - 00:06:00
刑法上的公務員嘛,所以這一題就是,真題當中的假，雖然是約僱人員沒有錯,可是他在戶政的櫃檯服務,戶政櫃檯做什麼?

00:06:10 - 00:06:14
什麼結婚離婚啊,遷戶籍啊什麼的,都在那個地方嘛,所以他做的事情是純粹的機械式嗎?

00:06:16 - 00:06:17
機械性事務嗎?

00:06:17 - 00:06:18
不是哦,所以他是不是公務員?

00:06:19 - 00:06:22
是，他是哪一種身份，OK嗎？

00:06:22 - 00:06:24
他覺得刑法上的身份是公務員。

00:06:27 - 00:06:34
好，那第二題，民間的拖吊業者跟警察一同出勤做違規停車的拖吊。

00:06:35 - 00:06:37
這個拖吊業者是不是刑法上的公務員？

00:06:38 - 00:06:39
不是。

00:06:39 - 00:06:44
我們講過，民間的拖吊業者，他只是什麼呢？行政助手，他只是一個行政助手，為什麼？

00:06:45 - 00:06:47
因為拖吊業者在執行

00:06:47 - 00:06:50
違規停車的車輛拖吊的時候，

00:06:50 - 00:06:52
業者本身對於哪一臺車要拖，

00:06:52 - 00:06:54
哪一臺車要放，

00:06:54 - 00:06:56
他完全沒有自主判斷的空間。

00:06:57 - 00:06:59
也就是他在作業的時候，要怎麼樣？

00:07:00 - 00:07:02
警察完全要跟在旁邊才可以，對不對？

00:07:02 - 00:07:05
所以他等於就是警察機關的助手而已。

00:07:05 - 00:07:08
所以這個第二小題呢,他當然不是刑法上的公務員。

00:07:10 - 00:07:13
好,接著第四題,我們應該看過來,然後我們往下看。

00:07:18 - 00:07:19
第二頁第八題。

00:07:20 - 00:07:21
來,第二頁第八題,這個我要跟各位說一下。

00:07:22 - 00:07:25
因為這一題我沒有講,你們可能不會寫。

00:07:26 - 00:07:27
這一題喔。

00:07:28 - 00:07:32
你們會發生困難的，不是它實質的內容，而是它的寫作格式。

00:07:33 - 00:07:36
所以我透過這個題目來跟各位講，遇到這種刑法空間效力範圍，

00:07:39 - 00:07:42
然後又同時涉及到論罪的考題，我們應該怎麼來寫？

00:07:44 - 00:07:45
我在黑板上示範一下喔。

00:08:00 - 00:08:00
Hello.

00:10:10 - 00:10:10
好

00:10:10 - 00:10:18
這一題所涉及的一個問題，有一個時間點，要先請同學來做釐清

00:10:18 - 00:10:18
好

00:10:18 - 00:10:19
我們來看這個圖號

00:10:19 - 00:10:28
這三個人在2014年的12月在日本製造了假車禍，後來被日本警方逮捕

00:10:28 - 00:10:31
後來他們在2017年的2月被遣送回臺

00:10:31 - 00:10:31
各位

00:10:31 - 00:10:32
這邊有一個時間點

00:10:32 - 00:10:32
我們要先知道

00:10:32 - 00:10:37
境外犯加重詐欺罪，有我國刑法的適用

00:10:37 - 00:10:38
這個法條在哪裡

00:10:38 - 00:10:40
刑法第五條第十一款

00:10:40 - 00:10:40
各位

00:10:40 - 00:10:41
第五條第十一款

00:10:41 - 00:10:44
並不是一個自古以來就存在的條文，不是喔

00:10:44 - 00:10:49
這個條文是2016年的11月增訂的

00:10:50 - 00:10:52
先記得這個時間點

00:10:52 - 00:10:57
2016年11月是那個時候增訂的

00:10:57 - 00:10:57
當然

00:10:57 - 00:11:00
現在離這個修法已經有一段時間了

00:11:00 - 00:11:01
所以會不會再考這個修法的時點

00:11:01 - 00:11:02
不確定

00:11:02 - 00:11:03
但是這個題目當時考出來很合理

00:11:03 - 00:11:04
因為那個時候剛修法

00:11:05 - 00:11:08
2016年11月才增訂的條文

00:11:08 - 00:11:08
這個

00:12:00 - 00:12:01
那個時候才成立的,所以。

00:12:01 - 00:12:05
是不是三個人的行為,有沒有我國刑法的適用。

00:12:05 - 00:12:07
我教各位,這一題我們要怎麼來寫。

00:12:09 - 00:12:12
這一題的寫法，很多同學會落入一個誤會。

00:12:13 - 00:12:19
很多同學說，我國人在境外犯加重詐欺罪，有我國刑法的適用。

00:12:19 - 00:12:25
那我是不是要先把加重詐欺罪審完，然後才可以看我國刑法的效力範圍？

00:12:25 - 00:12:27
不對，不是這樣判斷的，知道嗎？

00:12:28 - 00:12:29
這個，就好像。

00:12:30 - 00:12:31
我舉個例子。

00:12:32 - 00:12:36
如果我說，那個，我們以誰為例，以陸伯言為例好了。

00:12:36 - 00:12:37
還是以他為例，那誰叫他昨天打電話來問我刑法。

00:12:39 - 00:12:40
剛好想到他嘛，我們就以陸伯言為例，來。

00:12:44 - 00:12:46
假設，那個陸伯言啊，

00:12:46 - 00:12:47
我去告他，

00:12:47 - 00:12:49
說這個陸伯言呢，

00:12:49 - 00:12:52
在管酒的那個諮詢室裡啊，

00:12:52 - 00:12:53
違反我的意願，

00:12:53 - 00:12:55
逼我幫他吹喇叭。

00:12:55 - 00:12:56
假設我去這樣告他。

00:12:56 - 00:13:01
陸伯言在管酒的諮詢室，違反我的意願，逼我幫他。

00:13:01 - 00:13:02
吹喇叭。

00:13:02 - 00:13:02
我去告他。

00:13:03 - 00:13:04
後來他被檢察官起訴了。

00:13:05 - 00:13:09
結果臺北地院審理的結果指出他說。

00:13:09 - 00:13:11
沒有這件事，是我亂告，這樣子。

00:13:12 - 00:13:15
讓你覺得，這時候臺北地院要怎麼判。

00:13:16 - 00:13:19
臺北地院是要判說，被告陸伯言無罪。

00:13:20 - 00:13:26
還是要說因為不存在這一個我所指稱的性侵犯行，所以臺北地院的轄區不是犯罪地。

00:13:26 - 00:13:28
所以本件管轄錯誤，要怎麼判？

00:13:29 - 00:13:30
當然是判無罪吧。

00:13:31 - 00:13:31
對不對，不會判管轄錯誤吧？

00:13:32 - 00:13:34
換句話講，以我們刑訴為例。

00:13:35 - 00:13:37
刑訴那個條文，土地管轄嘛。

00:13:37 - 00:13:40
說什麼犯罪地的法院有管轄權，那個犯罪地是什麼意思？

00:13:41 - 00:13:44
控訴方所聲稱的犯罪地就算，知道嗎？

00:13:44 - 00:13:49
並不是說要最後實體審理，說犯罪這個成立，那個才叫犯罪地，不是，懂我的意思吧？

00:13:50 - 00:13:53
程序法就這樣，先程序後實體嘛。

00:13:53 - 00:13:54
民訴更明顯啊。

00:13:56 - 00:13:59
在民訴上面，我們講說侵權行為地的法院。

00:14:00 - 00:14:01
對本案有管轄權。

00:14:01 - 00:14:02
所以剛剛我講的大概是一樣啊。

00:14:02 - 00:14:04
如果我去告民事，

00:14:04 - 00:14:07
臺北地院的民事庭審完發現根本沒有性侵嘛。

00:14:08 - 00:14:09
所以臺北地院要怎麼辦？

00:14:09 - 00:14:11
是要說那個無管轄權，

00:14:11 - 00:14:12
程序不合法駁回，

00:14:13 - 00:14:15
還是要說原告之訴沒有理由駁回？

00:14:15 - 00:14:16
應該是哪一個？

00:14:16 - 00:14:17
原告之訴無理由,

00:14:17 - 00:14:18
對不對？

00:14:18 - 00:14:18
所以我跟各位講,

00:14:19 - 00:14:20
刑法也是,

00:14:20 - 00:14:22
我們在判斷刑法空間效力範圍的時候,

00:14:23 - 00:14:24
尤其是5678這種條文,

00:14:25 - 00:14:27
因為5678講的是罪名跟刑度,

00:14:27 - 00:14:29
所以同學很容易落入一個誤會是說,

00:14:29 - 00:14:29
啊,

00:14:30 - 00:14:32
所以要成立這些犯罪才有我國刑法的適用喔,

00:14:33 - 00:14:33
不是啦，

00:14:33 - 00:14:34
他不是這樣判斷的，

00:14:34 - 00:14:36
他的判斷方式是假設屬實，

00:14:37 - 00:14:39
假設行為人涉及的是這個犯罪的話，

00:14:40 - 00:14:42
有沒有我國刑法的適用？

00:14:42 - 00:14:43
所以這一件我們要怎麼看？

00:14:44 - 00:14:45
甲乙丙三個人，

00:14:45 - 00:14:48
他在實體上到底有沒有成立339之4，

00:14:48 - 00:14:49
這個不是重點，

00:14:50 - 00:14:54
而是說既然他們這三個人可能涉及刑法339之4的話，

00:14:54 - 00:14:56
那麼本件有沒有我國刑法的適用？

00:14:56 - 00:14:57
有了。

00:14:57 - 00:14:57
知道嗎？

00:14:57 - 00:14:59
所以我們以食物的角度來講，

00:15:00 - 00:15:03
只要檢察官所起訴的法條，

00:15:03 - 00:15:06
是我們刑法5678的條文,

00:15:07 - 00:15:08
那麼法院有沒有審判權?

00:15:08 - 00:15:09
就有,

00:15:09 - 00:15:09
知道嗎?

00:15:09 - 00:15:10
就有啊,

00:15:10 - 00:15:11
那在偵查中也是,

00:15:11 - 00:15:13
在偵查中檢察官要偵辦要起訴嘛,

00:15:14 - 00:15:15
只要在偵查中,

00:15:16 - 00:15:18
指控的這一方所提出來的法條,

00:15:19 - 00:15:20
依照5678,

00:15:20 - 00:15:22
有我國刑法的適用的話，

00:15:22 - 00:15:23
這件案子怎麼樣？

00:15:23 - 00:15:25
就有我國刑法的適用喔，

00:15:25 - 00:15:25
知道嗎？

00:15:25 - 00:15:27
實體上有沒有罪不重要。

00:15:27 - 00:15:27
好,

00:15:28 - 00:15:30
所以這裡我們說甲乙丙三個的人為行為,

00:15:31 - 00:15:33
他可能會有我國刑法的適用,

00:15:34 - 00:15:34
來,

00:15:34 - 00:15:35
那有還是沒有啊?

00:15:35 - 00:15:37
為什麼這一題特別標時間點？

00:15:38 - 00:15:38
好,

00:15:38 - 00:15:39
那我就跟各位說了，

00:15:39 - 00:15:42
一個題目裡面如果特別跟你標時間，

00:15:43 - 00:15:44
不外乎就是兩個原因。

00:15:45 - 00:15:46
要嘛考你修法,

00:15:46 - 00:15:48
要嘛考你時效,

00:15:49 - 00:15:50
刑法幾乎不會考時效,

00:15:51 - 00:15:53
所以刑法的題目出現時間的線索,

00:15:53 - 00:15:55
絕對在考你修法,

00:15:55 - 00:15:55
知道嗎？

00:15:55 - 00:15:56
好,

00:15:56 - 00:15:56
所以這一題喔,

00:15:58 - 00:15:59
依照第五條第11款,

00:16:00 - 00:16:00
好像有我國刑法的適用沒有錯

00:16:00 - 00:16:00
可是看清楚喔

00:16:03 - 00:16:06
他們行為時是2014年12月喔

00:16:06 - 00:16:08
當時五條11款怎麼樣

00:16:08 - 00:16:09
還沒公佈

00:16:10 - 00:16:11
對啊,所以這個是問題啊

00:16:11 - 00:16:17
這種情況之下，我們可以用一個事後追溯的刑法空間效力範圍的條文

00:16:18 - 00:16:24
來讓一個原本行為當下沒有我國刑法適用的行為變成有我國刑法的適用嗎

00:16:25 - 00:16:27
不可以，法律不溯及既往，知道嗎

00:16:27 - 00:16:29
這題就在考這個東西

00:16:29 - 00:16:33
我們的課本上有一個案例，叫做緬甸詐騙案

00:16:33 - 00:16:34
一模一樣

00:16:34 - 00:16:35
就在考這個

00:16:35 - 00:16:38
如果同學你回去複習的話,應該就會有印象,就在涉及這個東西

00:16:38 - 00:16:40
所以這一題呢,我們說啊

00:16:41 - 00:16:44
這三個人的行為沒有我國刑法的適用

00:16:44 - 00:16:47
因為法律呢,不溯及既往的關係

00:16:48 - 00:16:52
所以這裡,就要跟同學講的一件事,這個也是同學很常見的誤會

00:16:52 - 00:16:55
因為我們刑法是規定判斷

00:16:56 - 00:16:59
這種東西的性質有沒有感覺很像程序性的規定

00:16:59 - 00:17:00
因為它是怎麼判斷

00:17:00 - 00:17:01
假設屬實嘛，對不對？

00:17:01 - 00:17:03
很像程序性的規定

00:17:04 - 00:17:05
所以有些人會說

00:17:05 - 00:17:07
可是如果它是程序規定的話

00:17:07 - 00:17:09
不是說程序重啟嗎？

00:17:10 - 00:17:11
像同學有學過刑知道嗎

00:17:12 - 00:17:14
如果一個訴訟進行中，刑住的規定有修

00:17:15 - 00:17:16
那我們法官原則上是怎麼樣

00:17:17 - 00:17:20
用修法後的程序，用修法後的規定來把這個程序結掉，對不對

00:17:20 - 00:17:22
程序原本不是重審嗎

00:17:22 - 00:17:23
所以有些人會想說

00:17:23 - 00:17:27
那刑法5678的規定,它既然很像是程序性的規定的話

00:17:29 - 00:17:30
為什麼不是程序

00:17:30 - 00:17:30
重新

00:17:31 - 00:17:35
所以直接用這個案,這個條文,來讓本案有我國刑法的適用,為什麼不是這樣

00:17:36 - 00:17:37
所以我就說了

00:17:37 - 00:17:40
雖然5678的規定看起來很像程序性的規定

00:17:40 - 00:17:41
很像,沒有錯,可是它有實體法的成分哦

00:17:41 - 00:17:44
為什麼,因為它攸關到我國國家刑法權的空間效力範圍的大小

00:17:45 - 00:17:45
它不是純粹的程序規定

00:17:45 - 00:17:47
懂我的意思吧

00:17:47 - 00:17:49
所以這個東西怎麼樣,不可以說及既往

00:17:49 - 00:17:49
OK哦

00:17:49 - 00:17:50
雖然它判斷的方式

00:17:50 - 00:17:52
很像是程序性規定的判斷

00:18:00 - 00:18:00
可是

00:18:01 - 00:18:05
它的本質依然涉及到國家刑法權效力範圍的大小,

00:18:05 - 00:18:07
所以呢,它不可以溯及既往。

00:18:07 - 00:18:09
好,那退一步來說,我們看到括號二,

00:18:09 - 00:18:11
那甲乙丙三個人的行為,

00:18:11 - 00:18:13
好啦,如果你不講339之4,

00:18:13 - 00:18:16
那從一般的339來講,有沒有我國刑法的適用?

00:18:17 - 00:18:18
當然更沒有,知道嗎?

00:18:18 - 00:18:18
所以本案怎麼樣?

00:18:19 - 00:18:22
本案就是沒有我國刑法的適用,OK?

00:18:22 - 00:18:25
好，那我轉個彎再來提醒同學。

00:18:26 - 00:18:30
那假設這一題他們的行為時不是在2014年12月？

00:18:31 - 00:18:33
假設這一題是2016年12月呢？

00:18:34 - 00:18:36
那本案就有我國刑法的適用啦，對不對？

00:18:37 - 00:18:37
所以你要怎麼寫？

00:18:39 - 00:18:39
各位，

00:18:40 - 00:18:44
假設這一題是2016年12月作為行為時的話，

00:18:44 - 00:18:44
那你要怎麼寫？

00:18:45 - 00:18:46
那麼這一段，

00:18:47 - 00:18:49
這一段，它的位置不變。

00:18:50 - 00:18:53
一樣去做審查，審查完是有OK嘛，對不對？

00:18:53 - 00:18:55
然後第二段你再寫什麼？構成要件。

00:18:56 - 00:18:56
第三段違法。

00:18:57 - 00:18:58
第四段罪責，知道嗎？

00:18:58 - 00:18:59
所以這個東西我們放哪裡？

00:19:00 - 00:19:02
進三階之前，知道嗎？

00:19:02 - 00:19:03
我的重點在這邊。

00:19:03 - 00:19:05
刑法空間效力範圍的判斷，

00:19:06 - 00:19:12
我們一定是在進三階之前，而且是用一種假設屬實的方式去做判斷。

00:19:12 - 00:19:13
這樣瞭解？

00:19:13 - 00:19:15
不要三催四請完再寫它，不要。

00:19:16 - 00:19:23
因為這個我今年什麼時候啊，5月份，五六月那個時候，那個時候我帶警察的奪榜班。

00:19:23 - 00:19:24
我就考一個這樣的題目。

00:19:24 - 00:19:27
結果我想說應該送分吧，這大家都會。

00:19:27 - 00:19:28
結果大家都亂寫。

00:19:28 - 00:19:32
想送分還沒有送到，還打死一堆同學，這是不是我的初衷？

00:19:32 - 00:19:35
所以我想說可能很多同學不會這個東西，所以這邊來跟同學講一下。

00:19:37 - 00:19:39
來，這一題我們就看到這，

00:19:39 - 00:19:42
接著我們往下看。

00:19:45 - 00:19:46
來，第三頁，

00:19:46 - 00:19:47
我們來往下看。

00:19:56 - 00:19:58
第三頁的話，

00:19:59 - 00:20:00
看喔。

00:20:01 - 00:20:03
有些我們講過。

00:20:04 - 00:20:07
像那個第四題啊，雙重具體化錯誤。

00:20:08 - 00:20:09
這些年超愛考。

00:20:09 - 00:20:12
我上次有跟同學講過啊，雙重具體化錯誤超愛考。

00:20:13 - 00:20:14
那個第四題我們大概看一下。

00:20:15 - 00:20:18
用這個題目來順便幫同學複習一下我們之前講過的概念。

00:20:20 - 00:20:24
我們今天是因為第一次拿到題目本，所以有機會在前面幫同學複習一下前幾場課的內容。

00:20:25 - 00:20:26
以後就不會了。

00:20:26 - 00:20:27
所以以後要請同學自己複習喔。

00:20:28 - 00:20:29
有沒有跟同學講過，回去一定要複習。

00:20:30 - 00:20:34
回去如果你沒有複習的話，34堂上完，你又是白紙一張，一定的。

00:20:34 - 00:20:36
相信我，一定要複習喔。

00:20:36 - 00:20:36
好來。

00:20:37 - 00:20:37
那個

00:20:39 - 00:20:40
第四題，牛奶案。

00:20:41 - 00:20:43
在那個牛奶摻入鹽酸，

00:20:43 - 00:20:45
結果讓他的那個，

00:20:45 - 00:20:47
那個那個誰啊，

00:20:47 - 00:20:49
朋友喝了鹽酸牛奶，

00:20:49 - 00:20:51
後來食道灼傷。

00:20:51 - 00:20:54
我們講這種雙重具體化錯誤。

00:20:54 - 00:20:56
照多數說，也就是許老師的看法。

00:20:57 - 00:20:58
怎麼看呢？

00:20:59 - 00:21:04
我們看的是結果作用的方式，有沒有符合行為人對因果鏈的設定。

00:21:05 - 00:21:05
還記得這個關鍵字嗎？

00:21:06 - 00:21:09
結果作用的方式，有沒有符合行為人對因果鏈的設定。

00:21:09 - 00:21:13
所以這一題當中,行為人對因果鏈的設定是什麼呢?

00:21:13 - 00:21:16
喝到牛奶的人,口腔食道會被灼傷。

00:21:17 - 00:21:19
那個意外的訪客是不是也是這樣灼傷的?

00:21:20 - 00:21:20
是嗎?

00:21:20 - 00:21:24
所以我們當作什麼呢?行為人只是搞錯來喝牛奶的人,知道嗎?

00:21:24 - 00:21:27
所以這個題會是什麼錯誤？客體錯誤，OK哦，這個題會是客體錯誤。

00:21:29 - 00:21:31
好，所以這是一個非常典型的考法。

00:21:31 - 00:21:32
來，第五題，我們看一下。

00:22:00 - 00:22:00
而且是很前端的概念。

00:22:02 - 00:22:03
所以以往，一般情況來講，這個東西比較常出現是這種什麼大一的第一次期中考，比較容易考這種東西。

00:22:07 - 00:22:10
國考真的很少出現，結果這題竟然考了。

00:22:11 - 00:22:11
所以我們講喔。

00:22:12 - 00:22:13
這一題當中，

00:22:14 - 00:22:17
你看喔，這兩個人彼此沒有犯一點錯。

00:22:18 - 00:22:20
拆入的毒藥都足以致死。

00:22:21 - 00:22:22
所以這個會變成什麼？

00:22:22 - 00:22:24
條件因果的例外，記得吧？

00:22:25 - 00:22:27
因為如果你照原本條件因果的原型會怎麼樣？

00:22:28 - 00:22:30
會都有，會都沒因果關係啊。

00:22:31 - 00:22:37
所以這一種案例我們會怎麼樣？透過條件因果的例外，來視為他們都有因果關係，記得吧？

00:22:37 - 00:22:39
雙重因果的例外。

00:22:39 - 00:22:40
這一題在考這個東西。

00:22:42 - 00:22:42
好。

00:22:43 - 00:22:45
然後接著我們往後翻。

00:22:54 - 00:22:54
來第八題。

00:22:55 - 00:22:57
第八題是個很棒的題目，我們來看一下。

00:24:08 - 00:24:10
好，我說第八題是一個很棒的題目

00:24:10 - 00:24:12
這題我們到分則，講到那個，竊盜跟侵佔的區分

00:24:15 - 00:24:17
還有講到恐嚇取財的時候，我會再跟各位提這一題

00:24:19 - 00:24:22
這個題當中我們在行走啊，注意幾個點喔

00:24:22 - 00:24:24
來，那個假，偷壓了乙的沐浴乳兩坨

00:24:29 - 00:24:33
然後這個行為可能涉及到竊盜跟侵佔的區分

00:24:33 - 00:24:34
這個我現在沒有要說

00:24:35 - 00:24:36
我要講的是

00:24:36 - 00:24:38
好，不管你認為是竊盜也好，侵佔也罷

00:24:39 - 00:24:41
你覺得這個部分在行走涉及什麼考點

00:24:42 - 00:24:44
我們上個禮拜有講過喔

00:24:45 - 00:24:47
偷壓人家兩坨沐浴乳來洗澡

00:24:48 - 00:24:49
不管你說是竊盜或侵佔

00:24:49 - 00:24:50
這裡涉及什麼東西

00:24:51 - 00:24:52
可罰的違法性啊

00:24:52 - 00:24:53
記得吧

00:24:53 - 00:24:55
沐浴乳兩坨多少錢

00:24:56 - 00:24:56
幾塊錢吧

00:24:56 - 00:24:57
對不對

00:24:57 - 00:24:58
對啊,偷用會怎麼樣

00:25:00 - 00:25:00
而且

00:25:00 - 00:25:01
學這意思吧

00:25:01 - 00:25:04
所以這裡的話涉及到可罰的違法性的欠缺，所以記得喔

00:25:05 - 00:25:06
可罰的違法性，通常展現在這種財產性的犯罪

00:25:10 - 00:25:17
在財產犯罪當中，如果行為人偷的東西、侵佔的東西，顯然是近乎沒有財產價值的

00:25:17 - 00:25:20
這時候我們將去思考，有沒有可罰違法性理論的使用

00:25:20 - 00:25:22
所以這裡要寫的是什麼呢

00:25:22 - 00:25:24
可罰違法性的肯定說跟否定說

00:25:24 - 00:25:24
所以你看

00:25:25 - 00:25:26
這個老觀唸啊

00:25:26 - 00:25:29
現在的考試還是會考啊,三年前的考題而已

00:25:30 - 00:25:30
來

00:25:30 - 00:25:32
接下來喔,後面

00:25:34 - 00:25:35
也要給假教訓

00:25:36 - 00:25:38
在沐浴乳當中摻入鹽酸

00:25:38 - 00:25:40
那怎麼又是鹽酸啊，跟前面那個牛奶那題一樣

00:25:41 - 00:25:42
搞不好是同一個老師出的

00:25:43 - 00:25:44
我相信不是徐安老師

00:25:44 - 00:25:48
真的啦，我是不是跟你們講過，問過徐老師，徐老師說那個都不是他出的

00:25:48 - 00:25:49
我說哪一位老師出的，不知道

00:25:50 - 00:25:51
所以這一題當中的話

00:25:53 - 00:25:54
後面，要摻鹽酸

00:25:55 - 00:25:57
結果鹽酸呢，害另外一個人的手被灼傷

00:25:57 - 00:25:59
又是雙重具體化錯誤，來我跟你講

00:26:00 - 00:26:00
想一次公式

00:26:00 - 00:26:01
通說怎麼看？

00:26:02 - 00:26:04
看結果作用的方式怎麼樣呢？

00:26:04 - 00:26:07
有沒有符合行為人對因果力的設定？

00:26:07 - 00:26:09
所以真題行為人設計的因果力是什麼？

00:26:10 - 00:26:12
來洗澡按壓沐浴乳的人,

00:26:13 - 00:26:15
手會被鹽酸灼傷。

00:26:16 - 00:26:17
這一題當中那個人是不是這樣受傷的?

00:26:18 - 00:26:18
是嗎,

00:26:18 - 00:26:19
所以犯了什麼錯誤?

00:26:20 - 00:26:21
客體錯誤

00:26:21 - 00:26:21
OK嗎？

00:26:21 - 00:26:22
當中客體錯誤。

00:26:25 - 00:26:25
好，

00:26:35 - 00:26:36
接著第五頁13題，

00:26:37 - 00:26:38
110年4624。

00:26:39 - 00:26:41
這一題應該是臺大周樣儀老師的題目啦,

00:26:42 - 00:26:43
應該是他的題目啦,

00:26:44 - 00:26:48
因為從整個命題的風格還有他的問文字用語來講,

00:26:48 - 00:26:50
應該是周老師的題目。

00:26:51 - 00:26:52
好,我們看一部分就好。

00:26:54 - 00:26:54
你看喔,

00:26:55 - 00:27:01
他對仇人的透天厝潑汽油縱火,希望燒死A,

00:27:01 - 00:27:06
而且縱火的時候,他的腦中只有A被烈火焚身而死的想像別無其他。

00:27:06 - 00:27:08
後來啊,這個A被逼到陽臺,

00:27:09 - 00:27:13
面臨火焚的最後一刻，不得已往下跳，頭部著地身亡。

00:27:13 - 00:27:14
好，看到這邊就好。

00:27:15 - 00:27:17
周老師的主觀歸責理論。

00:27:17 - 00:27:19
同學有興趣你們自己去看文章。

00:27:19 - 00:27:21
我這個課不會特別去講，因為這個東西在國考沒那麼好用。

00:27:22 - 00:27:23
我這邊講通說的解法就好。

00:27:24 - 00:27:24
各位，

00:27:25 - 00:27:27
我們處理因果歷程偏離的問題，

00:27:27 - 00:27:28
不外乎就兩個面向。

00:27:29 - 00:27:32
客觀上是什麼呢？客觀規則，尤其是風險實現的問題。

00:27:33 - 00:27:37
主觀上是什麼呢？這一個異常的風險會不會影響行為人的故意？

00:27:37 - 00:27:39
那如果照通說來看這個題怎麼操作？

00:27:40 - 00:27:41
來，客觀上啊,

00:27:42 - 00:27:43
你對人家的房子放火,

00:27:44 - 00:27:46
確實對裡面的人的生命製造了法所不容許的風險。

00:27:47 - 00:27:47
沒有疑問對不對？

00:27:48 - 00:27:51
啊你放火燒別人的房子，結果對方是逃生失敗而死亡，

00:27:52 - 00:27:53
有很反常嗎？

00:27:53 - 00:27:53
還好。

00:27:54 - 00:27:54
對吧？

00:27:54 - 00:27:55
不意外嘛,

00:27:55 - 00:27:55
對啊,

00:27:56 - 00:27:58
這個你想嘛，放火燒別人的房子,

00:27:58 - 00:27:59
那個屋子裡面的人,

00:28:00 - 00:28:02
最後是真的被燒死，這反而是少數吧。

00:28:02 - 00:28:04
很多都是嗆死啊什麼的,對不對?

00:28:04 - 00:28:07
所以逃生失敗而死,不意外啊,這個並不是什麼很罕見的結果啊。

00:28:09 - 00:28:13
所以客觀規則來說,確實怎麼樣,因果力全部反常。

00:28:13 - 00:28:18
當然我強調了,周老師出的題目,周老師他是不喜歡客觀規則理論的,但國考我們不管。

00:28:19 - 00:28:23
國考因為你也不知道是誰出的嘛,我們就通說的體系去回答,知道嗎?

00:28:24 - 00:28:24
好。

00:28:24 - 00:28:27
然後，那那個什麼？

00:28:27 - 00:28:31
接下來的話進到客觀規則第三階層。

00:28:31 - 00:28:33
構成要件效力範圍。

00:28:33 - 00:28:35
整體可不可以說是被害人自我負責？

00:28:36 - 00:28:38
你活該你愛跳啊，自找的啊，可不可以這樣講？

00:28:39 - 00:28:42
不可以，為什麼？他被逼的嘛，對不對，又不是自由的跳下去。

00:28:43 - 00:28:44
所以客觀規則怎麼過？有。

00:28:44 - 00:28:46
那主觀上行為有沒有故意？

00:28:46 - 00:28:47
有。

00:28:47 - 00:28:56
為什麼？因為多數的說法是，故意不需要對構成犯罪事實的每一個細節、每一個動作都有認知，不用。

00:28:56 - 00:29:02
行為人只要對構成犯罪事實的輪廓有一個大致的認知就夠了。

00:29:02 - 00:29:11
所以最後被害人到底是怎麼死的，到底是逃生不及而死，還是被嗆死，還是逃生失敗而死。

00:29:11 - 00:29:13
這個只是細節性的偏差。

00:29:13 - 00:29:13
不影響。

00:29:13 - 00:29:14
故意的判斷。

00:29:14 - 00:29:18
所以並不會因為行為人事實上沒有想到這個結果，而就否定行為人的故意，OK嗎？

00:29:18 - 00:29:20
通說的解法是這樣子喔。

00:29:21 - 00:29:22
所以我跟各位說了。

00:29:22 - 00:29:27
在國考上，你這一段能寫通說寫到這樣，應該六級強的分數你就可以拿到。

00:29:28 - 00:29:34
在國考上面，像周漾老師這種主觀規則理論少數說，那個你當作是額外加分的bonus，知道嗎？

00:29:35 - 00:29:36
你不要反客為主。

00:29:36 - 00:29:39
不要想說把那個東西當主要的，不對，好嗎？

00:29:39 - 00:29:42
那種少數學說是額外加分的項目，你不要就是

00:29:43 - 00:29:46
把那個東西當作你主要的，拿題重點。

00:29:46 - 00:29:48
這不是在考臺大醫學術,OK哦。

00:29:50 - 00:29:50
好。

00:29:58 - 00:29:58
好。

00:29:58 - 00:30:00
接下來我們再往

00:30:00 - 00:30:00
好，看。

00:30:18 - 00:30:22
來構成要件幾個代表性的題目，我們就看到這，因為其他同質性還蠻高的。

00:30:23 - 00:30:24
接下來我們來看到第八頁。

00:30:27 - 00:30:29
好來第八頁，我們來看到違法性的第一題。

00:30:30 - 00:30:32
上上禮拜高普考剛考完的。

00:30:34 - 00:30:39
所以那個題目本會拖到現在才給各位，我就是想給你們看最新的高普考的考題啦。

00:30:40 - 00:30:41
來，第八頁第一題。

00:30:53 - 00:30:57
真題啊，就是我們剛剛講啊，普考法廉，如果你們想看完整版的解答的話。

00:31:00 - 00:31:02
公職王那一份是我解的。

00:31:02 - 00:31:07
今年的高普考，我只負責解那個法廉，就高考法廉還有普考法廉是我解的。

00:31:08 - 00:31:10
法制跟司法行政不是我。

00:31:10 - 00:31:11
誰寫的？

00:31:11 - 00:31:11
我不知道。

00:31:11 - 00:31:12
我沒有特別去看。

00:31:12 - 00:31:14
今年我只負責解法聯。

00:31:14 - 00:31:17
那這一份的話，各位應該看得出來考什麼吧？

00:31:17 - 00:31:19
我記得我應該有口頭跟各位講過這一題，對不對？

00:31:19 - 00:31:21
好像有，上禮拜好像有講過。

00:31:21 - 00:31:22
來，這一題在考什麼？

00:31:23 - 00:31:23
你看喔。

00:31:25 - 00:31:27
那個屁孩快要撞上假的兒子。

00:31:28 - 00:31:30
假可以把A拉開。

00:31:30 - 00:31:33
結果卻把B絆倒。

00:31:34 - 00:31:36
所以啊，B要撞上A，這個是什麼呢？

00:31:36 - 00:31:38
這確實是一個現在不法侵害沒有錯。

00:31:39 - 00:31:40
可是B是什麼人？

00:31:41 - 00:31:43
也是個小孩啊，無責任的力人啊。

00:31:43 - 00:31:44
複習一下喔。

00:31:44 - 00:31:46
對無責任的力人攻擊要怎麼樣？

00:31:46 - 00:31:48
要三階段防衛啊。

00:31:48 - 00:31:50
先試著逃跑，再試著保護。

00:31:50 - 00:31:52
最後不得已才可以攻擊，假如沒有一二三嘛。

00:31:53 - 00:31:56
所以假會怎麼樣？防衛過當，好嗎？

00:31:57 - 00:31:59
這一題當中，照通說的看法，假會防

00:32:00 - 00:32:01
衛過當喔。

00:32:02 - 00:32:02
好。

00:32:02 - 00:32:03
就這麼簡單。

00:32:04 - 00:32:05
接下來，

00:32:06 - 00:32:07
我們再往下看。

00:32:10 - 00:32:10
第四，

00:32:10 - 00:32:11
我不特別講。

00:32:12 - 00:32:13
因為第四題很簡單,

00:32:13 - 00:32:14
第四題就是那個什麼?

00:32:14 - 00:32:15
偶然防衛,

00:32:15 - 00:32:16
偶然防衛,

00:32:16 - 00:32:16
這個非常簡單。

00:32:17 - 00:32:17
然後，

00:32:18 - 00:32:19
我看喔，

00:32:29 - 00:32:31
然後像第10頁的第11題，

00:32:31 - 00:32:33
這一題也是偶然防衛。

00:32:35 - 00:32:35
這一題也是。

00:32:35 - 00:32:37
這也是偶然防衛。

00:32:37 - 00:32:38
然後，

00:32:38 - 00:32:39
我看喔，

00:32:42 - 00:32:43
13題看一下。

00:33:21 - 00:33:22
13題呀，

00:33:23 - 00:33:24
也是挑釁防衛。

00:33:25 - 00:33:26
那是哪一種挑釁？

00:33:27 - 00:33:29
沒事罵人家垃圾廢物，

00:33:30 - 00:33:30
然後對方打他，

00:33:30 - 00:33:31
他在反擊。

00:33:32 - 00:33:33
題目裡面特別講的一句話

00:33:34 - 00:33:34
題目裡面說

00:33:34 - 00:33:37
搶雖非刻意引起攻擊

00:33:38 - 00:33:38
所以這個是什麼？

00:33:39 - 00:33:40
非意圖式

00:33:40 - 00:33:41
知道嗎？

00:33:41 - 00:33:42
這個是非意圖式。

00:33:42 - 00:33:44
所以非意圖式的挑唆防衛,

00:33:44 - 00:33:45
行為人要123,

00:33:46 - 00:33:46
他沒有做。

00:33:46 - 00:33:47
所以會變什麼呢？

00:33:47 - 00:33:48
防衛過當，

00:33:49 - 00:33:49
好嗎？

00:33:49 - 00:33:50
又再考這個東西，

00:33:50 - 00:33:53
所以社會的理性式考試真的很常出現。

00:33:53 - 00:33:54
呃,

00:33:54 - 00:33:55
這一題當中,

00:33:55 - 00:33:56
我要提醒同學不要落入陷阱。

00:33:57 - 00:33:58
你不能直接講說,

00:33:58 - 00:33:59
因為他沒有

00:34:00 - 00:34:00
有選擇迴避，

00:34:00 - 00:34:02
所以他不能成立正當防衛，

00:34:02 - 00:34:03
你不能直接這樣講。

00:34:04 - 00:34:05
因為如果你直接這樣講的話，

00:34:05 - 00:34:06
是說所以說，

00:34:06 - 00:34:08
說好的正當防衛不用委屈求全啊。

00:34:09 - 00:34:10
你這樣解釋是跳躍的，

00:34:10 - 00:34:10
知道嗎？

00:34:11 - 00:34:11
所以你要講說，

00:34:12 - 00:34:13
甲直接打回去。

00:34:13 - 00:34:15
他就防衛手段來講,

00:34:15 - 00:34:18
確實符合一般一般的適當性跟必要性,

00:34:18 - 00:34:19
瞭解嗎?

00:34:19 - 00:34:20
一般的適當性必要性,

00:34:20 - 00:34:21
對,

00:34:21 - 00:34:21
確實有過,

00:34:22 - 00:34:25
可是因為這裡是基於意圖式的挑唆防衛,

00:34:25 - 00:34:27
而落入了權力濫用禁止原則之後,

00:34:28 - 00:34:29
會有那個123的問題,

00:34:29 - 00:34:31
而甲沒有做123

00:34:31 - 00:34:32
所以才怎樣怎樣，

00:34:32 - 00:34:33
要這樣寫，

00:34:33 - 00:34:33
知道嗎？

00:34:36 - 00:34:36
好，

00:34:36 - 00:34:38
這個是13。

00:34:42 - 00:34:42
第十四題,

00:34:43 - 00:34:44
我不建議同學看。

00:34:45 - 00:34:46
我不建議同學看,

00:34:46 - 00:34:46
我跟你們說,

00:34:47 - 00:34:48
110,

00:34:49 - 00:34:52
就是111年的司三觀護人那一份。

00:34:53 - 00:34:56
那一份的考題應該是實務界出的刑法，

00:34:56 - 00:34:57
我自己覺得啦，

00:34:57 - 00:34:58
應該是。

00:34:58 - 00:34:59
那題目又臭又長。

00:34:59 - 00:35:00
又沒有什麼考點

00:35:00 - 00:35:01
很無聊

00:35:01 - 00:35:02
真的很無聊。

00:35:02 - 00:35:04
我覺得可能是實務界出的

00:35:04 - 00:35:05
實務界出的刑法就長這個樣子

00:35:06 - 00:35:06
就題目很臭很長，

00:35:07 - 00:35:08
然後又沒有什麼決定性的考點，

00:35:08 - 00:35:09
不知所云。

00:35:10 - 00:35:11
很多人問我說在考什麼，

00:35:11 - 00:35:11
我也覺得很莫名。

00:35:12 - 00:35:14
就真的沒有什麼值得考的東西,

00:35:14 - 00:35:16
所以這一份同學不要去糾結它,

00:35:16 - 00:35:18
這個我覺得不具有什麼代表性。

00:35:19 - 00:35:20
然後你看哦,

00:35:20 - 00:35:21
像

00:35:23 - 00:35:24
像那個什麼啊,

00:35:25 - 00:35:28
其他有些我們看，可能還沒有講過。

00:35:29 - 00:35:30
我看一下喔。

00:35:43 - 00:35:44
對，其他我們還沒有講過，

00:35:44 - 00:35:46
好啦，我們題目本身就先看到這邊。

00:35:47 - 00:35:48
幾個重要的題目我們都說了,

00:35:48 - 00:35:50
我們接著回來課本。

00:36:11 - 00:36:12
好,

00:36:12 - 00:36:13
接著回到課本的話,

00:36:13 - 00:36:17
我們上一次跟各位講到165頁這邊。

00:36:18 - 00:36:19
我們上一次跟各位說啊,

00:36:19 - 00:36:20
緊急避難，

00:36:20 - 00:36:22
尤其是攻擊型的緊急避難，

00:36:23 - 00:36:26
我們在判斷避難行為有沒有過當的時候，

00:36:26 - 00:36:29
重點往往會放在法益的衡量性。

00:36:29 - 00:36:31
也就是在攻擊型的避難當中,

00:36:32 - 00:36:34
行為人保全的法益,

00:36:34 - 00:36:35
必然要怎麼樣呢?

00:36:36 - 00:36:38
要大於他所侵害的法益,

00:36:38 - 00:36:39
這才可以阻卻違法

00:36:40 - 00:36:43
那麼在判斷到底法義之間是大於小於或等於的時候,

00:36:44 - 00:36:46
第一個關鍵叫做生命法義,

00:36:46 - 00:36:48
不可以量化比較,

00:36:48 - 00:36:51
生命法義是有最高的位階性,

00:36:51 - 00:36:53
這個是我們上一次下課前所講到的嘛

00:36:53 - 00:36:54
所以當時我們講第一個，

00:36:55 - 00:36:58
所有的生命都是等價的，

00:36:58 - 00:36:59
好，

00:36:59 - 00:37:17
所有的生命

00:37:17 - 00:37:40
都是等價的。

00:37:40 - 00:37:43
所以喜憨兒的生命跟臺大教授的生命，

00:37:44 - 00:37:45
兩個都是一樣的，

00:37:45 - 00:37:45
好嗎？

00:37:46 - 00:37:47
多數人的生命跟少數人的生命，

00:37:48 - 00:37:49
兩者也都是一樣的，

00:37:49 - 00:37:51
生命法義不可以量化比較。

00:37:51 - 00:37:54
同時生命法義也具有最高位階性,

00:37:55 - 00:37:55
也就是啊,

00:37:56 - 00:37:58
任何的法義碰上生命的話,

00:37:58 - 00:38:00
剩下的任何法義都是

00:38:00 - 00:38:00
一些德國學理啊什麼的

00:38:00 - 00:38:02
你有興趣的話可以去找黃惠婷老師，請把案例演習123，一般的廣告考生不建議看，因為它太細，那個學說內容太學理，但如果你對刑法有興趣，想讀研究所的話，可以看一看，黃老師這套書還蠻有趣的。

00:38:16 - 00:38:18
好，這裡喔，假涉及什麼罪？

00:38:19 - 00:38:20
這一題我們上次還沒講，對吧？

00:38:21 - 00:38:22
還沒喔，假涉及什麼罪？

00:38:23 - 00:38:25
第一個叫過失傷害吧，題目都講了

00:38:25 - 00:38:27
疏忽未注意車前狀況，所以構成過失傷害。

00:38:29 - 00:38:32
真正的過失傷害，不要花太多的篇幅去論述。

00:38:32 - 00:38:33
因為一定有過失，知道嗎？

00:38:33 - 00:38:35
你三行帶過就好了，過失傷害，再來假裝做什麼事？

00:38:38 - 00:38:39
肇事逃逸啊，對不對？

00:38:39 - 00:38:41
假肇事逃逸啊，185之4啊。

00:38:42 - 00:38:46
所以各位，這一題假的肇事逃逸，可不可以阻卻違法？

00:38:48 - 00:38:49
他可不可以主張緊急避難？

00:38:50 - 00:38:52
真諦就在考你衡平性的判斷。

00:38:53 - 00:38:56
對啊，假這一題所涉的肇事逃逸，假可不可以主張緊急避難？

00:38:57 - 00:38:59
這有沒有符合人性?

00:39:00 - 00:39:02
假保全什麼法益?

00:39:03 - 00:39:03
欸

00:39:03 - 00:39:08
那個司機拿開山刀要殺他,所以他面臨的生命法益上面的為難。

00:39:09 - 00:39:11
而他肇事逃逸犧牲什麼法益?

00:39:12 - 00:39:14
那肇事逃逸最保護什麼法益啊?

00:39:14 - 00:39:15
超多種不同的說法。

00:39:17 - 00:39:20
但不管怎麼樣，因為假面臨的生命的法益。

00:39:21 - 00:39:25
好了，肇事逃逸我們就姑且說他可能是某些國家或社會法益好了。

00:39:26 - 00:39:28
生命對上國家社會什麼重要？

00:39:28 - 00:39:30
廢話，當然生命重要啊。

00:39:30 - 00:39:32
國家社會那哪根蔥啊，對不對？

00:39:32 - 00:39:33
所以這裡可不可以請你避難？

00:39:33 - 00:39:34
當然可以，知道嗎？

00:39:34 - 00:39:35
這題考這個東西，所以我跟各位說的

00:39:36 - 00:39:39
生命法義是一個最高的價值。

00:39:39 - 00:39:42
其他的法義對上生命，就算是國家社會法義

00:39:42 - 00:39:44
國家社會根本就不重要，好嗎？生命才是一切的根本。

00:39:44 - 00:39:48
所以這題當中，緊急避難還是過得去喔。

00:39:50 - 00:39:50
好

00:39:50 - 00:39:52
所以這個考題我們就看到這。

00:39:53 - 00:39:54
接下來

00:39:55 - 00:39:55
接下來喔

00:39:56 - 00:39:59
下面這個166頁這個進階問題啊。

00:40:00 - 00:40:00
這個我來講一下。

00:40:03 - 00:40:06
這個東西吼，大一的時候困擾我很久。

00:40:06 - 00:40:08
因為當時的學說都沒有講清楚。

00:40:09 - 00:40:11
後來是慢慢問的老師，

00:40:11 - 00:40:13
慢慢看很多文獻才知道說，

00:40:13 - 00:40:14
哦，原來啊，

00:40:14 - 00:40:17
這個問題是導致於是起因於呢，

00:40:17 - 00:40:21
我國刑法的緊急避難跟德國刑法的緊急避難，

00:40:21 - 00:40:23
兩者規定不一樣。

00:40:23 - 00:40:24
是起因於這個問題。

00:40:25 - 00:40:27
這個，我先用一個題目來說。

00:40:28 - 00:40:30
你們來看163頁這一題。

00:40:31 - 00:40:32
163。

00:40:32 - 00:40:34
這一題我好像還沒有講。

00:40:50 - 00:40:52
163這一題我上次是不是還沒講。

00:40:52 - 00:40:53
還沒對不對？

00:40:53 - 00:40:54
好，

00:40:54 - 00:40:54
我們來看一下。

00:40:56 - 00:40:58
我用這個題目來跟各位講這一題涉及什麼問題。

00:40:59 - 00:41:01
剛剛那個爭點在爭什麼東西。

00:41:02 - 00:41:03
來，

00:41:03 - 00:41:03
163頁這一題喔。

00:41:05 - 00:41:06
一樣。

00:41:06 - 00:41:07
十年以前的考題。

00:41:07 - 00:41:09
但我覺得它非常的經典，所以我每個課程都會講。

00:41:11 - 00:41:12
這一題喔。

00:41:12 - 00:41:13
你看的題目。

00:41:14 - 00:41:16
有沒有感覺這個題目的敘述很怪。

00:41:19 - 00:41:20
真的啦，這一題的敘述不合理。

00:41:22 - 00:41:23
題目裡面說：

00:41:23 - 00:41:27
兩個人駕駛香蕉船來到海中間。

00:41:28 - 00:41:29
有沒有發現這很怪。

00:41:30 - 00:41:32
欸駕駛香蕉船，香蕉船怎麼駕駛。

00:41:33 - 00:41:35
有沒有玩過香蕉船或看過。

00:41:35 - 00:41:39
香蕉船不能駕駛啦，香蕉船是要前面水上摩托車在拖啦，他怎麼駕駛。

00:41:41 - 00:41:45
而且題目裡面還說，兩人落海時緊抓住船上的浮板一塊。

00:41:45 - 00:41:47
哇塞，香蕉船上來放浮板哦。

00:41:48 - 00:41:50
莫名其妙的題目。

00:41:50 - 00:41:52
出題老師根本沒有玩過香蕉船啊。

00:41:53 - 00:41:54
所以你要怎麼說啊。

00:41:55 - 00:41:58
所以國考你要相信題目所述為真，不然你寫不下去，好嗎？

00:41:59 - 00:42:00
所以你要相信。

00:42:00 - 00:42:00
這個小船，它自帶一個馬達，它可以駕駛，而且那是一個有安全性的船，船上會放浮板這樣，你要相信它，不然怎麼寫？

00:42:10 - 00:42:13
所以以後如果，我就跟同學講過，你要相信體制所說為真。

00:42:13 - 00:42:18
以後如果看到考題裡面說什麼，鳳梨長在樹上，你也要相信這個是真的，好嗎？

00:42:19 - 00:42:19
好，所以這一題喔。

00:42:21 - 00:42:24
假裝走移的浮板，假設及什麼呢？

00:42:24 - 00:42:25
殺人罪啊，殺人罪。

00:42:26 - 00:42:28
殺人罪這一題的構成要件一定該當。

00:42:28 - 00:42:29
不用廢話，一定該當。

00:42:30 - 00:42:32
這個重點不在構成要件。

00:42:32 - 00:42:36
所以我們講，當一個考題的重點不在構成要件的話，我寫一下，這一題的答題架構。

00:42:46 - 00:42:48
好，他涉及271條第一項嘛，故意殺人既遂。

00:42:49 - 00:42:50
構成要件。

00:42:52 - 00:42:53
客觀，主觀。

00:42:54 - 00:42:55
都過啊，沒有問題啊。

00:42:56 - 00:42:57
再來喔，違法性，這裡涉及什麼？

00:42:58 - 00:42:59
緊急避難。

00:43:00 - 00:43:01
24條，緊急避難。

00:43:02 - 00:43:04
所以來，一個要件我們來看。

00:43:05 - 00:43:07
前提事實有沒有符合？

00:43:08 - 00:43:10
假當時是不是面臨一個生命的緊急危難？

00:43:11 - 00:43:11
是，對不對？

00:43:11 - 00:43:12
所以前提事實是符合的。

00:43:13 - 00:43:14
第二個喔。

00:43:15 - 00:43:16
手段有沒有適當？

00:43:18 - 00:43:19
他手段有沒有適當？

00:43:19 - 00:43:21
所以這裡會遇到兩個問題。

00:43:21 - 00:43:22
第一個喔，來來，想一下，第一個遇到什麼問題？

00:43:25 - 00:43:26
自找危難啊。

00:43:27 - 00:43:28
誰叫他不穿救生衣，對吧？

00:43:29 - 00:43:31
有穿救生衣的話，他就不需要去搶人家的浮板啦。

00:43:32 - 00:43:34
所以第一個喔，這裡涉及自招危難。

00:43:35 - 00:43:36
這個是哪一種自招？

00:43:37 - 00:43:38
這題哪一種自招？

00:43:39 - 00:43:40
故意的還過失的？

00:43:41 - 00:43:42
應該是過失吧。

00:43:43 - 00:43:44
假沒那麼壞吧。

00:43:45 - 00:43:47
想製造這個船難殺掉，假沒有這麼陰險吧，對不對？

00:43:49 - 00:43:51
所以這一題喔，他是過失自招。

00:43:52 - 00:43:55
那過失自招，可不可以緊急避難？

00:43:57 - 00:43:58
是不是有可否兩說？

00:43:58 - 00:43:59
好，對，所以在考這個東西。

00:44:00 - 00:44:02
再來第二個問題是什麼呢？

00:44:03 - 00:44:04
橫評。

00:44:05 - 00:44:11
假若為了保全自己的生命，而犧牲同船隊友的生命，

00:44:11 - 00:44:13
生命對生命，所以很明顯有沒有過失？

00:44:13 - 00:44:14
當然沒有啊！

00:44:14 - 00:44:17
所以這一題的話呢，不能主張緊急避難。

00:44:18 - 00:44:18
好。

00:44:19 - 00:44:21
接著到了罪責。

00:44:22 - 00:44:23
這個才是爭議的所在。

00:44:25 - 00:44:27
到了罪責這邊，會有什麼效果？

00:44:27 - 00:44:29
來來，進罪責前，我補充講一點。

00:44:30 - 00:44:34
這一題當中，我講過失自招，有些同學會不同意。

00:44:35 - 00:44:37
有些同學說沒有啊，這個怎麼會是過失自招？

00:44:37 - 00:44:40
有些同學說，那個香蕉船翻掉，那個是不可抗力吧？

00:44:41 - 00:44:42
這個哪有人為的過失啊？

00:44:42 - 00:44:43
有同學這樣說欸。

00:44:44 - 00:44:47
對啊，我歷年都遇到同學這樣說，說香蕉船翻掉，那個是不可抗力啊，

00:44:47 - 00:44:50
海浪啊，沒有人有過失啊，這怎麼會有過失自招？

00:44:51 - 00:44:53
同學，如果你這樣想的話，你就搞錯了，你知道為什麼嗎？

00:44:54 - 00:44:57
因為這一題的危難不是船翻掉本身，而是什麼呢？

00:44:58 - 00:45:10
船翻掉之後，

00:45:10 - 00:45:29
甲在海上載浮載沉的

00:45:29 - 00:45:43
生命危險狀態。

00:45:44 - 00:45:44
所以同學啊，

00:45:45 - 00:45:51
船翻掉之後，甲在海上載浮載沉的生命危險狀態，那個狀態甲有沒有過失？

00:45:51 - 00:45:53
有啊,就他不穿救生衣嘛,

00:45:53 - 00:45:55
對不對?所以這一題是過失自招喔,知道嗎?

00:45:55 - 00:45:56
好。

00:45:57 - 00:45:59
所以來,我們到目前為止沒有疑問。

00:46:00 - 00:46:00
看法。

00:46:02 - 00:46:04
認為說這是什麼呢?

00:46:04 - 00:46:07
24條第一項但書,

00:46:07 - 00:46:10
認為說這個東西叫做避難過當。

00:46:11 - 00:46:13
所以傳統上會認為說,

00:46:13 - 00:46:15
這一種情況行為人還是有罪,

00:46:15 - 00:46:17
只是可以減免其刑。

00:46:17 - 00:46:18
避難過當,

00:46:18 - 00:46:18
OK嗎?

00:46:19 - 00:46:19
好。

00:46:21 - 00:46:22
那律師要說什麼呢?

00:46:23 - 00:46:24
這時候啊,

00:46:24 - 00:46:25
就請各位再翻到後面。

00:46:26 - 00:46:27
這個是我接著要說的。

00:46:29 - 00:46:30
這個東西,

00:46:30 - 00:46:31
你沒看過德國法,

00:46:31 - 00:46:33
你真的不知道他們在吵什麼。

00:46:34 - 00:46:36
我覺得同學現在都很幸福,

00:46:36 - 00:46:37
因為你們不會德文沒有關係,

00:46:37 - 00:46:39
AI都可以幫你們翻譯。

00:46:39 - 00:46:41
以前我大學的時候沒這種東西啊。

00:46:42 - 00:46:44
甚至連那個德國刑法的中譯本都找不到。

00:46:44 - 00:46:46
所以以前大學的時候,

00:46:46 - 00:46:47
因為我覺得以前大學的時候,

00:46:47 - 00:46:48
念那些書都會有一個困境，

00:46:49 - 00:46:52
就是很多學者他們在介紹一些從德國來的制度的時候，

00:46:52 - 00:46:55
他們沒有把德國法附在旁邊。

00:46:56 - 00:46:58
以至於不懂德國法的讀者會覺得說，

00:46:58 - 00:46:58
蛤,

00:46:58 - 00:46:59
為什麼你會這樣想？

00:47:00 - 00:47:01
後來看德國制度才知道說，

00:47:01 - 00:47:02
哦,原來是這樣來的。

00:47:03 - 00:47:04
我們這裡啊,

00:47:04 - 00:47:05
往後翻。

00:47:06 - 00:47:06
不是往後翻啊,

00:47:06 - 00:47:08
就是我剛剛所講的那個東西,

00:47:08 - 00:47:09
那個在哪裡？

00:47:13 - 00:47:14
就166嘛。

00:47:14 - 00:47:15
來。

00:47:17 - 00:47:18
為什麼？

00:47:18 - 00:47:19
我先講結論。

00:47:19 - 00:47:22
這個香蕉船案,如果依照有力說,

00:47:22 - 00:47:23
少數說的看法,

00:47:24 - 00:47:26
這個少數說以前只有黃榮堅老師一個人採。

00:47:27 - 00:47:29
前幾年啊,

00:47:29 - 00:47:30
許澤天老師改變見解,

00:47:30 - 00:47:32
加入黃榮堅老師這個陣營。

00:47:33 - 00:47:34
他們的說法是：

00:47:34 - 00:47:34
結論：

00:47:34 - 00:47:40
叫做成立免除罪責的緊急避難而無罪。

00:47:41 - 00:47:42
這是他們的結論。

00:47:42 - 00:47:45
說成是免除罪責的緊急避難而無罪。

00:47:46 - 00:47:48
所以同學聽了會覺得很怪想說,

00:47:48 - 00:47:48
蛤,

00:47:48 - 00:47:51
為什麼會有免除罪責的緊急避難可以無罪,

00:47:51 - 00:47:52
為什麼會有這個東西?

00:47:53 - 00:47:55
那我們的24不就觸法嗎?

00:47:55 - 00:47:57
所以我在講這個思維怎麼來之前,

00:47:57 - 00:48:00
我們先來看一下德國法的規定。

00:48:01 - 00:48:02
各位啊,

00:48:02 - 00:48:05
你一定要知道德國法的緊急避難是兩個條文,

00:48:05 - 00:48:06
34跟35。

00:48:08 - 00:48:09
這是我國法最大的不同。

00:48:10 - 00:48:12
很多跟緊急避難的效果有關的爭議，

00:48:12 - 00:48:17
都源自於德國刑法分這個34跟35這兩條。

00:48:17 - 00:48:22
德國刑法34這個叫做阻卻違法的緊急避難。

00:48:22 - 00:48:23
德國刑法35條呢,

00:48:24 - 00:48:26
這個叫做免除罪責的緊急避難。

00:48:27 - 00:48:28
你看一下34條怎麼說的。

00:48:30 - 00:48:30
你看哦,

00:48:31 - 00:48:35
34條說為了排除他人生命身體自由名譽財產或其他法益的現實危險而出於不得已的衡量,

00:48:35 - 00:48:36
不得已的行為,

00:48:37 - 00:48:37
其利益衡量,

00:48:38 - 00:48:40
所保護的利益明顯超過所侵害的利益時,

00:48:41 - 00:48:42
該行為不違法。

00:48:43 - 00:48:44
有沒有覺得很熟悉?

00:48:44 - 00:48:46
不就我們前面講的緊急避難，主救法的要件嗎？

00:48:46 - 00:48:47
對不對？

00:48:47 - 00:48:49
所以德國刑法34，

00:48:49 - 00:48:52
它就是阻卻違法的緊急避難。

00:48:52 - 00:48:55
你有沒有發現德國的條文寫得比我們更精準？

00:48:56 - 00:48:58
我們的24條有寫什麼法益衡量嗎？

00:48:58 - 00:48:58
其實沒有，

00:48:58 - 00:48:59
對不對？

00:48:59 - 00:49:00
但人家德國的就有寫。

00:49:01 - 00:49:03
所以為什麼我們的學者會講什麼法益衡量什麼的？

00:49:04 - 00:49:05
就德國法來的啊。

00:49:05 - 00:49:06
真的啦，

00:49:06 - 00:49:08
很多那種我們的學歷你百思不得解，

00:49:08 - 00:49:09
你一看德國法的條文你就懂了，

00:49:10 - 00:49:11
因為那個就德國法的規定。

00:49:11 - 00:49:11
好,

00:49:11 - 00:49:13
可是德國法還有一個第35條喔,

00:49:13 - 00:49:15
你看一下第35條怎麼說啊。

00:49:16 - 00:49:17
來，第35條,

00:49:18 - 00:49:22
它叫做免除罪責的緊急避難。

00:49:25 - 00:49:26
為排除自己、

00:49:26 - 00:49:28
親屬或其他親近之人的生命、

00:49:28 - 00:49:29
身體、

00:49:29 - 00:49:30
自由的現實危險，

00:49:31 - 00:49:32
所為的不得已行為。

00:49:33 - 00:49:34
無責

00:49:34 - 00:49:35
無罪責。

00:49:36 - 00:49:39
這個緊急避難你看清楚跟34比。

00:49:40 - 00:49:41
35有沒有法益衡量性?

00:49:42 - 00:49:43
沒有。

00:49:44 - 00:49:44
有沒有發現？

00:49:44 - 00:49:45
對，

00:49:45 - 00:49:45
這就是關鍵。

00:49:46 - 00:49:47
35沒有法益衡量性。

00:49:48 - 00:49:49
所以來，

00:49:49 - 00:49:51
我們暫時切到德國法的世界。

00:49:52 - 00:49:55
假設那個香蕉船案發生在德國，

00:49:56 - 00:49:57
行為人怎麼論罪？

00:49:58 - 00:50:00
行為人是不是不能論罪？

00:50:00 - 00:50:00
對啊，當然不行啊，因為法益很沒有過啊。

00:50:03 - 00:50:09
但在德國怎麼論罪，簡單嘛，論355條罪嘛，對不對，成立免除罪責緊急避難而無罪，好。

00:50:10 - 00:50:12
這個無罪的結論有些學者很欣賞。

00:50:13 - 00:50:16
那可是回我國法，我們的緊急避難沒有這樣分，怎麼辦？

00:50:17 - 00:50:17
對啊，怎麼辦？

00:50:18 - 00:50:22
所以傳統就說沒辦法，我們沒有類似355條的規定啊，所以本案只能避難過當。

00:50:23 - 00:50:24
這是傳統的看法，知道嗎？

00:50:24 - 00:50:27
而少數說許澤天老師、黃老師的看法。

00:50:28 - 00:50:29
他們會覺得說啊。

00:50:29 - 00:50:35
我們沒有35的規定沒有錯，可是你不能因為我們的法律規定得爛，你就讓行為人變成有罪，不能這樣做。

00:50:36 - 00:50:39
而應該怎麼做，擴大解釋我們的24。

00:50:39 - 00:50:46
也就是啊，這一派的看法覺得我們的24條，他的不法，他的無罪有兩種不同的情況。

00:50:47 - 00:50:51
通過法益衡量，他是阻卻違法而無罪。

00:50:51 - 00:50:54
通不過法益衡量會怎麼樣？

00:50:55 - 00:50:57
通不過法益衡量。

00:50:57 - 00:51:01
又能符合德國刑法35條的要件的，我們會怎麼樣？

00:51:02 - 00:51:07
轉而讓他成立所謂免除罪責的緊急避難而無罪。

00:51:09 - 00:51:15
所以就是啊，我國刑法的24條，他其實隱含了兩種不同的緊急避難。

00:51:16 - 00:51:19
通過法益衡量，阻卻違法而不罰。

00:51:20 - 00:51:24
通不過法益衡量，又符合德國刑法35條的那些要件的。

00:51:25 - 00:51:27
怎麼樣，免除罪責而不罰。

00:51:27 - 00:51:28
知道嗎，這是另外一種看法。

00:51:29 - 00:51:30
所以啊。

00:51:31 - 00:51:32
我們這邊寫好。

00:51:33 - 00:51:34
有的說會成立啊。

00:51:40 - 00:51:40
免除罪責的緊急避難。

00:51:56 - 00:51:59
成立免除罪責的緊急避難。

00:52:06 - 00:52:09
所以趙、許澤天老師、趙黃間老師的看法，

00:52:09 - 00:52:11
這件不會是避難過當而有罪喔，

00:52:11 - 00:52:15
而是學理所謂免除罪責的緊急避難而無罪。

00:52:16 - 00:52:18
好，免除罪責的緊急避難而無罪。

00:52:19 - 00:52:21
所以,我跟各位說,

00:52:22 - 00:52:30
在德國刑法之下,會被判定為35條的免除罪責的緊急避難類型。

00:52:31 - 00:52:33
因為我們的刑法沒有這個條文嘛,

00:52:34 - 00:52:36
所以傳統見解是不是都把它當避難過當?

00:52:36 - 00:52:37
對,沒有錯。

00:52:37 - 00:52:39
所以這裡也會牽涉到一個問題,

00:52:39 - 00:52:41
什麼叫做免除罪責?

00:52:42 - 00:52:43
你看那個德文字。

00:52:46 - 00:52:46
這怎麼唸啊?

00:52:47 - 00:52:50
EntschuldigenderNotstand,應該是類似這樣念法吧。

00:52:50 - 00:52:53
我不知道我德文發音可能很爛啦,勉強看得懂而已。

00:52:55 - 00:52:56
這個東[redacted] ,

00:52:57 - 00:53:24
EntschuldigenderNotstand,

00:53:24 - 00:53:41
Notstand只是緊急避難啦

00:53:42 - 00:53:44
那前面那個字,不知道同學學過德文,

00:53:45 - 00:53:47
它跟德文的對不起,Entschuldigung有點像。

00:53:48 - 00:53:51
這個東西也有人把它翻譯成寬恕罪責。

00:53:52 - 00:53:52
也有人這樣翻譯,

00:53:53 - 00:53:54
也有人把它翻譯成寬恕罪責。

00:53:55 - 00:53:57
我們這邊打個叉來看下後面。

00:53:57 - 00:54:00
因為這個東西都是連在一起的,我必須要一起講。

00:54:00 - 00:54:01
起來吧,OK吼。

00:54:01 - 00:54:07
可是像上,像如果你採許澤建老師這種想法的話,他保留的德國法原汁原味的說法,所以他們會覺得所謂的免除罪責跟寬恕罪責就同一個字。

00:54:12 - 00:54:13
你看到160頁。

00:54:14 - 00:54:17
免除罪責或寬恕罪責是有。

00:54:18 - 00:54:22
你看那個東西,恩shuldigung的,就那個東西啊。

00:54:23 - 00:54:24
那個東西。

00:54:25 - 00:54:27
如果照徐老師的說法,

00:54:28 - 00:54:30
他是什麼，他就是無罪。

00:54:30 - 00:54:30
的確是有。

00:54:31 - 00:54:33
他不是前面起訴而已。

00:54:33 - 00:54:37
因為其實你看德國法，這個東西在德國法他就是無罪。

00:54:38 - 00:54:42
那反而是他們會覺得我們傳統的學者都扭曲了德國法的原因。

00:54:42 - 00:54:44
只因為我們的法律規定得不好。

00:54:44 - 00:54:48
那個東西搬來臺灣就變成有罪，沒有，他在德國法無罪的原因是因為無罪，知道嗎？

00:54:48 - 00:54:56
所以以後，你在刑法文獻上面看到這個關鍵字，你就看那個字頭嘛，很像德文的對不起那個字。

00:54:56 - 00:54:59
那個東西叫所謂的免除罪責事由。

00:55:00 - 00:55:02
寬恕罪責事由。

00:55:02 - 00:55:03
再講一次喔。

00:55:03 - 00:55:08
那個東西傳統上會把它當作是一種避難過當有罪的事由來處理，只是可以免刑。

00:55:09 - 00:55:10
可是少數說學的是什麼呢？

00:55:11 - 00:55:13
我們要依照德國法的方式去理解。

00:55:13 - 00:55:16
應該認為他是一個無罪的推定，好嗎？

00:55:16 - 00:55:18
應該認為他是一個無罪的推定喔。

00:55:19 - 00:55:20
好，所以這個跟德國法有關的東西。

00:55:21 - 00:55:22
我就跟各位講到這邊了。

00:55:24 - 00:55:25
好。

00:55:25 - 00:55:27
所以這個東西可能對第一次聽到的同學來講會有點複雜喔。

00:55:28 - 00:55:29
不過不要覺得它很難喔。

00:55:30 - 00:55:33
你看德國法34跟35，在對照回我國的。

00:55:33 - 00:55:35
大概就可以知道大家在吵什麼了。

00:55:36 - 00:55:36
好。

00:55:36 - 00:55:38
接著下來喔。

00:55:38 - 00:55:39
OK。

00:55:39 - 00:55:40
現在剛好11點呢。

00:55:40 - 00:55:42
好了好了，這是一個小段落。

00:55:42 - 00:55:43
我們休息，先休息10分鐘。

00:55:43 - 00:55:46
等一下呢，我們再來看168頁下面這個東西。

00:55:49 - 00:55:50
好。

00:55:50 - 00:55:52
我們接著來看168頁這邊。

00:55:52 - 00:55:53
我們來看到。

00:55:53 - 00:55:53
第二點啊，第三點。

00:55:53 - 00:55:56
這邊說個人的自主決定權。

00:55:57 - 00:56:00
這個東西考試考出來永遠

00:56:00 - 00:56:00
都是拿來千篇一律。

00:56:01 - 00:56:05
考試考這個東西呢，永遠會考出來的版本叫做強制抽血。

00:56:05 - 00:56:07
比如說你來看到這邊這一個案例。

00:56:08 - 00:56:08
你看喔。

00:56:09 - 00:56:13
A因為車禍失血過多，血型罕見，醫院缺乏這種血型。

00:56:13 - 00:56:16
醫師講到，義工C是這個血型，要求C捐血，但C不要。

00:56:17 - 00:56:23
那醫師為了挽救A的性命呢，所以強制拘束C的身體，並且抽了C的血液。

00:56:23 - 00:56:27
問說這一切可不可以緊急避難而主事者違法。

00:56:28 - 00:56:30
這個不是不可能發生。

00:56:30 - 00:56:36
因為我們一般人的血型都是RH陽性嘛，但有些人可能是RH陰性血，就會遇到這個問題。

00:56:37 - 00:56:40
那我每次講這個題目的時候，我都覺得這個題目的設計很有趣。

00:56:40 - 00:56:42
特別講醫院的志工。

00:56:42 - 00:56:44
然後我看到想說這義工根本就假愛心。

00:56:44 - 00:56:49
都願意去醫院當義工的，為什麼關鍵的時候需要他的血，他反而說我不要，我不捐血。

00:56:49 - 00:56:50
很有趣的設計，對不對？

00:56:51 - 00:56:52
來。

00:56:52 - 00:56:54
這一題當中，法益很平，有沒有過？

00:56:55 - 00:56:57
對啊，這題法益有沒有被侵害？

00:56:58 - 00:57:00
你看喔，有否定說和肯定說。

00:57:00 - 00:57:01
你知道這個在爭什麼嗎？

00:57:02 - 00:57:04
把那個義工壓在那邊抽他的血。

00:57:05 - 00:57:07
侵害了義工的什麼法益？

00:57:08 - 00:57:09
關鍵就在這邊。

00:57:09 - 00:57:11
好，把義工壓在那邊抽他血，侵害他什麼法益？

00:57:12 - 00:57:14
有人認為緊急避難過得去，為什麼？

00:57:15 - 00:57:18
因為有人認為這裡就是純粹的身體而已。

00:57:19 - 00:57:21
對啊，抽血啊，身體啊。

00:57:21 - 00:57:22
就頂多身體一下自由嘛。

00:57:22 - 00:57:24
那身體一下自由，另外一邊換什麼法益？

00:57:25 - 00:57:26
生命啊。

00:57:26 - 00:57:28
為了生命法益的維護，而犧牲別人的身體。

00:57:30 - 00:57:31
再加上一點點自由，OK嘛，過得去嘛。

00:57:32 - 00:57:34
所以有些人覺得這一題可以緊急避難。

00:57:34 - 00:57:37
因為有人認為說呢,這一題它就是純粹的身體再加上一點點自由法益而已。

00:57:37 - 00:57:38
OK啊,當然可以很平啊。

00:57:38 - 00:57:38
可是

00:57:38 - 00:57:45
多數說認為這件法益很貧弱過不去,為什麼?

00:57:47 - 00:57:48
因為多數覺得

00:57:48 - 00:57:49
多數所覺得,把人壓在那個地方抽血。

00:57:51 - 00:57:55
這裡所侵害的,不會僅僅是身體而已。

00:57:56 - 00:57:58
這根本是一個人格尊嚴的否定。

00:57:59 - 00:58:00
因為多數縱容。

00:58:00 - 00:58:00
覺得

00:58:00 - 00:58:02
你把人壓在那個地方抽血

00:58:02 - 00:58:04
你已經不把他當人看了

00:58:04 - 00:58:07
你只是把它當作一個純粹供應血液的機器

00:58:08 - 00:58:11
你已經完全藐視他作為一個人所享有的基本尊嚴

00:58:11 - 00:58:13
所以為什麼多數說認為這一屆會變得比較難過關

00:58:14 - 00:58:15
根本沒辦法過得去很明顯

00:58:16 - 00:58:16
再講一次

00:58:16 - 00:58:17
因為多數說覺得

00:58:18 - 00:58:19
把人壓在那個地方抽血

00:58:20 - 00:58:21
這樣的行為,

00:58:21 - 00:58:23
根本已經不把他當人看,

00:58:24 - 00:58:26
等於就是把這個人當作是一個供血的機器而已,

00:58:27 - 00:58:27
所以這個是什麼呢?

00:58:28 - 00:58:31
這裡不是單純的身體而已喔,

00:58:31 - 00:58:33
這裡會上升到人性尊嚴的層次,

00:58:33 - 00:58:35
這裡會變成是人性尊嚴的對象生命,

00:58:36 - 00:58:37
所以才會說這個叫什麼?

00:58:37 - 00:58:37
過當,

00:58:38 - 00:58:38
知道嗎?

00:58:38 - 00:58:39
所以多數說,

00:58:39 - 00:58:41
認為說這種情況不能阻卻違法。

00:58:42 - 00:58:42
好,

00:58:43 - 00:58:43
再來第四點,

00:58:44 - 00:58:46
法益損害的強度。

00:58:47 - 00:58:48
我們會說啊,

00:58:48 - 00:58:49
生命不可以量化比較,

00:58:50 - 00:58:50
這個當然沒話說,

00:58:51 - 00:58:54
但如果是生命以外的其他法益呢?

00:58:55 - 00:59:00
這裡會不會有所謂法益損害的強度的問題呢?

00:59:00 - 00:59:00
好,

00:59:00 - 00:59:01
我們講法益怎麼排?

00:59:02 - 00:59:04
生命、身體、自由、財產,

00:59:04 - 00:59:04
對不對?

00:59:05 - 00:59:05
我們這樣排嘛。

00:59:05 - 00:59:06
生命、身體、自由、財產,

00:59:07 - 00:59:07
所以各位,

00:59:09 - 00:59:09
自由跟財產,

00:59:10 - 00:59:11
哪一個大?

00:59:12 - 00:59:13
正常來說自由比較大,

00:59:14 - 00:59:14
對不對?

00:59:14 - 00:59:15
正常來說自由比較大。

00:59:16 - 00:59:16
可是各位,

00:59:17 - 00:59:18
自由跟財產,

00:59:19 - 00:59:20
雖然自由比較大,

00:59:21 - 00:59:21
沒錯,

00:59:22 - 00:59:22
雖然自由比較大,

00:59:22 - 00:59:23
沒錯,

00:59:24 - 00:59:24
可是,

00:59:26 - 00:59:28
可是在有些情況之下,

00:59:29 - 00:59:31
如果加入法益的總量,

00:59:31 - 00:59:32
那可能就不一樣了。

00:59:33 - 00:59:33
對,

00:59:34 - 00:59:35
我們說抽象的法益本質來講,

00:59:36 - 00:59:37
自由比財產大,

00:59:37 - 00:59:39
可是我問同學一個問題嘛,

00:59:40 - 00:59:42
如果是數十分鐘的自由,

00:59:43 - 00:59:45
對上巨額的財產,

00:59:46 - 00:59:48
你還會說自由比較大嗎?

00:59:48 - 00:59:49
可能不見得囉。

00:59:50 - 00:59:51
我們就用日常生活來講嘛,

00:59:52 - 00:59:53
假設有人跟你說,

00:59:53 - 00:59:55
我把你關到一個恐怖的密室,

00:59:56 - 00:59:56
關你一個小時,

00:59:57 - 00:59:58
給你三萬塊,

00:59:58 - 00:59:59
要不要?

01:00:00 - 01:00:01
好像很好賺欸。

01:00:01 - 01:00:03
如果是我的話我也會說好啊。

01:00:03 - 01:00:05
對啊我也會說好啊。

01:00:05 - 01:00:05
你想嗎?

01:00:06 - 01:00:09
當律師去給人家做那個法律諮詢。

01:00:09 - 01:00:14
因為律師我們,我們當律師收那個諮詢費,工會的建議。

01:00:15 - 01:00:16
就是一小時收5000。

01:00:17 - 01:00:21
啊如果把我關去那個恐怖密室，我在裡面什麼事都不用做欸。

01:00:21 - 01:00:24
就忍受一下恐懼，然後出來就有3萬塊，比當律師還要好賺欸。

01:00:25 - 01:00:26
那不錯欸，對不對？

01:00:26 - 01:00:30
所以對啊，你說自由比財產重要，對，通常這樣沒有錯。

01:00:30 - 01:00:34
可是如果是短暫的自由，對上極高的財產呢？

01:00:35 - 01:00:36
這可能就未必了，對不對？

01:00:37 - 01:00:40
所以這個時候呢，就要把法益侵害的總量納入考量。

01:00:41 - 01:00:44
考出來啊，永遠都長這個樣子，你來看光學二。

01:00:45 - 01:00:50
珠寶店裡面有數個客人在挑選珠寶，不知何故突然停電30秒。

01:00:50 - 01:00:54
電力恢復之後啊，店長發現有一顆上千萬的鑽石不見。

01:00:55 - 01:00:57
30秒內沒有任何人離開珠寶店。

01:00:58 - 01:01:00
顯見啊，顧客必然

01:01:00 - 01:01:03
就是多名顧客其中之一。

01:01:03 - 01:01:05
竊賊必然就是他們其中一人。

01:01:05 - 01:01:08
所以店長把門反鎖，通知警方前來。

01:01:08 - 01:01:09
同學。

01:01:09 - 01:01:10
這案例當中啊。

01:01:11 - 01:01:15
店長把門反鎖涉及到剝奪行動自由，罪刑是302條。

01:01:16 - 01:01:18
那這一種案例你要會區分喔。

01:01:19 - 01:01:25
因為你想啊，假設現場三個客人，三個客人裡面其實只有一個是小偷，對吧，另外兩個是無辜的。

01:01:27 - 01:01:29
所以店長要用什麼阻卻方法是有？

01:01:30 - 01:01:30
你要區分喔。

01:01:31 - 01:01:34
店長對於真正的小偷，

01:01:35 - 01:01:37
他可以主張什麼？

01:01:37 - 01:01:38
正當防衛。

01:01:38 - 01:01:39
現行犯逮捕，對不對？

01:01:40 - 01:01:40
OK。

01:01:40 - 01:01:44
店長對於那個真正偷鑽石的人，不會用緊急避難喔。

01:01:44 - 01:01:46
瞭解吧，因為他就是小偷嘛。

01:01:46 - 01:01:48
我們可以走正當防衛或走現行犯逮捕。

01:01:49 - 01:01:50
緊急避難是指對誰？

01:01:51 - 01:01:52
無辜被關的其他客人。

01:01:53 - 01:01:54
瞭解吧？

01:01:54 - 01:01:57
緊急避難針對的是那個無辜被關的其他客人。

01:01:57 - 01:01:59
這以前轉學考考過，你要會分，知道嗎？

01:01:59 - 01:02:00
所以

01:02:00 - 01:02:00
所以我再講一次喔，對於真正的小偷，這個是正當防衛或者是現行犯逮捕的問題喔。

01:02:06 - 01:02:16
我們緊急避難探討的對象是對於那個什麼，當初被關，但事後發現他無辜，他根本不是小偷的客人才會去走緊急避難。

01:02:16 - 01:02:19
所以各位，這一題緊急避難過得去還過不去？

01:02:21 - 01:02:25
抽象的法益來講，為了保護財產而犧牲自由。

01:02:26 - 01:02:29
單純就法益的種類好像過不去。

01:02:29 - 01:02:34
可是自由沒有說不能量化比較啊，生命才不行啊，自由可以啊。

01:02:34 - 01:02:36
所以這一題當中,可不可以阻擋解圍避難?

01:02:37 - 01:02:37
可以。

01:02:37 - 01:02:40
為什麼?30分鐘的自由。

01:02:40 - 01:02:44
對啊,好像也不到30分鐘吧,警察可能不會拖那麼久吧。

01:02:44 - 01:02:46
通常警察可能十幾分鐘就來了嘛。

01:02:46 - 01:02:49
十幾分鐘的自由對上上千萬的財產。

01:02:50 - 01:02:52
財產當然重要的嘛，對不對？

01:02:52 - 01:02:57
所以這題當中呢，我們會認為說這個解避難手段是合理的喔，法益衡量是過得去的喔。

01:02:59 - 01:02:59
好。

01:02:59 - 01:03:00
所以

01:03:00 - 01:03:02
我們翻到170頁第五點。

01:03:03 - 01:03:05
法益遭受危險的大小。

01:03:08 - 01:03:11
我們來看這個東西，法益遭受危險的大小。

01:03:12 - 01:03:14
這裡啊，會涉及到一個問題。

01:03:15 - 01:03:18
這個東西考出來永遠就是這麼的千篇一律。

01:03:19 - 01:03:26
行為人為了要拯救危急的傷患而冒險酒後駕車。

01:03:26 - 01:03:27
永遠都是這樣考，我想不出第二個版本。

01:03:27 - 01:03:31
真的，他考出來的永遠就是這個樣子，為了拯救危急的傷患而冒險酒駕。

01:03:31 - 01:03:34
下面這個題目你們看一下，多年前幾特試的就考這個東西。

01:03:34 - 01:03:35
非常經典的一個考題。

01:04:09 - 01:04:12
好，這一題假該當什麼罪？

01:04:14 - 01:04:15
185之3啊，對不對，酒駕。

01:04:17 - 01:04:20
這一題的酒駕罪，它會有一些分則的問題。

01:04:20 - 01:04:22
那個以後我們到分則再去說。

01:04:22 - 01:04:28
反正我先跟各位講結論，這一題假的185之3，構成要件一定該當。

01:04:29 - 01:04:36
因為這個會牽涉到185之3的危險犯性質，它是一條抽象危險犯。

01:04:36 - 01:04:37
不以個案有交通危險為必要。

01:04:37 - 01:04:37
但那個分則以後我們再說。

01:04:37 - 01:04:44
反正，真題不管照多數說或怎麼樣，不管它的構成要件一定會該當，知道嗎？

01:04:44 - 01:04:46
它一定會該當185之3，好。

01:04:47 - 01:04:50
那行為人該當了185之3之後，接著，對。

01:04:50 - 01:04:52
185之3該當，我跟各位講一下。

01:04:52 - 01:04:54
當年有同學這樣寫。

01:04:55 - 01:04:57
因為這個考在寫特試的嘛，他沒有附法條。

01:04:58 - 01:05:01
那個四等考試就很容易考同學說法條到底熟不熟。

01:05:01 - 01:05:02
這一題很賊喔。

01:05:02 - 01:05:06
一般考0.185之3，題目都會寫那個吐氣的酒精濃度。

01:05:07 - 01:05:08
結果這個題寫抽血。

01:05:09 - 01:05:10
他就是要看你法條熟不熟，他寫抽血。

01:05:11 - 01:05:12
你知道嗎？

01:05:13 - 01:05:14
我

01:05:14 - 01:05:16
我當年有個學生去考這一題。

01:05:16 - 01:05:16
那

01:05:16 - 01:05:18
他法條不熟，結果他跟我說。

01:05:18 - 01:05:19
說他在寫這一題的時候啊。

01:05:22 - 01:05:23
他法條不熟嘛。

01:05:23 - 01:05:27
他就覺得行為人那個抽血的酒測值沒有達標。

01:05:27 - 01:05:29
所以他就說沒有達標就構成要件不該當，這一題就結束。

01:05:31 - 01:05:32
然後他就說要這樣寫。

01:05:33 - 01:05:34
我就嗆他說你是智障喔。

01:05:35 - 01:05:37
我跟他還蠻熟的，我就嗆他說你是智障喔。

01:05:37 - 01:05:39
如果這一題構成要件不該當，那三行就結束了。

01:05:39 - 01:05:42
後面還跟你寫那麼多幹什麼，所以這個是寫題目的技巧，知道嗎？

01:05:43 - 01:05:48
你不確定法條有沒有該當，而你發現後面有一堆細節的時候，你當然要說他有該當啊。

01:05:48 - 01:05:51
不然後面你要寫什麼，對不對？所以真題當中，當然他的構成要件有該當。

01:05:55 - 01:05:55
當然有啊。

01:05:56 - 01:05:58
這裡的問題是違法性，來。

01:05:58 - 01:05:58
來

01:06:00 - 01:06:03
假面臨第三人的什麼法律危險？

01:06:04 - 01:06:06
重大身體

01:06:06 - 01:06:09
甚至可能會到生命的程度,對不對?

01:06:09 - 01:06:15
所以假要保全的是一個身體或者是重大的身體,甚至可能是一個生命程度的法益。

01:06:16 - 01:06:18
而假犧牲什麼法益?

01:06:19 - 01:06:20
他酒後駕車,

01:06:21 - 01:06:22
所以他犧牲什麼法益?

01:06:22 - 01:06:24
公共安全。

01:06:25 - 01:06:27
公共安全其實具體來講，它也是什麼？

01:06:28 - 01:06:30
不特定人的生命身體安全。

01:06:31 - 01:06:32
所以有沒有感覺很難判斷？

01:06:33 - 01:06:36
它保全跟犧牲那一邊的法益其實本質上都是差不多的，對不對？

01:06:36 - 01:06:37
所以怎麼判斷？

01:06:37 - 01:06:38
來，所以學者這樣說，

01:06:39 - 01:06:41
學者這樣說啊，在這種情況之下，

01:06:42 - 01:06:45
那你要看行為人所犧牲的法益那一邊，

01:06:46 - 01:06:49
到底是已經形成了具體危險？

01:06:50 - 01:06:54
還是僅止於抽象危險而已。

01:06:54 - 01:06:58
所以各位你看一下，這一題假酒駕的行為，

01:06:59 - 01:07:02
有沒有對公眾往來的安全形成具體的危險？

01:07:03 - 01:07:04
答案是沒有，

01:07:04 - 01:07:04
為什麼？

01:07:04 - 01:07:05
因為題目裡面怎麼說？

01:07:06 - 01:07:10
說假使神智清醒，而且途中也只有零星的車輛。

01:07:11 - 01:07:13
也就是假使雖然該當酒駕沒有錯，

01:07:13 - 01:07:17
但假使並沒有對公眾往來的安全形成太具體的危險。

01:07:17 - 01:07:18
沒有。

01:07:18 - 01:07:19
假只是怎麼樣？

01:07:19 - 01:07:21
形成一個抽象上的危險而已，對不對？

01:07:21 - 01:07:23
假只有形成抽象的危險，

01:07:23 - 01:07:24
所以整體法益很平讓他過。

01:07:25 - 01:07:26
要喔。

01:07:26 - 01:07:27
知道嗎？

01:07:27 - 01:07:27
這一條讓他過。

01:07:27 - 01:07:29
所以各位啊，如果這一題反過來，

01:07:29 - 01:07:31
如果題目裡面跟你講說，

01:07:31 - 01:07:35
假當時的意識已經有點模糊，

01:07:35 - 01:07:41
途中車輛很多，好幾度差點追撞到機車騎士或路人。

01:07:41 - 01:07:42
如果題目這樣說，

01:07:42 - 01:07:43
那法益很沒有過？

01:07:43 - 01:07:44
就沒有了。

01:07:44 - 01:07:44
為什麼？

01:07:44 - 01:07:49
因為這樣子的話，假使製造的就已經是一個具體危險了，

01:07:49 - 01:07:49
知道嗎？

01:07:49 - 01:07:55
所以我們講，為了救，為了要拯救危急的病患，而冒險酒駕的情形，

01:07:56 - 01:07:57
法益很沒有過呢？

01:07:57 - 01:07:58
我們的重點在什麼呢？

01:07:59 - 01:08:00
在於

01:08:00 - 01:08:04
行為人所犧牲的公共安全那邊，

01:08:04 - 01:08:06
到底是隻有抽象的危險，

01:08:06 - 01:08:10
還是已經達到了具體危險的程度，

01:08:10 - 01:08:11
我們看的是這個。

01:08:11 - 01:08:12
好,

01:08:12 - 01:08:13
所以我們用這個題目來講,

01:08:13 - 01:08:14
大概就看到這邊。

01:08:14 - 01:08:16
接下來170頁,

01:08:16 - 01:08:18
又是進階問題了。

01:08:18 - 01:08:21
強制性緊急避難的法律評價。

01:08:22 - 01:08:23
這個東西啊,

01:08:24 - 01:08:27
前年臺大法研所有考過。

01:08:28 - 01:08:30
應該是許志人老師的題目。

01:08:31 - 01:08:34
然後在當年的退除役軍官轉任考,

01:08:34 - 01:08:35
考了一模一樣的東西,

01:08:35 - 01:08:36
我等一下帶你們去看。

01:08:37 - 01:08:39
我常覺得退除役軍官很可憐,

01:08:39 - 01:08:40
都被迫考那麼難的東西。

01:08:41 - 01:08:43
跟臺大法研所考一樣欸,

01:08:43 - 01:08:43
我曉得奇怪,

01:08:43 - 01:08:46
出題老師是不是對那個退除役軍官有什麼仇恨,

01:08:46 - 01:08:48
出那麼難的東西去刁難他們。

01:08:48 - 01:08:49
對啊,

01:08:49 - 01:08:51
退除役軍官考的跟臺大法研所一樣是怎樣啊。

01:08:52 - 01:08:52
來,

01:08:53 - 01:08:54
強制性緊急避難,

01:08:54 - 01:08:55
它涉及到的問題是這樣子。

01:08:56 - 01:08:57
什麼叫強制性緊急避難？

01:08:58 - 01:08:58
當今天啊,

01:08:59 - 01:09:22
緊急避難的

01:09:22 - 01:09:41
行為人，

01:09:42 - 01:09:47
同時他也身兼了強制罪的被害人的話，

01:09:47 - 01:09:50
他就叫做強制性緊急避難。

01:09:50 - 01:09:51
瞭解嗎？

01:09:51 - 01:09:52
緊急避難的行為人，

01:09:52 - 01:09:54
同時也身兼了強制罪的被害人

01:09:54 - 01:09:57
那就叫做強制性的緊急避難。

01:09:58 - 01:10:00
那個德文字我寫上去

01:10:00 - 01:10:04
知道愛因斯坦，我都還記得啊，那女孩的下夜店，想說奇怪，我為什麼會那個行政法的單字，看得就忘不掉。

01:10:05 - 01:10:06
真的啊。

01:10:06 - 01:10:08
你現在問我一些生活德文的單字，我可能都忘記了，但法學的都不會忘記啊。

01:10:12 - 01:10:13
好，我們來看一下。

01:10:17 - 01:10:17
來。

01:10:18 - 01:10:20
假脅迫乙。

01:10:21 - 01:10:22
來，我們這樣設定。

01:10:34 - 01:10:34
來。

01:10:36 - 01:10:38
假為誰，假跟你說。

01:10:39 - 01:10:40
你去找彼得車。

01:10:41 - 01:10:44
如果你不砸彼得車，我就持刀捅森。

01:10:45 - 01:10:49
彼得非常害怕，因此非常害怕，所以只好去砸彼得車。

01:10:50 - 01:10:51
這邊我們就問。

01:10:51 - 01:10:55
那以所該當的毀損罪，要怎麼處理？

01:10:56 - 01:11:00
你看喔，一方面是緊急避難的行為人。

01:11:00 - 01:11:03
另外一方面，他也是強制罪的被害人。

01:11:04 - 01:11:07
所以我們再講一次喔，什麼叫做強制性緊急避難？

01:11:08 - 01:11:14
當今天緊急避難的行為人，他同時也身兼強制罪的被害人的時候。

01:11:14 - 01:11:18
這一種情況，我們就叫做強制性緊急避難。

01:11:18 - 01:11:19
好。

01:11:19 - 01:11:22
我們在爭執的是強制性緊急避難。

01:11:23 - 01:11:27
他是阻卻違法，還是免除罪責。

01:11:28 - 01:11:30
差別在這邊，他是阻

01:11:30 - 01:11:32
卻違法還是免除罪責呢。

01:11:32 - 01:11:33
好。

01:11:33 - 01:11:36
這裡有幾說，第一說是我們傳統的看法叫阻卻違法說。

01:11:37 - 01:11:43
所以通說會覺得強制性緊急避難跟一般的緊急避難沒有什麼不同，要件什麼的都一樣。

01:11:45 - 01:11:47
所以通說會覺得，到底這個緊急

01:11:47 - 01:11:54
避難的危難來源是什麼，動物的攻擊是自然力，或者是別人的犯罪行為。

01:11:54 - 01:11:57
傳統商學的說，那不重要，那不過就是一個現象而已。

01:11:58 - 01:12:00
我們不應該以這個東西作為規律

01:12:00 - 01:12:00
上的區分依據，所以傳統上的看法會覺得說，你看嘛，我們的24條，他也沒有對危難來源做區分啊。

01:12:00 - 01:12:01
24條要旨講生命、身體、自由、財產上的侵害，為難來源是人或物什麼的，不重要嘛。

01:12:12 - 01:12:21
所以傳統見解會跟你說，這種所謂的強固性緊急避難，他沒有什麼好特別說的，他就是緊急避難。

01:12:21 - 01:12:24
所以他的效果是什麼呢？就是阻卻違法，知道嗎？

01:12:24 - 01:12:30
所以傳統上因為覺得條文沒有內心的區分，所以他會把強固性緊急避難跟一般的緊急避難認為是一樣的，都是怎麼樣？

01:12:32 - 01:12:34
阻卻違法，而不卻你犯罪。

01:12:34 - 01:12:36
好,所以這傳統的看法,阻卻違法。

01:12:37 - 01:12:43
相對的有另外一種說法叫做免除罪責說,或者叫做寬恕罪責說,第二點。

01:12:45 - 01:12:47
當然這裡又牽涉到我們上半堂課講的問題。

01:12:48 - 01:12:50
那個寬恕罪責是什麼意思?

01:12:52 - 01:12:52
我再想一次。

01:12:53 - 01:12:57
因為我們的刑法沒有類似德國刑法第35條的規定。

01:12:58 - 01:13:04
所以傳統上會把所謂的免除罪責或寬恕罪責理解成對應到什麼東西？

01:13:05 - 01:13:06
24條第一項但書。

01:13:07 - 01:13:07
避難過當。

01:13:08 - 01:13:08
好吧。

01:13:09 - 01:13:15
所以你看到寬恕罪責，你不要把它等同是阻卻罪責，不是喔，它是另外一個不同的德文字，知道嗎？

01:13:15 - 01:13:20
再講一次喔，因為我們的刑法沒有類似德國刑法35條的那一種規定。

01:13:20 - 01:13:24
所以傳統上所謂的免除罪責或寬恕罪責。

01:13:24 - 01:13:25
他是有罪的喔。

01:13:25 - 01:13:26
他就是避難過當，知道嗎？

01:13:27 - 01:13:29
當然啦，如果你照許澤天老師的看法。

01:13:30 - 01:13:31
這個會變無罪。

01:13:32 - 01:13:33
那個是另外的問題，我剛剛講過，知道嗎？

01:13:33 - 01:13:34
那是另外的問題喔，好。

01:13:36 - 01:13:38
所以第二說啊，那個叫做寬恕罪責說，或者叫免除罪責說。

01:13:39 - 01:13:44
第二說覺得緊急避難只能阻卻罪責，只能阻卻罪責，為什麼？

01:13:47 - 01:13:51
因為第二說的學者，第二說的學者，他們覺得

01:13:53 - 01:13:54
有一個關鍵字啊。

01:13:54 - 01:13:55
叫做以，他是利益假不法的一方。

01:13:59 - 01:13:59
那個關鍵字。

01:14:00 - 01:14:02
的文義我叫做利於不法的一方。

01:14:02 - 01:14:05
白話文的意思就是，你根本跟甲是一夥的啦。

01:14:06 - 01:14:07
對丙來說，

01:14:07 - 01:14:09
丙會覺得乙無辜嗎？

01:14:09 - 01:14:11
不會啊，丙會覺得說乙就是甲的人啊。

01:14:12 - 01:14:14
所以,另外一種說法會覺得,

01:14:14 - 01:14:17
乙的部分所涉及的緊急避難,

01:14:18 - 01:14:20
我們最多隻能把它放在罪責

01:14:20 - 01:14:23
因為乙並不是全然無辜的,

01:14:23 - 01:14:24
乙就是甲的人啊。

01:14:25 - 01:14:26
對啊，乙就是甲的人啊。

01:14:26 - 01:14:34
所以乙這裡，他頂多，就算採我們現在這種學說的看法，乙頂多可以認為說，他成立免除罪責的緊急避難而無罪。

01:14:35 - 01:14:36
而不能讓他阻卻不法。

01:14:37 - 01:14:38
這是另外一說。

01:14:38 - 01:14:40
來，前兩說的區別實益在哪裡？

01:14:42 - 01:14:44
區別實益在於，

01:14:45 - 01:14:47
那丙可不可以對乙正當防衛？

01:14:47 - 01:14:48
這就是實益，

01:14:48 - 01:14:50
懂嗎？丙可不可以對乙正當防衛？

01:14:50 - 01:14:51
同學，

01:14:52 - 01:14:56
如果你覺得強取性緊急避難是阻卻違法的話,

01:14:57 - 01:14:59
那乙去砸丙的車,

01:14:59 - 01:15:01
乙是合法喔。

01:15:01 - 01:15:03
丙可不可以正當防衛？不行啊。

01:15:03 - 01:15:07
但如果你把強取性緊急避難定位在罪責的話,

01:15:07 - 01:15:09
乙砸丙的車變不法,

01:15:09 - 01:15:11
所以丙可不可以正當防衛？可以。

01:15:11 - 01:15:12
實益在這邊,

01:15:12 - 01:15:13
懂嗎？實益在這邊。

01:15:14 - 01:15:20
這個寬恕罪責說啊，它最根本的目的當然不是說一定要讓丙可以正當防衛,

01:15:20 - 01:15:21
它基本的想法是什麼？

01:15:22 - 01:15:24
就乙是假的人嘛，乙跟甲是一夥的嘛，

01:15:24 - 01:15:26
你怎麼說乙是全然無辜呢？

01:15:26 - 01:15:27
瞭解吧？它主要的核心是這樣子喔。

01:15:28 - 01:15:31
接著還有一個折衷說啦，我們翻過來，折衷說。

01:15:33 - 01:15:35
折衷說的主張是這樣子,

01:15:35 - 01:15:40
他說啊,保留強取性緊急避難阻卻違法的可能性,但提高適用的門檻。

01:15:41 - 01:15:43
只有在被強取者啊,

01:15:43 - 01:15:45
遭受生命身體或自由的重大危險,

01:15:45 - 01:15:48
而且避難手段也不會對別人

01:15:48 - 01:15:50
生命身體自由形成損害的時候,

01:15:50 - 01:15:51
才可以阻卻違法

01:15:52 - 01:15:54
否則都只能減免罪責而已。

01:15:57 - 01:15:59
所以這個折衷說是怎麼樣?

01:16:00 - 01:16:03
區分情況適用一跟二。

01:16:03 - 01:16:06
懂這意思吧，就是區分情況適用一跟二。

01:16:06 - 01:16:15
你看嘛，如果行為人，他有生命身體的重大威脅，而且他的避難手段，也不會犧牲到無辜的生命身體自由，那怎麼樣？

01:16:16 - 01:16:17
走主卻不法。

01:16:18 - 01:16:20
反之怎麼樣？

01:16:20 - 01:16:20
最多免除罪責。

01:16:20 - 01:16:22
同學吧，所以這個是折衷說的說法，是情況，看決定要採哪一說。

01:16:24 - 01:16:28
所以黑板上這個例子，這個例子如果採折衷說的話會怎麼樣？

01:16:30 - 01:16:30
會怎麼樣？

01:16:31 - 01:16:33
主卻不法，主卻違法。

01:16:34 - 01:16:35
因為他財產而已嘛，對不對？

01:16:35 - 01:16:36
財產而已，所以這一題的話呢，看你採哪一說。

01:16:39 - 01:16:40
好，那我這邊講區別實益。

01:16:41 - 01:16:44
區別實益的，第一個是正當防衛的問題。

01:16:45 - 01:16:47
第二個問題是什麼呢，是共犯的問題。

01:16:48 - 01:16:50
共犯的問題的話,我們這邊來看一下考題。

01:16:52 - 01:16:55
來,帶各位看當年這個退出一考的什麼。

01:17:56 - 01:17:58
在第九頁第八題,我們來看一下。

01:17:59 - 01:18:00
第九頁第八題。

01:18:13 - 01:18:20
好,以威脅甲去做偽證,

01:18:20 - 01:18:31
所以甲後來果然在有生命威脅的情況之下

01:18:31 - 01:18:36
做了虛偽的陳述。

01:18:36 - 01:18:38
假可能會成立偽證罪。

01:18:38 - 01:18:40
所以前面的參數我們再跑一下喔。

01:18:41 - 01:18:44
假這裡所成立的偽證，所以他可不可以主張緊急避難的阻卻違法？

01:18:45 - 01:18:48
那你看主張阻卻違法說的話，當然阻卻違法嘛。

01:18:48 - 01:18:49
主張免除罪責說的話，

01:18:50 - 01:18:52
他的效果會是免除罪責。

01:18:52 - 01:18:56
當然你要延續探討的是說，那什麼是免除罪責。

01:18:56 - 01:18:59
免除罪責是避難過當，還是他是無罪的事由。

01:20:00 - 01:20:00
當然是另外一個問題了，我剛剛講的。

01:20:02 - 01:20:05
然後如果才折衷說呢，這一題可不可以阻卻不法，可以。

01:20:05 - 01:20:10
因為他避難的手段並沒有犧牲掉別人的生命身體自由，OK嗎，對不對，所以這是真的部分。

01:20:12 - 01:20:13
這個是假的部分。

01:20:13 - 01:20:14
好，那所以真的怎麼論罪。

01:20:16 - 01:20:18
就真的的部分來說，真的怎麼論罪。

01:20:20 - 01:20:24
以威脅假作偽證，所以真的會成立強制罪，沒有疑問。

01:20:25 - 01:20:27
然後這裡啊，跟同學先講一個後面的東西。

01:20:28 - 01:20:29
間接正犯。

01:20:30 - 01:20:32
各位，我們先記得一件事。

01:20:32 - 01:20:38
脅迫別人犯罪的人，往往也會成立那一條罪的間接正犯。

01:20:39 - 01:20:48
我跟你說，你去把公主王門市砸掉，你不去砸公主王門市的話，我就放火燒死你全家，你超害怕，你把公主王的門市給砸了。

01:20:48 - 01:20:51
這樣的話,我除了成立強制罪,我還會論什麼。

01:20:52 - 01:20:54
毀損罪的間接正犯,知道嗎。

01:20:54 - 01:20:57
逼迫別人犯罪的人除了成立強制罪之外,還有什麼呢。

01:20:58 - 01:21:00
那一條罪的

01:21:00 - 01:21:01
間接正犯。

01:21:01 - 01:21:02
懂嗎，這個叫強制支配，我們以後會說。

01:21:03 - 01:21:04
所以來。

01:21:04 - 01:21:08
以逼迫假作偽證，除了成立強制罪之外，也可以說

01:21:09 - 01:21:13
也成立偽證罪的間接正犯。

01:21:14 - 01:21:15
這是後面的考點，我先跟你們說。

01:21:16 - 01:21:19
偽證罪叫純正身分犯，偽證罪他又既遂犯。

01:21:20 - 01:21:22
這樣的性質不可能成立間接正犯。

01:21:23 - 01:21:25
這個你沒有學過沒關係，以後我們會講，知道嗎。

01:21:25 - 01:21:26
反正我跟你們說了。

01:21:27 - 01:21:28
再講一次喔。

01:21:28 - 01:21:29
我講簡單的結論。

01:21:30 - 01:21:37
逼迫別人犯罪的人，照理說應該要成立他所逼迫的那一條罪的間接正犯。

01:21:37 - 01:21:42
可是偽證罪的性質沒辦法成立間接正犯。

01:21:42 - 01:21:46
所以這個時候是不是隻能轉個彎，考慮讓他成立教唆犯。

01:21:47 - 01:21:47
好。

01:21:48 - 01:21:52
那如果要成立教唆犯的話，教唆犯又有一個問題，又是我們後面才要講的，叫共犯從屬。

01:21:55 - 01:21:56
要成立教唆犯，必須要怎麼樣。

01:21:58 - 01:22:00
必須正犯的行為。

01:22:00 - 01:22:01
有該當且違法。

01:22:03 - 01:22:09
所以假設該當的偽證罪到底是阻卻不法或阻卻罪，或免除罪責。

01:22:10 - 01:22:13
是不是也會連帶影響到成立教唆犯的可能性？

01:22:14 - 01:22:15
能不能從屬的問題。

01:22:16 - 01:22:18
來，這一塊我講共犯從屬，你沒學過沒關係。

01:22:19 - 01:22:21
以後我們會在說，這一題超難，知道嗎？

01:22:21 - 01:22:27
所以如果是，因為有些函授的同學可能不是法律系轉，被什麼監護人啊，什麼三等考試，第一次學習法沒關係。

01:22:28 - 01:22:29
這一塊你現在聽不懂無所謂。

01:22:30 - 01:22:32
我們把教唆犯學完你再回來看，

01:22:32 - 01:22:32
就懂了，好吧？

01:22:33 - 01:22:34
刑法時候會這樣子喔。

01:22:36 - 01:22:39
對啊，所以這一題是你看，當年退出乙法聯。

01:22:40 - 01:22:42
我覺得考這很不人道欸。

01:22:43 - 01:22:46
就稱它，這是臺大法研所的考點，真的啦，你去看當年臺大法研所刑法組。

01:22:49 - 01:22:51
那個是許志人老師的文章題。

01:22:51 - 01:22:57
大概就是說，有個人被地下錢莊逼債，他被逼債有生命危險嘛，他就去

01:22:58 - 01:23:00
那個偷偷背下，

01:23:00 - 01:23:02
因為他是商店的店員,

01:23:02 - 01:23:05
他就偷偷背下那個客人的信用卡卡號,

01:23:05 - 01:23:09
然後去綁定什麼電子支付去償債之類的，大概是類似的事實啦,

01:23:11 - 01:23:12
就跟這個很像。

01:23:13 - 01:23:15
所以你看，我真的考出來了。

01:23:15 - 01:23:17
強聚性寫一避難，知道嗎？

01:23:17 - 01:23:18
所以這個三說，區別在這邊。

01:23:19 - 01:23:20
第一個是正當防衛，第二個是共犯的成立。

01:23:24 - 01:23:27
所以以前啊，以前我都說這個是思慮的考點吧。

01:23:27 - 01:23:29
這應該不會考這般的國考，我說我們

01:23:30 - 01:23:31
考在退出一三等。

01:23:32 - 01:23:33
好。

01:23:33 - 01:23:33
接著來。

01:23:34 - 01:23:35
難的看完了，我們回來看簡單的。

01:23:38 - 01:23:39
我們來看到172頁。

01:24:00 - 01:24:00
好，172頁，我們剛剛講的那麼多法益衡量。

01:24:05 - 01:24:07
那都是在講攻擊型緊急避難。

01:24:09 - 01:24:13
再跟各位複習一次喔，緊急避難分兩種喔，攻擊型跟防禦型喔，什麼意思？

01:24:14 - 01:24:23
如果今天被那個緊急避難所犧牲的法益是一個無辜的法益，也就是危難根本就跟他無關，幹他什麼事，他就被犧牲了，那一種叫做攻擊型緊急避難。

01:24:27 - 01:24:30
相對的，那如果被犧牲的法益

01:24:30 - 01:24:34
其實並不無辜，他就是始作俑者，

01:24:34 - 01:24:37
他就是危難的來源，那叫做

01:24:37 - 01:24:39
防禦型緊急避難。

01:24:40 - 01:24:45
所以我一直跟同學講，緊急避難他並不是永遠都在犧牲無辜。

01:24:45 - 01:24:53
以考試的觀點來講，防禦型很少考，通常都是攻擊型，通常都是犧牲無辜，沒有錯，但不必然喔。

01:24:53 - 01:24:55
有的時候是防禦型喔，很特別喔。

01:24:55 - 01:24:55
好。

01:24:56 - 01:24:58
防禦型緊急避難跟攻擊型有什麼不同？

01:24:59 - 01:25:00
我們的想

01:25:00 - 01:25:00
法是這樣。

01:25:01 - 01:25:03
攻擊型的,因為他會犧牲無辜。

01:25:04 - 01:25:07
所以我們才會要求一大堆什麼衡平性什麼的要件,超嚴格對不對?

01:25:08 - 01:25:09
但防禦型沒有哦。

01:25:09 - 01:25:14
防禦型，因為他所犧牲的對象就是危難的來源。

01:25:16 - 01:25:19
被犧牲的對象就是危難來源，他並不無辜欸。

01:25:20 - 01:25:22
所以我們說危難來源要選擇自己吞下去。

01:25:22 - 01:25:23
知道吧，所以這個時候呢，

01:25:23 - 01:25:26
法益衡平性會放寬。

01:25:26 - 01:25:26
好,所以我們來看到

01:25:28 - 01:25:30
幾種情況喔。

01:25:30 - 01:25:31
第一個,對物防禦。

01:25:33 - 01:25:33
對物防禦喔。

01:25:34 - 01:25:35
這個比較不會有疑問,你看到這個案例。

01:25:36 - 01:25:40
登山者無端遭河馬攻擊，為了保命，只好把河馬殺死。

01:25:43 - 01:25:44
欸，不覺得這個案例怪怪的嗎？

01:25:45 - 01:25:46
好，爬山遇到河馬咬你，

01:25:47 - 01:25:48
所以把河馬殺了。

01:25:49 - 01:25:51
我當初在寫這個案例的時候，

01:25:51 - 01:25:53
我在想要用什麼保育的野生動物

01:25:53 - 01:25:56
原本想臺灣黑熊，但感覺太平淡無奇了。

01:25:57 - 01:25:59
原本想寫櫻花鉤吻鮭。

01:26:00 - 01:26:00
但登山者被櫻花鉤吻鮭攻擊，鮭魚逆流而上，從河裡跳出來去咬人，所以他把那個鮭魚砍死，這太不可理喻了，所以想說寫河嘛，寫河嘛。

01:26:10 - 01:26:10
好。

01:26:10 - 01:26:16
這一題當中,我們看,偽者要保密,誰把河馬給殺死。

01:26:16 - 01:26:19
你說河馬的命跟登山者的命哪一個重要?

01:26:20 - 01:26:21
還好啦,就隨便啦。

01:26:22 - 01:26:23
反正,因為這個是防禦型嘛。

01:26:24 - 01:26:27
所以法益很平時要怎麼樣,非顯然不相當,就給他過,知道嗎,就給他過。

01:26:28 - 01:26:32
好，那相對的關懷人，對人防禦，所以我們講喔。

01:26:32 - 01:26:40
對人防禦的話，被犧牲的人，因為他就為難來源，他就應該自我承受，他不應該把為難做轉嫁，所以這個時候呢。

01:26:40 - 01:26:44
不需要考慮被犧牲者的自主決定權。

01:26:46 - 01:26:47
所以我們來看到下面這個第一個案例。

01:26:48 - 01:26:51
精神病患A，每到半夜就會去樓下砸鄰居的機車。

01:26:52 - 01:26:58
而A的家人為了避免鄰居的機車遭殃,所以在A的食物當中摻入安眠藥,讓A半夜可以好好睡。

01:26:59 - 01:27:00
這個案例喔。

01:27:00 - 01:27:01
來來來,我們思考一下。

01:27:02 - 01:27:04
有沒有成立正當防衛的可能性?

01:27:05 - 01:27:07
其實這個案例跟家暴殺夫根本就超像,有沒有?

01:27:08 - 01:27:09
對啊。

01:27:09 - 01:27:10
有沒有成立正當防衛的可能性？

01:27:11 - 01:27:12
照通說沒有，為什麼？因為那個侵害不是現在侵害嘛。

01:27:14 - 01:27:16
對不對，他是將來的侵害啊。

01:27:16 - 01:27:19
所以通說的看法，這一件沒辦法用正當防衛。

01:27:19 - 01:27:21
所以緊急避難有沒有機會？

01:27:22 - 01:27:22
有喔。

01:27:23 - 01:27:26
這一件照通說的看法，緊急避難是過得去的喔。

01:27:26 - 01:27:28
你不要跟我講說這裡法益不很平衡喔。

01:27:29 - 01:27:30
因為有些同學。

01:27:30 - 01:27:30
的想法是。

01:27:30 - 01:27:33
你讓這個精神病患吃藥昏過去。

01:27:33 - 01:27:35
身體法益強，自由法益，保護什麼？

01:27:36 - 01:27:37
鄰居的車子而已，財產，怎麼可以為了保護財產犧牲別的身體跟自由。

01:27:37 - 01:27:38
不對。

01:27:38 - 01:27:38
不能這樣看。

01:27:38 - 01:27:38
因為這個不是攻擊型。

01:27:38 - 01:27:39
這個是什麼？是防禦型啊。

01:27:39 - 01:27:39
那為難來源是誰？

01:27:39 - 01:27:39
就他，對不對？

01:27:39 - 01:27:40
所以這一種是防禦型喔。

01:27:40 - 01:27:40
我們講防禦型的法益很平性。

01:27:40 - 01:27:40
只要不要顯然的失衡。

01:27:40 - 01:27:40
只要不要那種明顯說不過去。

01:27:40 - 01:27:41
那就讓他過了，知道嗎？所以這一件呢。

01:28:00 - 01:28:00
的話，防禦寫得很平靜，過得去喔，知道嗎，這是過得去的喔。

01:28:04 - 01:28:05
來，下面這個也是。

01:28:07 - 01:28:10
這個，你看喔，A、B兩個結伴登山。

01:28:10 - 01:28:14
兩個人為了避免摔落，而以扣環把彼此扣在一起。

01:28:14 - 01:28:16
不掉啊，攀登時B失足踩空。

01:28:17 - 01:28:19
扣環掛著，搖搖欲墜。

01:28:19 - 01:28:23
A以自身力氣完全拉不起B，甚至放任B懸空可能會導致A一同摔落。

01:28:24 - 01:28:28
於是A呢，只好把扣環解開，使B摔落山谷而死亡。

01:28:29 - 01:28:30
這

01:28:30 - 01:28:30
一題當中。

01:28:31 - 01:28:33
一樣，你不要落入陷阱。

01:28:33 - 01:28:36
你不要去想說好像香蕉船那一題生命對生命，沒有，不是那個問題。

01:28:37 - 01:28:39
香蕉船的那個生命對生命。

01:28:39 - 01:28:42
被犧牲的人真的不干他的事。

01:28:42 - 01:28:43
又不是他害的，對不對？

01:28:44 - 01:28:45
可是這一題不是啊。

01:28:46 - 01:28:48
這一題當中，A為什麼會有生命危險？

01:28:49 - 01:28:50
B造成的嘛，對不對？

01:28:50 - 01:28:51
B造成的啊，所以這一題不是攻擊性喔。

01:28:51 - 01:28:54
這一題是防禦性喔，所以這一題防禦很頻繁可以被過。

01:28:56 - 01:28:57
可以，知道嗎？

01:28:57 - 01:28:58
這是防禦性喔，不要搞錯了喔。

01:29:00 - 01:29:00
好。

01:29:01 - 01:29:03
最後，下面這一個專題研究。

01:29:03 - 01:29:04
我們來看一下。

01:29:06 - 01:29:08
欸，我們之前好像沒有看過類似的標。

01:29:08 - 01:29:11
對啊，你看今年專題研究上面都有一隻可愛的小豬。

01:29:11 - 01:29:13
這、這個，這個豬我不知道。

01:29:14 - 01:29:17
他們美編是不是抓那個圖庫裡面的，應該是吧。

01:29:18 - 01:29:22
然後我就覺得這種形狀的豬感覺會站在那個超市的肉品生鮮區看到。

01:29:22 - 01:29:26
這就是對嘛,我越看越眼熟嘛,就是那個肉品區的那個豬嘛。

01:29:26 - 01:29:29
對啊,難怪覺得好像常常在哪裡看到。

01:29:30 - 01:29:30
這個

01:29:30 - 01:29:33
覺得他可愛,還是你看到會覺得肚子餓,覺得想吃。

01:29:33 - 01:29:33
好,我們來看一下。

01:29:34 - 01:29:34
那個

01:29:37 - 01:29:37
這邊。

01:29:37 - 01:29:42
保全跟犧牲的法益，同屬於一人所有，這是一種很特殊的類型。

01:29:45 - 01:29:46
行為人為了保護A，結果最後也犧牲了A。

01:29:49 - 01:29:50
哎，很特別喔。

01:29:51 - 01:29:55
我們前面講的一般的攻擊型跟防禦型是保護A而犧牲B，或者保護A而犧牲C。

01:29:55 - 01:29:58
這一種不是喔，這一題當中。

01:29:59 - 01:30:00
嗯。

01:30:00 - 01:30:01
這一種類型當中，

01:30:01 - 01:30:03
被保全跟被犧牲的對象。

01:30:03 - 01:30:05
竟然是同一個人呢。

01:30:05 - 01:30:06
你說這也叫緊急避難？

01:30:06 - 01:30:07
對。

01:30:08 - 01:30:08
我跟你們講，

01:30:09 - 01:30:10
這一種類型啊，

01:30:11 - 01:30:12
其實照現在的觀點，

01:30:13 - 01:30:14
會依照客觀規則處理。

01:30:15 - 01:30:16
真的。

01:30:16 - 01:30:17
這個其實我們前面有講過，

01:30:18 - 01:30:19
我不知道同學這邊有沒有做註記。

01:30:20 - 01:30:20
我們前面有講過喔,

01:30:21 - 01:30:24
這一種類型其實如果照現在多數的看法,

01:30:25 - 01:30:27
我們會在客觀規則處理。

01:30:29 - 01:30:30
你看到下面兩個案例,

01:30:30 - 01:30:31
第一個打山豬。

01:30:32 - 01:30:33
A相約去山上打獵,

01:30:34 - 01:30:35
結果B被山豬攻擊而撲倒在地,

01:30:35 - 01:30:36
跟山豬搏鬥,

01:30:36 - 01:30:37
命在旦夕,

01:30:37 - 01:30:39
A舉槍瞄準山豬要把山豬打死,

01:30:40 - 01:30:41
結果山豬轉身啊,

01:30:41 - 01:30:44
A不小心把B給打死了。

01:30:45 - 01:30:46
這一種案例,

01:30:47 - 01:30:49
我們在客觀規則其實討論過欸。

01:30:49 - 01:30:50
當時在講什麼?

01:30:50 - 01:30:51
還記得那個名詞嗎？

01:30:52 - 01:30:53
替代性風險。

01:30:54 - 01:30:54
有沒有印象？

01:30:55 - 01:30:56
替代性風險。

01:30:56 - 01:30:56
來來來，

01:30:57 - 01:30:58
你忘記的話往回翻。

01:30:58 - 01:30:59
客觀規則其實我們講過了，

01:31:00 - 01:31:00
往回翻喔，

01:31:01 - 01:31:01
客觀規則。

01:31:02 - 01:31:03
當時我們在比較一個概念叫做，

01:31:04 - 01:31:06
那個降低風險跟替代性風險。

01:31:58 - 01:31:58
8889,

01:31:59 - 01:32:00
忘記的話往回翻喔。

01:32:00 - 01:32:02
如果這個拯救是有成功的,

01:32:03 - 01:32:05
被害人被救回一命,

01:32:05 - 01:32:09
可是拯救的過程被害人可能受了一些小傷,

01:32:09 - 01:32:11
我們會說這個叫什麼？

01:32:11 - 01:32:12
降低風險,

01:32:13 - 01:32:14
對不對？我們會說它叫降低風險。

01:32:14 - 01:32:15
來，那我再補充喔，

01:32:16 - 01:32:18
因為客觀規則它並不是從以前就有的嘛。

01:32:19 - 01:32:21
在以前還沒有客觀規則的年代，

01:32:22 - 01:32:24
你拯救被害人拯救成功，他沒有死，

01:32:24 - 01:32:26
但被害人受了點小傷，

01:32:26 - 01:32:27
這一種以前會用什麼處理？

01:32:28 - 01:32:29
緊急避難啊。

01:32:29 - 01:32:33
就是我們剛剛講的，保全跟犧牲同屬於一人所有，知道嗎？

01:32:33 - 01:32:34
就會這樣處理啊。

01:32:34 - 01:32:35
好，再來。

01:32:36 - 01:32:37
那拯救失敗呢？

01:32:38 - 01:32:39
山豬案。

01:32:40 - 01:32:41
或者以前我口頭舉過例子啊,

01:32:41 - 01:32:45
你在等公車，有一臺卡車失控，朝你的站牌衝過來，

01:32:45 - 01:32:46
那你要逃命啊，

01:32:46 - 01:32:48
你看到旁邊有個小朋友，你也抓著他跑啊。

01:32:49 - 01:32:53
結果你抓著他跑的時候，你不小心讓那個小朋友的頭敲到電線桿，

01:32:53 - 01:32:55
那小朋友顱內出血死掉，我是不是舉過這個例子？

01:32:56 - 01:32:56
有吧，對不對？

01:32:57 - 01:32:58
這個例子，

01:32:59 - 01:33:01
如果你採取客觀歸責理論的話，

01:33:02 - 01:33:03
可能會有什麼概念處理？

01:33:03 - 01:33:05
替代性風險。

01:33:05 - 01:33:09
所以我們是不是講過，替代性風險跟降低風險的差別在哪裡？

01:33:09 - 01:33:14
降低風險是拯救成功，可是拯救的過程人受傷的。

01:33:15 - 01:33:18
而替代性風險是怎麼樣？拯救失敗人死了。

01:33:18 - 01:33:22
而且我們發現就算不拯救，人幾乎也是必死無疑。

01:33:22 - 01:33:23
這個叫替代性風險。

01:33:23 - 01:33:30
所以我再講一次喔，這種案例其實照現在多數的說法不會跑去緊急避難啦。

01:33:30 - 01:33:36
這一種所謂保全跟犧牲法益同屬於一人所有的情形，

01:33:36 - 01:33:40
現在多數的說法會說呢，客觀規則就解決了。

01:33:41 - 01:33:42
要嘛降低風險，

01:33:43 - 01:33:44
要嘛替代性風險，

01:33:44 - 01:33:45
OK吧？

01:33:45 - 01:33:47
所以我們翻回143頁。

01:33:49 - 01:33:51
為什麼緊急避難還會有這個東西？

01:33:53 - 01:33:55
這個就是歷史的遺跡。

01:33:56 - 01:33:59
意思就是，如果你不採客觀規則理論，

01:34:00 - 01:34:03
或者是不認為有替代性風險這種東西，

01:34:04 - 01:34:06
那才會用緊急避難來處理，

01:34:06 - 01:34:07
知道嗎？

01:34:07 - 01:34:08
多數說不會這樣子喔,

01:34:08 - 01:34:10
多數說直接在客觀規則就解決了喔,

01:34:10 - 01:34:11
OK喔。

01:34:13 - 01:34:14
好,

01:34:14 - 01:34:16
接著來144C。

01:34:27 - 01:34:28
最後第四點,

01:34:29 - 01:34:31
緊急避難跟正當防衛的關係。

01:34:32 - 01:34:34
這個東西很簡單,

01:34:34 - 01:34:34
來。

01:34:35 - 01:34:37
對正當防衛可不可以正當防衛？

01:34:37 - 01:34:38
當然不行啊,

01:34:38 - 01:34:40
正當防衛的前提是什麼？

01:34:40 - 01:34:41
現在不法侵害,

01:34:41 - 01:34:42
對不對？

01:34:42 - 01:34:45
所以別人正當防衛，你在反擊說我也正當防衛？

01:34:45 - 01:34:46
沒有啊,

01:34:46 - 01:34:47
就不正當啦。

01:34:47 - 01:34:49
對方是合法行為,

01:34:49 - 01:34:50
你怎麼正當防衛，對不對？

01:34:51 - 01:34:53
啊，對，正當防衛可不可以緊急避難？

01:34:53 - 01:34:54
當然不行嘛。

01:34:55 - 01:34:57
因為緊急避難的危難也不包括合法行為嘛，

01:34:57 - 01:34:58
對不對？

01:34:58 - 01:34:58
好，

01:34:58 - 01:34:59
反過來，

01:34:59 - 01:35:20
對別人的緊急避難,

01:35:20 - 01:35:41
可不可以正當防衛?

01:35:42 - 01:35:43
人家被豬追,

01:35:44 - 01:35:45
所以跳到你家的庭院,

01:35:45 - 01:35:46
你說你被豬追幹我屁事喔,

01:35:46 - 01:35:48
你把人家打出去,可不可以?

01:35:48 - 01:35:49
不可以啊。

01:35:49 - 01:35:52
因為緊急避難的危難不包括合法行為嘛，

01:35:52 - 01:35:52
對不對？

01:35:52 - 01:35:53
最後，

01:35:53 - 01:35:54
啊對，緊急避難可不可以緊急避難？

01:35:54 - 01:35:55
當然不可以啊,

01:35:55 - 01:35:56
知道吧？

01:35:56 - 01:35:57
所以我們說，

01:35:57 - 01:36:00
交錯四種排列組合下來的結果都是什麼？

01:36:00 - 01:36:00
來，

01:36:00 - 01:36:01
帶各位看幾個題目。

01:36:23 - 01:36:24
來第11頁，

01:36:25 - 01:36:27
我們來看一下那個題目本11頁。

01:36:27 - 01:36:32
其實11頁的第18題跟第11頁的第15題啊，

01:36:32 - 01:36:33
根本就一樣。

01:36:34 - 01:36:35
就根本就一樣

01:36:35 - 01:36:38
就百萬重機跟數十萬的高級公路車

01:36:38 - 01:36:39
就根本是一樣的東西。

01:36:40 - 01:36:41
我們拆一來看

01:36:41 - 01:36:42
就都一樣啦

01:36:42 - 01:36:42
差不多。

01:36:43 - 01:36:44
我們就看18題好了。

01:37:16 - 01:37:16
好,

01:37:17 - 01:37:18
那個18題啊,

01:37:18 - 01:37:21
甲把他車由乙推倒在地,

01:37:21 - 01:37:22
讓乙多處挫傷,

01:37:22 - 01:37:25
所以甲該當的傷害罪,

01:37:25 - 01:37:26
沒有疑問,

01:37:26 - 01:37:27
傷害罪一定該當,

01:37:27 - 01:37:29
不用花太多篇幅去寫

01:37:29 - 01:37:30
知道嗎？

01:37:30 - 01:37:31
一定該當喔。

01:37:32 - 01:37:32
好，

01:37:32 - 01:37:33
那傷害罪該當的話，

01:37:33 - 01:37:34
在違法性這邊，

01:37:34 - 01:37:36
這裡可不可以主張緊急避難？

01:37:36 - 01:37:38
甲面臨什麼危難？

01:37:38 - 01:37:40
百萬重機要倒了，

01:37:40 - 01:37:42
倒下去這個重機如果閃掉的話，

01:37:42 - 01:37:45
好幾十萬的財產損失嘛。

01:37:45 - 01:37:50
所以甲面臨到的一個財產法益上面的急迫危難。

01:37:51 - 01:37:53
而甲的避難行為呢，

01:37:53 - 01:37:55
是犧牲人家的身體。

01:37:56 - 01:37:58
為了身體保護財產，

01:38:00 - 01:38:00
一涵品有沒有過？

01:38:01 - 01:38:04
我抱歉為了財產，對為了身體去犧牲別人財產，反含品沒有過嘛，對不對？

01:38:06 - 01:38:07
那你可額外補充一個點。

01:38:08 - 01:38:12
這裡會不會有這個法益侵害的總量的問題？

01:38:14 - 01:38:17
這裡的財產確實是一個很昂貴的財產，上百萬沒有錯。

01:38:18 - 01:38:22
可是這裡犧牲的身體，你覺得是顯然輕微的身體嗎？

01:38:22 - 01:38:24
不是，多處挫傷。

01:38:25 - 01:38:29
如果只是說，什麼手臂一處瘀青，那或許可以講。

01:38:30 - 01:38:33
加入量的觀點之後，是微不足道。

01:38:33 - 01:38:37
可是這一題多處挫傷，你想被重擊壓多痛啦。

01:38:38 - 01:38:40
身體會傷成什麼樣子，這沒有很輕。

01:38:40 - 01:38:41
所以我們會說。

01:38:44 - 01:38:49
這一題當中，就算我們納入法益侵害的總量的觀點去判斷，

01:38:50 - 01:38:51
依然怎麼樣？

01:38:51 - 01:38:52
不含平，知道嗎？

01:38:52 - 01:38:54
所以這一題是必然過當，OK喔，這一題依然是必然過當。

01:39:54 - 01:39:56
再來,14頁第41題,我們看一下。

01:40:34 - 01:40:38
那個偷取別人龍眼這一題,這一題我覺得寫得還不錯。

01:40:39 - 01:40:48
我們記得喔,當一個題目考到正當防衛的時候,如果題目裡面同時問到防衛者跟侵害者的刑責。

01:40:49 - 01:40:50
我們記得先寫誰?

01:40:51 - 01:40:52
侵害者。

01:40:52 - 01:40:53
知道嗎？

01:40:53 - 01:40:59
一定是先寫侵害人，為什麼？因為我們要先確認侵害人的行為不具有不法性。

01:40:59 - 01:41:02
防衛者的部分，你才寫得下去。

01:41:03 - 01:41:03
瞭解嗎？

01:41:03 - 01:41:12
再講一次喔，一個涉及到正當防衛的考題，如果題目當中同時問到防衛者跟侵害人的話。

01:41:13 - 01:41:14
我們要先寫誰？

01:41:14 - 01:41:15
先寫侵害人，知道吧？

01:41:15 - 01:41:20
確認侵害人的行為是不法的，防衛者的部分，我們才寫得下去喔。

01:41:20 - 01:41:21
好，所以啊

01:41:23 - 01:41:24
假偷摘

01:41:24 - 01:41:25
人家龍眼，這裡涉及竊盜罪。

01:41:29 - 01:41:30
我題目裡面

01:41:30 - 01:41:30
特別說。

01:41:32 - 01:41:35
龍眼長出牆外。

01:41:35 - 01:41:36
為什麼特別跟你講這個東西？

01:41:38 - 01:41:39
因為沒有加重竊盜罪。

01:41:40 - 01:41:41
我跟你們說啊，因為

01:41:41 - 01:41:49
如果龍眼在牆裡面，假的手很賤啊，伸過人家的牆去抓那個龍眼來吃。

01:41:49 - 01:41:51
那個會變加重竊盜喔。

01:41:51 - 01:41:54
毀壞門窗牆垣安全設備，321第二款，那個會變加重喔，知道嗎？

01:41:54 - 01:41:57
會變加重，這一題沒有，所以這一題它是普通竊盜。

01:42:00 - 01:42:00
而已。

01:42:02 - 01:42:04
然後來偷吃人家一顆龍眼，

01:42:05 - 01:42:07
又在考這個東西，可罰的違法性。

01:42:08 - 01:42:14
所以可罰的違法性雖然是一個80年代的爭議，但是現在的考試其實還是會出。

01:42:15 - 01:42:16
偷人家一顆龍眼,

01:42:16 - 01:42:18
一顆龍眼多少錢?

01:42:18 - 01:42:20
對，我記得這一題我上次口頭跟各位講過啊。

01:42:21 - 01:42:22
你去水果攤買龍眼,

01:42:22 - 01:42:24
說老闆我買一顆就好,

01:42:24 - 01:42:25
一顆算我多少錢?

01:42:25 - 01:42:28
老闆一定會說，那你要吃一顆我請你吃好不好?

01:42:29 - 01:42:31
這哪有人在算一顆的，對不對?

01:42:31 - 01:42:37
所以這裡的話呢，在違法性的部分，你要探討說這裡會不會認為是一個可罰的違法性欠缺，

01:42:37 - 01:42:38
會遇到這個問題啊。

01:42:38 - 01:42:40
可罰的違法性的欠缺。

01:42:40 - 01:42:41
好。

01:42:42 - 01:42:44
那再來，括號二，乙的部分。

01:42:45 - 01:42:48
乙，這裡涉及到的是傷害罪。

01:42:48 - 01:42:50
去，你看乙去

01:42:51 - 01:42:52
打人家的巴掌嘛,

01:42:53 - 01:42:54
造成甲嘴角受傷。

01:42:54 - 01:42:55
乙這裡涉及傷害罪。

01:42:56 - 01:42:58
一樣，構成要件該當。

01:42:59 - 01:43:01
違法性，乙可不可以主張正當防衛？

01:43:02 - 01:43:03
一定不可以。

01:43:03 - 01:43:04
為什麼？

01:43:04 - 01:43:05
兩個理由。

01:43:05 - 01:43:08
第一個是這樣，因為正當防衛要對現在不法侵害。

01:43:09 - 01:43:16
第一個你可以說，假設你認為甲偷龍眼是欠缺可罰的違法性而不罰的話。

01:43:17 - 01:43:18
那甲的行為合法喔,

01:43:18 - 01:43:20
甲合法乙怎麼正當防衛？

01:43:20 - 01:43:21
瞭解吧？

01:43:21 - 01:43:22
這是第一個問題嘛。

01:43:23 - 01:43:25
好，再來，就算你說甲的行為不法，

01:43:25 - 01:43:28
題目裡面是不是說甲都吃完要走掉的?

01:43:28 - 01:43:30
吃完走掉你追打人家幹什麼?

01:43:31 - 01:43:32
那個不叫防衛，那個叫報復。

01:43:33 - 01:43:36
所以就算你說甲的行為是不法好了，

01:43:36 - 01:43:37
但怎麼樣?

01:43:37 - 01:43:40
甲都吃完要走了，那個侵害都既遂也終了啦。

01:43:41 - 01:43:42
他也不是現在侵害，

01:43:42 - 01:43:45
他是過去的侵害，也沒得防衛，OK吧？

01:43:45 - 01:43:47
所以這一題的架構大概長這個樣子，

01:43:47 - 01:43:48
OK喔？

01:43:49 - 01:43:53
所以以後我在講解題目的時候,有些比較簡單的我就口頭講,

01:43:54 - 01:43:56
有些比較多的,我就會寫這樣的架構,

01:43:56 - 01:44:00
所以同學你在自己練習的話,就是

01:44:00 - 01:44:01
照這個架構下去寫,知道嗎,這個有些太難的。

01:44:04 - 01:44:05
不太難了,應該是說有些不是考點的,我們就帶過,不要寫太多。

01:44:10 - 01:44:11
好，題目我們看到這邊。

01:44:12 - 01:44:14
等一下等一下，是不是還有一題要講？

01:44:18 - 01:44:19
等一下，我看一下。

01:44:36 - 01:44:37
沒有沒有，沒事，就容忍這一題。

01:44:38 - 01:44:43
好，接下來我們來看到175、176頁，我們來看到其他的主確法是由。

01:44:44 - 01:44:47
這裡啊,首先第一個來看到依法令行為。

01:44:48 - 01:44:53
主張違法是由最難最複雜的兩個二三個二四我們都講完了。

01:44:53 - 01:44:56
剩下幾種相對簡單,我們就輕鬆來聽。

01:44:56 - 01:44:57
剩下幾種。

01:44:58 - 01:45:00
接著第四節叫依法令的行為。

01:45:01 - 01:45:02
誒,不對,又要下課了。

01:45:03 - 01:45:04
差點忘記時間,是等一下再說好了。

01:45:05 - 01:45:07
之前真的太習慣了,比如說上一個半小時,我們休息一下。

01:45:08 - 01:45:10
等一下我們再來看依法令行為。

01:45:17 - 01:45:20
好,我們接著來看到依法令的行為。

01:45:21 - 01:45:27
我標題的註釋這邊有講，依法令行為的種類很多，所以我們這邊呢只挑其中重要的來說。

01:45:27 - 01:45:30
好，首先第一種重要的依法令行為呢。

01:45:30 - 01:45:31
這個叫做自助行為。

01:45:32 - 01:45:33
這個在民法上你們可能會學到。

01:45:34 - 01:45:37
但以我的經驗，民總通常教不到這一塊。

01:45:37 - 01:45:38
真的啦。

01:45:38 - 01:45:40
以前我大一在學民總的時候。

01:45:40 - 01:45:42
我印象中。

01:45:43 - 01:45:47
民總能好好的把消滅時效跟除斥期間講完就不錯了。

01:45:47 - 01:45:49
一般大一應該是上不到這一塊。

01:45:49 - 01:45:50
我記得應該是這樣了。

01:45:50 - 01:45:53
所以沒關係，這個就由刑法這邊來講。

01:45:55 - 01:45:57
還記得以前我大一的民總老師。

01:45:57 - 01:45:59
讓我印象非常的深刻。

01:46:00 - 01:46:00
喔，說會不小心講到他，真的啊？

01:46:02 - 01:46:05
我大一念文化[redacted]　,那我大一的民總老師呢,他就是那個,是釋字737號解釋的申請人。

01:46:11 - 01:46:12
叫賴素如。

01:46:12 - 01:46:13
各位聽過這個人吧?

01:46:14 - 01:46:17
以前士林北投的議員,後來涉貪被抓去關。

01:46:17 - 01:46:18
真的我大一民總老師是他。

01:46:19 - 01:46:23
這個，對，他為我們刑事訴訟貢獻了重要的里程碑。

01:46:23 - 01:46:27
這個沒有他的話，我們的刑事訴訟機押審查程序辯護人是沒有否決權的。

01:46:27 - 01:46:31
他，他對我們的這個被告的人權非常的重要。

01:46:31 - 01:46:34
這個，好了，我這邊講自助行為。

01:46:35 - 01:46:37
自助行為這個東西是這樣子。

01:46:37 - 01:46:39
你看喔，民法的條文這麼說。

01:46:40 - 01:46:41
為保護自己的權利，

01:46:41 - 01:46:46
對於他人的自由或財產加以拘束、壓制或毀損者，

01:46:46 - 01:46:47
不負責任之責，

01:46:47 - 01:46:50
但以不及受法院或其他有關機關的援助，

01:46:50 - 01:46:52
並非於及時為之，

01:46:52 - 01:46:55
則請求權就不得實行或實行有困難者為限。

01:46:56 - 01:46:57
這個叫做自助行為。

01:46:58 - 01:46:59
我跟各位來說。

01:47:01 - 01:47:04
自助行為這個東西啊，要件上認定是這樣子。

01:47:05 - 01:47:09
因為我們說權力原則上不可以自力救濟。

01:47:09 - 01:47:10
為什麼？

01:47:11 - 01:47:11
那你講嘛。

01:47:12 - 01:47:15
權力如果可以自力救濟的話，會有什麼問題？

01:47:15 - 01:47:19
第一個會回到原始時代，叢林法則，誰的拳頭大，誰就贏了，第一個是這樣。

01:47:20 - 01:47:25
再來第二個，因為權力如果可以自力救濟的話，那不是會有球員兼裁判的疑慮嗎？

01:47:26 - 01:47:28
他一定是寬鬆的判斷這一法的要件嘛。

01:47:28 - 01:47:32
所以我們的權力，原則上是禁止自力救濟。

01:47:32 - 01:47:34
自助行為就是這樣的例外。

01:47:36 - 01:47:37
我們的條文說，如果說

01:47:38 - 01:47:39
這個權力，當下不去救濟，

01:47:41 - 01:47:44
將來就會無法實現的話，好，OK。

01:47:44 - 01:47:49
這種情況例外地讓人民允許對權力做自力救濟的行為。

01:47:50 - 01:47:52
這個東西呢，叫做自助行為。

01:47:53 - 01:47:57
好，所以我們說，自助行為，我們可以從幾個方面來講。

01:47:59 - 01:48:00
梳理。

01:48:00 - 01:48:00
課本上講的案例，幾乎就是課本上說的，你在機場遇到你的債務人，他買了一張單程機票要移民了，課本上永遠都舉這個案例，但這個案例未免太不常見了，所以我就講一個日常生活當中比較有可能會發生的案例，你們想哦。

01:48:16 - 01:48:20
你才剛把車停在路邊的白色停車格當中。

01:48:20 - 01:48:25
結果竟然被一個冒失的老人騎著電動代步車撞上去。

01:48:25 - 01:48:29
那個老人把你的保險桿給你的…

01:48:30 - 01:48:32
這個門啊，都刮壞了。

01:48:32 - 01:48:36
他騎那個電動代步車，撞壞了你停在路邊的車。

01:48:36 - 01:48:40
而這個老人撞壞你的車之後，他騎著電動代步車要跑了喔。

01:48:41 - 01:48:47
你為了避免他跑掉，所以你衝上前去，趕快把他的電動代步車的鑰匙拔掉。

01:48:47 - 01:48:49
然後通知警方起來處理。

01:48:50 - 01:48:52
這樣的情況就可以主張自助行為。

01:48:54 - 01:48:55
你注意我這個案例。

01:48:56 - 01:48:59
我為什麼特別講是騎著電動代步車的老人。

01:49:00 - 01:49:00
我

01:49:00 - 01:49:02
為什麼不講一般的機車騎士。

01:49:02 - 01:49:04
當然不是我其實老人啊,不是啊。

01:49:04 - 01:49:05
這是有意義的。

01:49:06 - 01:49:09
因為如果只是一般的機車騎士或汽車駕駛人的話。

01:49:10 - 01:49:10
這個

01:49:11 - 01:49:13
機車汽車有車牌。

01:49:13 - 01:49:15
你沒有必要去把它擋下來。

01:49:16 - 01:49:17
你機車牌號報警不就好了。

01:49:18 - 01:49:18
對啊。

01:49:20 - 01:49:21
我被人撞過啊。

01:49:22 - 01:49:24
我又有一次開車在亞東醫院那邊。

01:49:24 - 01:49:27
那邊算土城跟板橋的交界,對，就亞東醫院那邊。

01:49:28 - 01:49:29
我開的好好的啊。

01:49:30 - 01:49:33
但是我車速不快啊,我開在最外側,前面紅燈,我那時候大概2、30公里而已。

01:49:34 - 01:49:36
突然一個阿伯上鬼切。

01:49:36 - 01:49:38
就從最外側鬼切出來,我根本閃不掉。

01:49:39 - 01:49:41
他直接撞上我車子的右前方。

01:49:42 - 01:49:44
而且那個歐巴桑挺很敢,超好,他沒有倒喔。

01:49:45 - 01:49:46
對,他沒有倒。

01:49:47 - 01:49:50
然後我右前方被撞啊,反而我自己嚇得跟什麼一樣,他沒有倒。

01:49:51 - 01:49:54
然後到前面紅燈,我說你撞到我了。

01:49:54 - 01:49:55
他說啊，拍誰拍誰。

01:49:55 - 01:49:56
然後綠燈他人就跑掉了。

01:49:57 - 01:49:59
當下我趕快拍下他的車，我報警處理。

01:50:01 - 01:50:01
我以前被撞過啊。

01:50:01 - 01:50:02
後來

01:50:03 - 01:50:04
被撞到當下感覺就是

01:50:05 - 01:50:08
我買了那麼多年的保險，終於錢沒有白繳。

01:50:09 - 01:50:10
因為後來我保險桿直接換一條

01:50:10 - 01:50:12
又前面的鋁圈我也換一顆

01:50:12 - 01:50:13
蠻超值的啦

01:50:13 - 01:50:16
就蠻大方的，直接給我換新的。

01:50:17 - 01:50:22
所以我歷史就是說，如果你遇到一個人肇事逃逸，對方的車輛是有車牌的

01:50:23 - 01:50:25
那你沒有必要去攔他嘛

01:50:25 - 01:50:27
你報警記他車牌就好了，對不對

01:50:28 - 01:50:29
我會講老人的電動代步車

01:50:29 - 01:50:31
就是因為他沒有車牌啊。

01:50:31 - 01:50:34
那沒有車牌的話，你當下沒有把他擋住

01:50:34 - 01:50:36
他日後跑了，你怎麼追呀？

01:50:37 - 01:50:42
你不要跟我說警察可以透過路口監視器，一一調出那個老人住哪裡。

01:50:42 - 01:50:44
你知道路口監視器也常壞掉嗎？

01:50:44 - 01:50:46
萬一中間有一個斷點，那後面就找不到了

01:50:47 - 01:50:53
而且萬一老人住在這種社區大樓，這一個大社區裡面300多戶

01:50:53 - 01:50:54
他是哪一戶啦？

01:50:54 - 01:50:54
你怎麼找？

01:50:54 - 01:50:54
對不對？

01:50:54 - 01:50:59
所以這樣的情況,如果你當下不把這個老人的行動攔阻下來的話

01:50:59 - 01:51:02
日後你跟誰求償,根本就找不到

01:51:02 - 01:51:05
所以這種情況就可以主張自救行為

01:51:05 - 01:51:07
所以你把這個老人的鑰匙拔起來,然後不能走

01:51:07 - 01:51:10
雖然你可能該當的剝奪行動自由罪

01:51:10 - 01:51:13
但是呢，你可以依照自助行為而阻卻違法。

01:51:13 - 01:51:14
好

01:51:14 - 01:51:17
再來第二個，叫做父母的親權跟懲戒權。

01:51:18 - 01:51:22
我們民法說呢，父母對未成年子女有保護教養的權利義務

01:51:22 - 01:51:24
那1085條說，父母可以在必要的範圍之內

01:51:24 - 01:51:28
懲戒他的子女，這個是父母的親權跟懲

01:51:28 - 01:51:30
戒權，行使上幾個限制。

01:51:33 - 01:51:36
第一個呢，手段要合理而不過當。

01:51:37 - 01:51:38
這個我前面講過了喔

01:51:39 - 01:51:42
所有的阻卻違法是要成立

01:51:42 - 01:51:45
手段都不能過當，這個是必然的

01:51:45 - 01:51:48
所有的主法是有手段都不能過當

01:51:48 - 01:51:51
為什麼只有2324有過當的解面，為什麼別條沒有

01:51:52 - 01:51:55
因為2324具有緊急的性質啊

01:51:55 - 01:51:58
那種東西的過當，我們覺得值得同情嘛

01:51:59 - 01:52:00
那反觀21的

01:52:00 - 01:52:01
二，它有沒有這個性質？

01:52:01 - 01:52:02
那過渡到什麼好解？

01:52:02 - 01:52:02
對不對？

01:52:02 - 01:52:03
所以第一個，

01:52:03 - 01:52:04
手段不能過當喔。

01:52:04 - 01:52:05
再來第二個，

01:52:05 - 01:52:09
只能對未成年子女為之喔。

01:52:10 - 01:52:12
這個牽涉到我們法條很妙的地方，

01:52:12 - 01:52:13
你看條文這麼說。

01:52:15 - 01:52:16
1084,1085。

01:52:17 - 01:52:19
我以前學親屬篇就記得這個東西。

01:52:20 - 01:52:21
你看1084第二項說，

01:52:21 - 01:52:23
父母對誰有保護教養的權利義務？

01:52:23 - 01:52:25
未成年子女。

01:52:26 - 01:52:28
然後父母可以在必要的範圍之內懲戒什麼呢？

01:52:28 - 01:52:30
懲戒他們的子女。

01:52:31 - 01:52:32
沒有寫未成年哦。

01:52:33 - 01:52:35
所以父母可以懲戒他們的成年子女，

01:52:35 - 01:52:36
是這個意思嗎？

01:52:37 - 01:52:38
我回到家，

01:52:38 - 01:52:39
跟我爸吵架，

01:52:39 - 01:52:40
我爸覺得我不聽話，

01:52:40 - 01:52:41
他可以痛打我一頓，

01:52:41 - 01:52:43
然後他卻違法不成罪。

01:52:44 - 01:52:45
聽起來是不是覺得很荒謬？

01:52:45 - 01:52:46
我都幾歲了，

01:52:46 - 01:52:47
我爸還可以打我。

01:52:47 - 01:52:48
所以跟各位說啊，

01:52:49 - 01:52:51
我們民法的條文這麼定。

01:52:52 - 01:52:53
雖然有親屬法的學者說,

01:52:54 - 01:52:54
對,

01:52:54 - 01:52:54
沒有錯,

01:52:54 - 01:52:56
父母可以懲戒他的成年子女。

01:52:57 - 01:52:58
可是這個說法真的很怪。

01:52:59 - 01:53:41
我以前有跟各位講過，

01:53:41 - 01:53:43
如果你說父母可以懲戒成年子女，

01:53:44 - 01:53:45
這個叫中華文化的概念啊，

01:53:45 - 01:53:48
中華文化沒有什麼人格獨立這回事啦。

01:53:49 - 01:53:49
真的啊。

01:53:49 - 01:53:50
中華文化沒有這種概念。

01:53:51 - 01:53:53
就在中華文化裡面，

01:53:53 - 01:53:55
我不知道有沒有跟你們講過這件事。

01:53:56 - 01:53:57
中華文化講這種孝順，

01:53:57 - 01:53:58
孝道。

01:53:58 - 01:54:00
身體髮膚受之父母什麼的。

01:54:00 - 01:54:02
推薦他看過一本書，他覺得非常的感動。

01:54:03 - 01:54:03
他覺得很好看。

01:54:04 - 01:54:06
那本書的作者叫做王伯奇，

01:54:06 - 01:54:08
早期的一位民法學者叫王伯奇。

01:54:10 - 01:54:11
那本書的名字叫什麼啊？

01:54:13 - 01:54:15
近代法律思潮與中國固有文化，

01:54:15 - 01:54:16
好像是這個名詞吧？

01:54:16 - 01:54:17
你們上網找應該有，

01:54:17 - 01:54:20
王伯奇先生寫的《近代法律思潮與中國固有文化》。

01:54:21 - 01:54:23
呃，李老師說那本書他覺得看得非常感動。

01:54:24 - 01:54:25
我聽老師說，

01:54:25 - 01:54:26
真的那麼好看嗎？

01:54:26 - 01:54:27
我去圖書館借，

01:54:27 - 01:54:27
一看，

01:54:28 - 01:54:28
哇賽,

01:54:28 - 01:54:29
這本書寫得好棒。

01:54:30 - 01:54:30
對,

01:54:30 - 01:54:31
他就是在批評,

01:54:31 - 01:54:32
也不能說批評啦,

01:54:32 - 01:54:35
就是講說傳統那個中華文化有什麼問題

01:54:35 - 01:54:38
那傳統中華文化這種講求家庭和諧啊

01:54:38 - 01:54:40
講求眾人的人際關係的看法

01:54:40 - 01:54:42
他跟我們現代的法治精神

01:54:42 - 01:54:44
強調個人的人格獨立

01:54:44 - 01:54:45
中間的矛盾點在哪裡？

01:54:45 - 01:54:46
那本書寫得非常好。

01:54:48 - 01:54:48
好。

01:54:48 - 01:54:49
我就說啊。

01:54:49 - 01:54:52
雖然有民法親屬篇的學者會說，

01:54:52 - 01:54:54
對成年子女也可以懲戒,

01:54:54 - 01:54:56
可是我們刑法不會這樣採喔,

01:54:56 - 01:54:59
因為如果你說父母可以懲戒成年子女的話,

01:55:00 - 01:55:03
父母懲戒成年子女要怎麼樣合理而不過當？

01:55:04 - 01:55:05
我超難想像。

01:55:06 - 01:55:06
對啊,

01:55:06 - 01:55:07
你說我爸可以打我,

01:55:07 - 01:55:08
把我打傷也OK,

01:55:08 - 01:55:09
合理不過分,

01:55:09 - 01:55:10
我真的無法想像,

01:55:11 - 01:55:12
所以刑法學者會說，

01:55:13 - 01:55:15
父母對子女的懲戒權，

01:55:15 - 01:55:18
應該只限於對未成年子女，

01:55:19 - 01:55:20
那才有可能合理不過當。

01:55:21 - 01:55:23
德國學說也是這樣說的。

01:55:23 - 01:55:23
知道嗎？

01:55:24 - 01:55:26
所以對成年子女沒有懲戒權。

01:55:26 - 01:55:27
好，

01:55:27 - 01:55:28
接著我們翻過來第三點，

01:55:28 - 01:55:31
來看到最常見的一種現行犯的逮捕。

01:55:33 - 01:55:35
在所有的依法令行為當中,

01:55:35 - 01:55:38
考試最常出現的就是這個東西,

01:55:38 - 01:55:40
現行犯逮捕。

01:55:41 - 01:55:41
這四種裡面,

01:55:42 - 01:55:43
最常考這個東西。

01:55:43 - 01:55:44
現行犯逮捕

01:55:44 - 01:55:44
好

01:55:44 - 01:55:45
我們來看條文怎麼說。

01:55:48 - 01:55:48
刑訴88說啊

01:55:49 - 01:55:49
現行犯不問

01:55:50 - 01:55:52
不問何人得進行逮捕，

01:55:52 - 01:55:54
所以每個人都可以逮現行犯。

01:55:55 - 01:55:55
那第二項他說啊，

01:55:56 - 01:56:00
犯罪在實施中或實施後即

01:56:00 - 01:56:02
立即發覺者為現行犯。

01:56:02 - 01:56:04
時中之後才發覺。

01:56:04 - 01:56:06
然後第三項說有左列,

01:56:06 - 01:56:08
就下列情形，以現行犯論。

01:56:08 - 01:56:11
第一個叫做被追呼為犯人。

01:56:12 - 01:56:15
第二個叫做因為持有兇器、贓物或其他的文件。

01:56:15 - 01:56:18
或在身體衣服等處留有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者。

01:56:18 - 01:56:21
第三項這個叫做準現行犯，

01:56:21 - 01:56:22
準現行犯。

01:56:24 - 01:56:25
那個第三項啊，

01:56:25 - 01:56:27
我記得以前我看過一個爭議。

01:56:27 - 01:56:28
你看說他無聊還是有趣？

01:56:29 - 01:56:30
你看那個第三項的第一款，

01:56:31 - 01:56:35
他說準現行犯有一種情況叫做被追呼為犯人。

01:56:36 - 01:56:37
你們想像那個畫面，

01:56:38 - 01:56:40
路伯言在前面跑。

01:56:41 - 01:56:44
後面一堆女生在喊著說抓變態

01:56:44 - 01:56:45
大概就這個畫面

01:56:46 - 01:56:47
腦中有畫面嗎，對不對？

01:56:47 - 01:56:49
那個光頭在前面跑，後面一堆女生說抓變態

01:56:50 - 01:56:51
這被追呼為犯人者

01:56:52 - 01:56:53
對啊,被追呼為犯人。

01:56:53 - 01:56:54
你知道以前的爭議是什麼嗎?

01:56:55 - 01:56:57
以前有人在爭，說那個追跟呼啊,

01:56:57 - 01:56:59
是擇一或是並存的要件。

01:57:00 - 01:57:01
真的啦。

01:57:01 - 01:57:03
你們去看林老師的行訴，早期有行訴還爭這個東西啊。

01:57:04 - 01:57:06
說追跟呼是要擇一還並存。

01:57:07 - 01:57:08
早期有人說要並存，

01:57:08 - 01:57:10
被追且被呼。

01:57:10 - 01:57:12
說兩個都要，被追且被呼。

01:57:13 - 01:57:15
啊如果你說要被追且被呼的話,

01:57:16 - 01:57:19
那如果路伯言去對那個坐輪椅的殘障人士行兇,

01:57:20 - 01:57:22
那他只能呼，他沒辦法追耶。

01:57:23 - 01:57:25
所以他那就不算現行犯,

01:57:25 - 01:57:26
很奇怪的對不對？

01:57:26 - 01:57:29
所以後來有人說要被追且被呼，

01:57:29 - 01:57:30
所以要是，

01:57:30 - 01:57:31
不是不是要且，

01:57:31 - 01:57:33
要或被追或被呼就夠了。

01:57:33 - 01:57:36
可是如果你想要被追或被呼，擇一就夠的話，

01:57:36 - 01:57:41
那，那一群小學生在公園玩警察抓小偷，

01:57:41 - 01:57:44
所以你就可以把那個扮小偷的小學生押去警局，

01:57:44 - 01:57:45
因為他被追呼為犯人，

01:57:45 - 01:57:46
是這樣嗎？

01:57:46 - 01:57:47
也很怪，對不對？

01:57:47 - 01:57:48
所以學者會說啦,

01:57:48 - 01:57:50
什麼擇一或並存不是重點啦,

01:57:50 - 01:57:53
重點是說在一般的情境之下,

01:57:54 - 01:57:57
那個人會不會讓一般人相信他是現行犯。

01:57:58 - 01:57:59
重點在這邊,

01:57:59 - 01:57:59
知道嗎？

01:57:59 - 01:58:00
所以這個是

01:58:01 - 01:58:03
性侵犯跟準性侵犯的認定。

01:58:03 - 01:58:04
好。

01:58:05 - 01:58:07
然後我跟同學講一個嘗試。

01:58:08 - 01:58:12
第二款說因持有兇器、贓物，那個贓物，我跟同學講。

01:58:14 - 01:58:16
行訴的贓物跟刑法的贓物認定不一樣。

01:58:17 - 01:58:19
這個你們上行訴一估計一定會跟你們說。

01:58:20 - 01:58:24
記得哦，行訴這一條贓物跟刑法349的贓物不一樣哦。

01:58:25 - 01:58:30
刑法349的贓物專指財產犯罪的所得。

01:58:31 - 01:58:35
是吧，刑法349條的贓物專指財產犯罪的所得。

01:58:36 - 01:58:42
所以如果有一天那個路伯言他去挖人家的墳墓，挖到一堆金銀珠寶陪葬品。

01:58:43 - 01:58:46
然後路伯言看到我就說，學長那個我挖到一堆陪葬品喔。

01:58:46 - 01:58:46
送你好不好？

01:58:46 - 01:58:48
我說我超喜歡陪葬品，我收下了。

01:58:49 - 01:58:50
這樣的話我會不會收受贓物？

01:58:51 - 01:58:51
沒有喔。

01:58:52 - 01:58:54
因為挖墳墓那個叫違反社會善良風俗的犯罪。

01:58:55 - 01:58:56
那不是財產犯罪，知道嗎？

01:58:56 - 01:59:01
所以刑法349條的贓物專指財產犯罪的所得。

01:59:02 - 01:59:03
可是行訴不是喔。

01:59:04 - 01:59:08
行訴這個條文的贓物，它是泛指一切的犯罪所得。

01:59:09 - 01:59:11
所以像貪汙的賄款是不是這個贓物？

01:59:12 - 01:59:12
是喔。

01:59:12 - 01:59:13
知道嗎？

01:59:13 - 01:59:13
是喔。

01:59:13 - 01:59:15
所以如果有一天你去市府辦事，

01:59:16 - 01:59:22
你發現市長室裡面放了好幾個茶葉罐，而且茶葉罐看起來裡面就不是茶葉，是一捆一捆的現金。

01:59:23 - 01:59:24
你可不可以逮捕市長？

01:59:25 - 01:59:25
可以喔。

01:59:26 - 01:59:26
知道吧，可以喔。

01:59:26 - 01:59:29
所以這個贓物跟行訴解釋是跟刑法解釋不一樣的。

01:59:30 - 01:59:32
好，這個是我們講性侵害的意義喔。

01:59:32 - 01:59:38
那性侵害的逮捕，除了要有逮捕行為之外，還要怎麼樣呢，還要解送檢警機關。

01:59:39 - 01:59:40
光是逮捕還不夠。

01:59:41 - 01:59:44
還要解送到檢警機關那邊去。

01:59:44 - 01:59:46
所以啊，這種主確法是有很特別。

01:59:47 - 01:59:48
他兩個都要做。

01:59:48 - 01:59:49
第一個要先逮捕。

01:59:50 - 01:59:50
第二個要解送。

01:59:51 - 01:59:52
你少做一個都不行。

01:59:53 - 01:59:57
所以比如說你逮到一個六鳥俠，你沒有送到警局，你反而去踹他的鳥，然後你就走了。

01:59:58 - 01:59:59
就不能主張違法。

01:59:59 - 01:59:59
知道嗎？

02:00:00 - 02:00:01
的主張違法，所以兩個動作。

02:00:03 - 02:00:05
因此啊，各位你會發現，

02:00:05 - 02:00:09
現行犯的逮捕跟正當防衛，

02:00:09 - 02:00:11
有沒有感覺他們會引起爭議？

02:00:11 - 02:00:12
有的時候啦，

02:00:13 - 02:00:15
六鳥案當然不會啦，因為對公共法益不能正當防衛嘛。

02:00:16 - 02:00:17
但比如說你想，

02:00:17 - 02:00:19
你看到有個小偷在偷東西，

02:00:20 - 02:00:21
你看到他在偷東西，

02:00:22 - 02:00:25
你就把他壓制在地，然後通知警方來處理。

02:00:26 - 02:00:29
這裡除了可以走現行犯逮捕之外，是不是也可以走正當防衛？

02:00:29 - 02:00:29
對，沒有錯。

02:00:30 - 02:00:32
這兩者確實有些時候會重疊，沒錯。

02:00:33 - 02:00:37
所以我跟你們說，現行犯的逮捕跟正當防衛，

02:00:37 - 02:00:40
如果感覺同時成立的話，你要寫哪一個？

02:00:41 - 02:00:45
當然主客法是有他們的優先順序，擇一成立就阻卻違法，對不對？

02:00:45 - 02:00:46
那你要寫哪一個？

02:00:46 - 02:00:47
你看題目的線索。

02:00:49 - 02:00:53
如果題目裡面有跟你說行為人進一步解送檢警機關的話，

02:00:54 - 02:00:56
那你就去寫現行犯逮捕。

02:00:56 - 02:01:00
如果題目沒有說到解送檢警的話，

02:01:00 - 02:01:01
你就寫正當防衛。

02:01:02 - 02:01:03
瞭解吧，因為那個是要件的問題。

02:01:03 - 02:01:06
題目沒有寫到解送進機關，而你還去寫現行犯逮捕的話，

02:01:08 - 02:01:11
那會很麻煩，因為要件過不去，瞭解吧？

02:01:11 - 02:01:15
所以這兩者如果發生重疊的時候，我們就擇一來寫，看題目給什麼線索。

02:01:15 - 02:01:18
我們就往有利的那邊去寫，知道嗎？

02:01:21 - 02:01:21
好。

02:01:21 - 02:01:23
所以這個現行犯逮捕的意義，

02:01:23 - 02:01:23
好。

02:01:23 - 02:01:24
接下來第二點，

02:01:24 - 02:01:26
抓錯人怎麼辦？

02:01:27 - 02:01:29
考試人喜歡考這個東西，

02:01:29 - 02:01:30
抓錯人怎麼辦？

02:01:30 - 02:01:33
今年的高考又考出這個東西了，

02:01:33 - 02:01:35
今年的高考又考出來的。

02:01:36 - 02:01:38
這個沒關係，這個是間接正犯的問題，

02:01:38 - 02:01:39
以後我們再說。

02:01:41 - 02:01:42
抓錯人怎麼辦？

02:01:43 - 02:01:43
好。

02:01:44 - 02:01:46
我舉一個我以前自己遇到的事，

02:01:47 - 02:01:49
還好沒有變成現行犯逮捕，

02:01:49 - 02:01:50
就差那麼一點點。

02:01:51 - 02:01:54
我以前大學的時候啊，發生過一些這樣的事，

02:01:55 - 02:01:55
我跟同學講過嘛，

02:01:55 - 02:01:57
我老家住在東湖。

02:01:57 - 02:01:59
我老家住在東湖，

02:01:59 - 02:01:59
這個，

02:02:00 - 02:02:02
內湖的東邊靠近汐止，叫東湖。

02:02:03 - 02:02:07
所以以後你們考上律師之後去律訓的地方，離我老家很近。

02:02:07 - 02:02:11
那律訓，你們知道吧，律訓在那個捷運湖州站。

02:02:11 - 02:02:13
那個行政執行署。

02:02:13 - 02:02:16
那個那個叫什麼，內湖分署還是什麼的，在在那個地方。

02:02:17 - 02:02:18
那個離我老家很近。

02:02:18 - 02:02:22
所以有的時候，我都會約律訓的同學出來吃個拉麵。

02:02:22 - 02:02:25
那邊有一家很好吃的拉麵店，律訓離我老家很近。

02:02:26 - 02:02:27
我老家住在東湖啦。

02:02:27 - 02:02:30
因為我老家離捷運站其實有一段路。

02:02:30 - 02:02:31
1.5公里。

02:02:31 - 02:02:33
那一段路走路20幾分鐘。

02:02:33 - 02:02:36
坐公車沒有比較快，因為公車十幾分鐘才一班。

02:02:37 - 02:02:40
所以我以前大學的時候啊，大學後半文湖線通車嘛。

02:02:40 - 02:02:42
我都騎腳踏車去捷運站。

02:02:42 - 02:02:45
我以前都這樣，我短時間都騎腳踏車去捷運站。

02:02:46 - 02:02:49
那有一次啊，大學最後一年。

02:02:49 - 02:02:52
當時晚上大概10點多，我下課回到家。

02:02:53 - 02:02:57
到了捷運站，我一如往常地拿車鎖，要開啟我的腳踏車。

02:02:58 - 02:03:04
結果我把車鎖插進鑰匙孔之後啊，我轉了好幾下，奇怪，怎麼卡住轉不開。

02:03:04 - 02:03:08
用力一轉啊，慘了，鑰匙斷在車鎖裡面。

02:03:08 - 02:03:10
我傻眼，怎麼辦，鑰匙斷在車鎖裡面呢。

02:03:11 - 02:03:13
啊我，我要怎麼騎回家啊。

02:03:13 - 02:03:14
鎖就沒有打開啊，我怎麼辦？

02:03:15 - 02:03:16
所以當時我想，糟糕。

02:03:17 - 02:03:19
對啊，那我又是沒有備份鑰匙嗎？

02:03:19 - 02:03:22
我是不是隻能把車鎖破壞，我才回得了家了？

02:03:23 - 02:03:25
於是當時呢，我又回到了捷運站。

02:03:26 - 02:03:27
我就問站務員說，你有沒有那個

02:03:27 - 02:03:30
油壓鉗可以借我啊。

02:03:30 - 02:03:32
站務員露出了一點惶恐的樣子，

02:03:32 - 02:03:33
想說你要借這個東西幹嘛。

02:03:34 - 02:03:35
我就秀出我斷掉的鑰匙。

02:03:35 - 02:03:37
我說我車子停在樓下，鑰匙斷了。

02:03:39 - 02:03:41
我要把車鎖解開，我才能回家啊。

02:03:41 - 02:03:44
所以我就說有沒有油錢可以借我。

02:03:44 - 02:03:46
站務員說油錢是沒有啦。

02:03:46 - 02:03:47
有『老虎錢』你要不要？

02:03:48 - 02:03:50
我說可以啊,老虎錢中間有一個刀片啊,可以剪啊。

02:03:51 - 02:03:54
於是我又押了證件,跟他借了老虎錢,要去下面剪車鎖。

02:03:55 - 02:03:58
那時候大概10月11月,天氣有點涼。

02:03:59 - 02:04:00
我拿了一把老虎

02:04:00 - 02:04:02
虎鉗,晚上大概10點半,

02:04:02 - 02:04:05
在捷運東湖站旁邊的腳踏車停車處

02:04:05 - 02:04:07
在那邊剪那個腳踏車的車鎖。

02:04:07 - 02:04:08
欸，不好剪欸

02:04:09 - 02:04:10
剪得滿身大汗欸。

02:04:10 - 02:04:13
剪了幾分鐘之後突然有一點，好像有一點成果了。

02:04:14 - 02:04:16
可是我看著周遭的環境,

02:04:16 - 02:04:18
再看看我自己在做的動作,

02:04:18 - 02:04:20
我真的越想越不對欸。

02:04:21 - 02:04:21
你們是路人,

02:04:22 - 02:04:22
你看到這個畫面,

02:04:23 - 02:04:24
你會覺得我是什麼人？

02:04:24 - 02:04:25
偷車賊，

02:04:26 - 02:04:28
對吧，就一臉偷車賊樣啦。

02:04:28 - 02:04:30
晚上10點多在那邊剪車鎖，

02:04:30 - 02:04:33
誰會想到我是車鎖壞掉啊？

02:04:33 - 02:04:34
沒有人想到。

02:04:34 - 02:04:35
我越想越不對欸，

02:04:35 - 02:04:37
我想說萬一我被扭送警局怎麼辦？

02:04:38 - 02:04:41
那東湖捷運站出來，派出所就在旁邊欸，

02:04:41 - 02:04:42
我被扭送怎麼辦？

02:04:42 - 02:04:44
想說算了算了，我不想做這種會讓人誤會的事。

02:04:45 - 02:04:46
我把老虎鉗換回去。

02:04:47 - 02:04:49
最後我走路回家，浪費了十幾分鐘。

02:04:50 - 02:04:50
各位，

02:04:51 - 02:04:52
這樣的案例當中，

02:04:53 - 02:04:55
假設我被當作是

02:04:57 - 02:04:59
偷車賊，被扭送警局，

02:04:59 - 02:05:03
那麼扭送我的人可不可以主張現行犯的逮捕而阻卻違法？

02:05:04 - 02:05:06
我跟你們說通說認為可以。

02:05:06 - 02:05:08
真的喔，通說認為可以喔。

02:05:08 - 02:05:11
因為通說覺得現行犯的逮捕它是一種強制處分。

02:05:12 - 02:05:14
那強制處分這種東西呢，

02:05:14 - 02:05:16
我們在行訴上就會知道，

02:05:16 - 02:05:20
強制處分這種東西啊，它都是那種形式上判斷。

02:05:21 - 02:05:24
只要外觀上這個人看起來像。

02:05:24 - 02:05:27
只要外觀上這個人看起來有犯的嫌疑，

02:05:27 - 02:05:28
他就是合法，

02:05:29 - 02:05:35
並不會因為事後發現這個強制處分是徒勞無功的，而反過來說這個強制處分不合法，知道嗎？

02:05:35 - 02:05:37
以後你們學行訴就會學到這個概念。

02:05:37 - 02:05:39
所以現行犯的逮捕也是啊。

02:05:39 - 02:05:47
多數說會覺得，因為現行犯逮捕往往發生在案件剛發生、兵荒馬亂現場一片混亂的時候，

02:05:47 - 02:05:51
如果你要求要抓對人才是合法逮捕的話，那誰敢逮捕？

02:05:52 - 02:05:52
對不對？

02:05:52 - 02:05:56
所以多數說覺得，只要在逮捕的當下，

02:05:57 - 02:06:00
這個人看起來像是

02:06:00 - 02:06:01
個現行犯

02:06:01 - 02:06:02
那就是合法逮捕

02:06:02 - 02:06:05
並不會因為事後發現他沒有犯罪而有所不同，知道嗎

02:06:05 - 02:06:07
所以多數說的看法是這樣哈

02:06:07 - 02:06:11
當下看起來他像是個竊賊，當我轉現行犯

02:06:12 - 02:06:13
那就是合法逮捕喔

02:06:14 - 02:06:15
所以剛剛我舉的案例

02:06:16 - 02:06:22
半夜和晚上10點多，我拿老虎鉗在警局旁邊剪腳踏車的車鎖

02:06:23 - 02:06:25
你覺得我外觀上看起來像不像偷車賊

02:06:25 - 02:06:26
根本超像啊，對不對

02:06:27 - 02:06:29
所以如果有人把我扭送警局的話

02:06:29 - 02:06:30
這是合法逮捕喔

02:06:30 - 02:06:31
知道嗎

02:06:31 - 02:06:31
這通說的看法

02:06:31 - 02:06:32
來我註釋有寫喔

02:06:33 - 02:06:34
反對說是李東茂老師的意見

02:06:35 - 02:06:38
有人說要真的抓對人才算，否則便容許苟且

02:06:40 - 02:06:42
有，有這個說法，但它是少數說

02:06:42 - 02:06:45
多數說都是怎麼樣，情勢判斷，OK嗎

02:06:46 - 02:06:48
多數說的主張，都認為這個東西是情勢判斷

02:06:49 - 02:06:50
它跟刑訴的概念有關啊

02:06:50 - 02:06:51
我們講刑訴也是嘛，比如說

02:06:51 - 02:06:52
那個搜索好了

02:06:54 - 02:06:59
我們刑訴那個131第一項的進行搜索

02:06:59 - 02:07:00
它不是有一款

02:07:00 - 02:07:01
是，是說什麼？

02:07:01 - 02:07:04
那個，有人在那裡犯罪，情況急迫，那

02:07:04 - 02:07:07
執法者就可以不用搜索票進去人家家裡搜嘛，對不對？

02:07:08 - 02:07:09
刑訴最喜歡考的嘛。

02:07:11 - 02:07:11
警察。

02:07:13 - 02:07:14
巡邏的時候

02:07:14 - 02:07:16
聽到那個屋子裡面有人在慘叫

02:07:17 - 02:07:19
警察覺得好像發生兇殺案

02:07:19 - 02:07:20
警察就破門而入

02:07:21 - 02:07:23
結果破門而入之後啊

02:07:23 - 02:07:23
才知道喔

02:07:23 - 02:07:26
原來是那對男女他們在打炮啊

02:07:26 - 02:07:28
那個打得太激烈了，所以那個聲音聽起來像殺人一樣

02:07:30 - 02:07:33
結果警察進去之後發現，這對男女打炮的時候有吸毒助興

02:07:33 - 02:07:35
旁邊放了一堆毒品

02:07:36 - 02:07:37
你一定聽過這種案例嘛，對不對？

02:07:38 - 02:07:40
所以那個搜索會不會變得不合法？

02:07:40 - 02:07:43
不會啊，因為當下聽起來就是有人在裡面犯罪啊，對不對？

02:07:43 - 02:07:45
所以現行犯逮捕也是一樣的思考，知道嗎？

02:07:45 - 02:07:47
強制處分這種東西喔。

02:07:47 - 02:07:48
當然我們是怎麼樣

02:07:49 - 02:07:50
程序要件嘛

02:07:50 - 02:07:50
當下有就OK嘛

02:07:51 - 02:07:52
你不會事後做判斷喔

02:07:53 - 02:07:53
好

02:07:53 - 02:07:55
所以喔，照多數的說法

02:07:55 - 02:07:57
現行犯逮捕，只要在當下

02:07:58 - 02:08:00
看起來那個人是

02:08:00 - 02:08:03
這個現行犯，他就是合法的逮捕，知道嗎？

02:08:03 - 02:08:06
所以接下來我講的話請同學注意喔。

02:08:07 - 02:08:12
所以有些同學會說，喔所以現行犯逮捕不會變誤想。

02:08:13 - 02:08:14
話不能這麼說啦。

02:08:15 - 02:08:19
我只能說，因為現行犯逮捕他是做這種程序情勢上的判斷。

02:08:20 - 02:08:25
所以他要變誤想，要變容許構成要件錯誤，很難，知道嗎？很難。

02:08:26 - 02:08:30
但不代表他一定不會變誤想。

02:08:31 - 02:08:32
不代表一定不會。

02:08:32 - 02:08:34
有沒有可能誤判？有啊。

02:08:34 - 02:08:37
就客觀上這個人他根本不像現行犯。

02:08:37 - 02:08:41
可是，情治人員就覺得他是現行犯。

02:08:42 - 02:08:43
有沒有可能？有啊，有可能啊。

02:08:43 - 02:08:43
你們想喔。

02:08:44 - 02:08:45
等一下5點下課。

02:08:46 - 02:08:47
我走去請大家搭捷運。

02:08:48 - 02:08:50
結果有路人把我壓制在地。

02:08:52 - 02:08:54
路人說要逮捕我，我說奇怪，我沒犯罪幹嘛逮捕我。

02:08:55 - 02:08:59
結果路人竟然說，我帶著墨鏡，然後穿著花襯衫，就一副很猥瑣的樣子。

02:09:00 - 02:09:02
看起來就是一副剛猥瑣完別人。

02:09:02 - 02:09:03
你是猥褻犯，跟我去警局一趟。

02:09:04 - 02:09:07
假設有路人這樣逮捕我，說我是個猥褻犯，要幫我抓去警局。

02:09:08 - 02:09:10
這種情況，是不是違法逮捕？

02:09:13 - 02:09:14
這種情況會不會變妄想？

02:09:15 - 02:09:15
當然會啊。

02:09:16 - 02:09:17
還是你們也覺得我這樣看起來很猥褻？

02:09:18 - 02:09:19
應該不會吧。

02:09:19 - 02:09:20
我又不是陸伯言。

02:09:21 - 02:09:24
如果陸伯言穿這樣被押去逮捕，我覺得合理啊，看起來就那麼猥褻，對不對？

02:09:24 - 02:09:26
我又不是陸伯言，所以，在這樣案例當中。

02:09:30 - 02:09:33
照通說的看法，當然會變成誤想，瞭解吧？

02:09:33 - 02:09:34
所以我說，通說的看法之下。

02:09:35 - 02:09:37
現行犯逮捕只是怎麼樣？他只是很難變誤想喔。

02:09:40 - 02:09:41
不是永遠不會喔，知道嗎？只是很難而已喔。

02:09:44 - 02:09:45
好。

02:09:45 - 02:09:47
下面這一題就是，我們來看一下。

02:10:17 - 02:10:18
這一題喔

02:10:19 - 02:10:22
雖然題目先問甲再問乙

02:10:22 - 02:10:24
但我剛跟各位說過了

02:10:24 - 02:10:27
在這種涉及阻卻違法事由的考題

02:10:28 - 02:10:32
如果題目裡面同時問到的防衛者跟侵害者的話

02:10:33 - 02:10:34
我們要先寫誰

02:10:35 - 02:10:36
先寫侵害人哦

02:10:36 - 02:10:38
所以這一題你第一個不要傻傻的先寫

02:10:39 - 02:10:40
先寫甲

02:10:41 - 02:10:41
不要喔

02:10:42 - 02:10:43
你要先寫乙，知道嗎

02:10:43 - 02:10:45
因為甲乙是正當防衛嘛

02:10:46 - 02:10:48
對啊，所以我們在想喔

02:10:48 - 02:10:51
涉及到正當防衛的考題，我們要先寫的是侵害者的喔

02:10:51 - 02:10:54
所以你要先確認乙的逮捕行為合不合法

02:10:54 - 02:10:58
因為後面我有附我的思考方向，所以我就不再寫黑板了喔

02:10:58 - 02:11:02
照多數的說法，乙會不會成立剝奪行動自由罪

02:11:02 - 02:11:02
不會

02:11:02 - 02:11:03
為什麼

02:11:03 - 02:11:07
因為當下那個人看起來確實像是個現行犯

02:11:07 - 02:11:09
所以乙是合法逮捕

02:11:09 - 02:11:10
好，那所以乙合法逮捕的話

02:11:11 - 02:11:12
假

02:11:13 - 02:11:14
可不可以正當防衛

02:11:15 - 02:11:16
當然不行啊

02:11:17 - 02:11:19
對啊，因為合法行為的相對人要忍受嘛

02:11:19 - 02:11:21
所以假當然不能正當防衛

02:11:22 - 02:11:23
假可不可以緊急避難

02:11:25 - 02:11:25
也不行，為什麼

02:11:25 - 02:11:27
因為我們剛說過基於法律秩序的一致性

02:11:29 - 02:11:31
合法行為的相對人要忍受

02:11:31 - 02:11:33
他當然不能正當防衛

02:11:33 - 02:11:35
當然也不可以緊急避難，都不可以，知道嗎

02:11:36 - 02:11:37
也不能緊急避難喔

02:11:37 - 02:11:38
所以這一題當中

02:11:40 - 02:11:40
假

02:11:40 - 02:11:41
為什麼被傷害罪

02:11:41 - 02:11:42
會

02:11:42 - 02:11:44
啊有人會說，啊可是假很可憐呢

02:11:45 - 02:11:46
有人會說，啊對啊

02:11:46 - 02:11:47
如果我沒有學過法律，我也會覺得

02:11:49 - 02:11:50
他應該要可以

02:11:51 - 02:11:52
緊急避難啊

02:11:52 - 02:11:55
也有人會這樣講啊，就說他應該可以正當防衛啊

02:11:55 - 02:11:56
所以這個誤認會變成什麼問題

02:11:58 - 02:11:59
就會變成是

02:11:59 - 02:11:59
那個那個

02:12:00 - 02:12:00
叫什麼？

02:12:01 - 02:12:02
才會變成是，呃，法律意識的欠缺

02:12:05 - 02:12:06
會變成這個問題，你知道嗎？

02:12:06 - 02:12:11
如果假自認為說我又沒犯罪，你憑什麼抓我

02:12:11 - 02:12:11
我反擊是正當的啊

02:12:11 - 02:12:13
如果假有這個認知

02:12:13 - 02:12:15
那就是16條不知法律

02:12:16 - 02:12:17
法律意識的欠缺

02:12:18 - 02:12:19
我提醒各位喔

02:12:19 - 02:12:20
我再講一次喔

02:12:20 - 02:12:25
如果當然題目沒有這樣說啦,但如果題目說假自認無辜

02:12:28 - 02:12:31
對啊,假自認無辜啊,假覺得說我沒犯罪你憑什麼抓我

02:12:31 - 02:12:33
假覺自己的反擊是合理正當的

02:12:33 - 02:12:35
這個不是誤想防衛喔

02:12:36 - 02:12:39
因為誤想防衛容許構成要素,那個是對事實的誤認,知道嗎？

02:12:40 - 02:12:43
假如果是覺得在法律上自己有權去反擊

02:12:44 - 02:12:46
那個叫16條的法意識欠缺

02:12:46 - 02:12:47
OK嗎？

02:12:47 - 02:12:48
這個提醒各位喔

02:12:49 - 02:12:51
好，所以這題照通說的看法就這樣喔

02:12:51 - 02:12:54
逮捕合法，所以相對人無從反擊

02:12:55 - 02:12:57
這一題你不要去寫誤想防衛

02:12:58 - 02:13:03
因為這一題明明有現行犯逮捕可以用，用這個東西就阻卻違法的

02:13:03 - 02:13:04
你不要再去寫正當防衛

02:13:05 - 02:13:08
你寫正當防衛，然後把它凹成誤想防衛，那個叫捨近求遠的寫法，知道嗎？

02:13:08 - 02:13:09
不要這樣寫喔

02:13:09 - 02:13:13
我們這一題直接用正當，用那個現行犯逮捕就解決囉

02:13:13 - 02:13:14
不要捨近求遠喔

02:13:15 - 02:13:16
好，這個我們看到這

02:14:00 - 02:14:01
叫權利，好吧

02:14:01 - 02:14:02
法律不罰人工流產,

02:14:02 - 02:14:05
不是說我看你很可憐，不忍心罰你，不是，

02:14:06 - 02:14:07
這個是權利，

02:14:07 - 02:14:08
好吧，它就是一種權利，

02:14:09 - 02:14:11
它並不是什麼看你可憐不罰你，不是喔。

02:14:11 - 02:14:12
人工流產是權利,

02:14:12 - 02:14:14
好吧,它是一種權利。

02:14:14 - 02:14:15
好,

02:14:16 - 02:14:18
反正啊,照現行法的規定,

02:14:19 - 02:14:22
實施人工流產的事由,它有這六款。

02:14:23 - 02:14:24
這六款我們大致歸納一下，

02:14:25 - 02:14:26
大概什麼樣情況可以人工流產？

02:14:27 - 02:14:29
這六款其實有一些共同特徵。

02:14:30 - 02:14:33
比如說有些事由是胎兒有缺陷，

02:14:34 - 02:14:36
或者有事實懷疑那個胎兒有缺陷。

02:14:36 - 02:14:37
比如說幾款？

02:14:38 - 02:14:38
你看，

02:14:40 - 02:14:43
1、2、4，有沒有？

02:14:44 - 02:14:47
1、2、4就是這個胎兒有問題或可能有問題嘛，

02:14:47 - 02:14:47
對不對？

02:14:48 - 02:14:49
再來，

02:14:53 - 02:14:53
三呢？

02:14:55 - 02:14:56
三是母體有問題啊，

02:14:56 - 02:14:57
對不對？

02:14:58 - 02:14:59
一二四是胎兒可能有問題嘛。

02:15:00 - 02:15:02
三是母體可能有問題嘛。

02:15:03 - 02:15:04
那五跟六呢？

02:15:05 - 02:15:08
五跟六是孕婦的心理狀況不適合。

02:15:09 - 02:15:10
五跟六是這樣,

02:15:11 - 02:15:13
五跟六孕婦的身體是健康的,

02:15:13 - 02:15:15
胎兒也是健康的,

02:15:15 - 02:15:19
可是五跟六的情況是，這種情況如果你逼那個孕婦生,

02:15:20 - 02:15:21
不太人道。

02:15:22 - 02:15:24
孕婦的心理不適合生小孩,

02:15:25 - 02:15:26
這個是五跟六。

02:15:27 - 02:15:28
比如說第五個是被性侵嘛,

02:15:28 - 02:15:31
第六個是其他的情況，比如說,

02:15:31 - 02:15:35
學生意外懷孕之類的，這個是第六款的情況。

02:15:36 - 02:15:37
所以啊，我跟各位講，

02:15:39 - 02:15:41
有些反墮胎的保守派,

02:15:42 - 02:15:44
他們在遇到墮胎的問題的時候很喜歡講一句話，

02:15:44 - 02:15:46
說胎兒是無辜的。

02:15:46 - 02:15:52
我跟你們講，胎兒是無辜的這句話，根本不足以用來否定人工流產的正當性。

02:15:53 - 02:15:58
因為我跟你們講，在所有人工流產的情況當中，胎兒一定都是無辜的。

02:15:58 - 02:15:59
真的啊。

02:16:00 - 02:16:01
不然你們自己想嘛。

02:16:03 - 02:16:05
孕婦懷的一個有唐氏症的胎兒。

02:16:08 - 02:16:12
這種情況的人工流產，一般人比較不會反對它的正當性。

02:16:13 - 02:16:14
你說胎兒不無辜？

02:16:15 - 02:16:17
無辜啊，超無辜啊，對吧？

02:16:17 - 02:16:18
還有啊。

02:16:19 - 02:16:20
再舉一種情況。

02:16:21 - 02:16:23
那個女生被性侵而懷孕。

02:16:24 - 02:16:25
女生要人工流產。

02:16:25 - 02:16:26
胎兒無辜嗎？

02:16:27 - 02:16:28
一樣是無辜的，對吧？

02:16:29 - 02:16:30
對啊，所以我就說。

02:16:30 - 02:16:35
在所有人工流產的情況，胎兒一定都是無辜的啦。

02:16:35 - 02:16:37
胎兒怎麼可能有錯，當然不可能啊。

02:16:38 - 02:16:43
所以很多保守派在反人工流產的時候都喜歡講，那胎兒是無辜的，你怎麼可以殺掉他？

02:16:43 - 02:16:44
這個論述沒有意義啦。

02:16:45 - 02:16:49
因為在這種所有的人工流產的情境，胎兒本來就是無辜的，知道嗎？

02:16:49 - 02:16:52
所以那並不是一個否定人工流產的理由。

02:16:53 - 02:16:53
來。

02:16:56 - 02:16:59
其中啊，你看喔，人工流產的事由第六款。

02:17:00 - 02:17:04
懷孕或生產將影響孕婦的心理健康或家庭生活。

02:17:05 - 02:17:08
有沒有感覺這一款超寬，對吧？

02:17:08 - 02:17:12
所以幾乎是隻要女生想人工流產，這一款幾乎就一定可以過吧。

02:17:13 - 02:17:15
所以我第一堂課才會說。

02:17:15 - 02:17:17
現行法雖然還有墮胎罪。

02:17:18 - 02:17:19
但是現行法的墮胎罪。

02:17:19 - 02:17:23
幾乎全部都被這一款架空了。

02:17:23 - 02:17:26
因為一般女生想人工流產一定是有一些原因嘛。

02:17:27 - 02:17:30
心理上沒有準備好，經濟上沒有準備好，現在不適合懷孕等等。

02:17:32 - 02:17:33
一定有這些原因。

02:17:33 - 02:17:39
所以依照這個第六款的事由呢,人工流產絕大多數都會被它阻卻違法。

02:17:39 - 02:17:41
所以墮胎罪幾乎是一個名存實亡的犯罪。

02:17:42 - 02:17:46
所以我們說,現行法之下,孕婦要人工流產,其實不難。

02:17:48 - 02:17:50
第六款事由幾乎都可以過。

02:17:51 - 02:17:59
當然啦,在臺灣的話,因為臺灣那種保守派的教會勢力沒有那麼強,所以在臺灣的話,比較少有這一種反對墮胎的勢力。

02:18:00 - 02:18:00
外國不是喔,像在美國,美國他們保守派還蠻強的啊

02:18:03 - 02:18:08
所以在美國的話,這個墮胎的爭議,還蠻敏感的

02:18:09 - 02:18:11
臺灣這個東西比較站不起來啦

02:18:11 - 02:18:14
因為臺灣比較不會有人那麼堅定的反墮胎

02:18:14 - 02:18:15
但是在美國會哦

02:18:16 - 02:18:22
你知道嗎,在美國,因為各國的政治局勢,還有各國值得爭議的問題不太一樣

02:18:24 - 02:18:26
臺灣的話就是真藍綠嘛

02:18:26 - 02:18:28
國家認同嘛,之類的,臺灣是真這個東西

02:18:29 - 02:18:31
美國不會有這個問題啊

02:18:32 - 02:18:37
美國應該不會有民主黨跟共和黨人在互吵說你是不是英國人

02:18:37 - 02:18:37
應該不會吧

02:18:37 - 02:18:44
在美國應該不會有人說，你的祖先從英國來的，你怎麼不承認自己是英國人的，你這個數典忘祖

02:18:44 - 02:18:45
美國不會嘛

02:18:45 - 02:18:46
美國吵別的嘛

02:18:46 - 02:18:52
美國吵什麼槍枝管制啊，這個性少數族群的權利啊，墮胎啊，就吵這個東西啊

02:18:53 - 02:18:59
你知道嗎，在美國，如果你搭飛機很無聊，問你旁邊的人：你對墮胎有什麼想法？

02:19:00 - 02:19:02
這是敏感的議題。

02:19:02 - 02:19:06
這就跟在臺灣說：你是臺灣人還是中國人？大概類似的感覺。

02:19:07 - 02:19:07
在美國啊。

02:19:09 - 02:19:11
保守派說墮胎等於殺人。

02:19:11 - 02:19:12
很可惡

02:19:12 - 02:19:13
自由派說還好

02:19:13 - 02:19:18
墮胎就胎兒就受精卵，然後就一堆細胞啊，那又不是人，殺掉會怎麼樣

02:19:18 - 02:19:19
自由派的想法是這樣子

02:19:20 - 02:19:21
雙方的立場針鋒相對

02:19:22 - 02:19:24
以前有一本書很有趣，只是有點舊

02:19:24 - 02:19:26
那本書叫蘋果橘子經濟學，十幾年前的書

02:19:28 - 02:19:29
那一本書是在講說

02:19:31 - 02:19:32
作者發現一個現象

02:19:33 - 02:19:33
說

02:19:34 - 02:19:37
1990年代的美國犯罪率突然下降

02:19:39 - 02:19:41
當時各界的學者都在問

02:19:41 - 02:19:42
對啊，為什麼？

02:19:43 - 02:19:45
為什麼90年代的犯罪率突然下降？

02:19:46 - 02:19:48
於是各界的學者提出各種不同的假說

02:19:49 - 02:19:50
有人說

02:19:50 - 02:19:51
因為社會福利變好

02:19:52 - 02:19:53
有些人說

02:19:53 - 02:19:54
因為警察增加

02:19:55 - 02:19:56
有些人說因為刑罰變重

02:19:56 - 02:19:57
等等，各界的學者

02:19:57 - 02:19:59
提出各種不同的意見

02:19:59 - 02:19:59
而

02:20:00 - 02:20:03
蘋果橘子經濟學的作者說呢，以上的理由通通不成立。

02:20:04 - 02:20:06
蘋果橘子經濟學的作者是說啊，

02:20:07 - 02:20:10
90年代的美國治安會變好，

02:20:10 - 02:20:11
理由只有一個，

02:20:11 - 02:20:14
因為70年代的墮胎大幅合法化。

02:20:15 - 02:20:16
你說關聯性在哪？

02:20:16 - 02:20:17
有啊，當然有關係啊。

02:20:17 - 02:20:18
你想喔,

02:20:19 - 02:20:21
在一個墮胎不合法的社會,

02:20:22 - 02:20:28
意外懷孕的女生因為缺乏合法的墮胎管道,她可能被迫只能把小孩生下來。

02:20:28 - 02:20:37
而這樣的女生,她原本想墮胎而法律不允許墮胎,她在心理上在經濟上根本就沒有準備好要當媽媽。

02:20:38 - 02:20:44
所以這樣的女生生下來的小孩,是不是很容易缺乏照顧,缺乏資源,長大走向犯罪之路。

02:20:45 - 02:20:46
可以想像，對吧？

02:20:47 - 02:20:48
所以相對的，

02:20:49 - 02:20:51
70年代墮胎大幅合法化，

02:20:52 - 02:20:59
是不是讓這些無法在有溫暖的環境下長大的小孩，提早在肚子裡就被墮胎殺掉了，

02:21:00 - 02:21:01
被墮掉了，對吧？

02:21:01 - 02:21:01
對啊,

02:21:01 - 02:21:06
所以那些潛在的犯罪者還沒有生下來，在肚子裡就先被殺掉了。

02:21:06 - 02:21:09
因此呢，20年後治安變好了。

02:21:09 - 02:21:10
他的論述是這樣。

02:21:10 - 02:21:11
你們想啊，

02:21:11 - 02:21:14
那個保守的基督教會的人聽到會多火大。

02:21:15 - 02:21:16
應該可以想像，對吧？

02:21:16 - 02:21:18
說什麼鼓勵殺人什麼的一定的嘛。

02:21:18 - 02:21:22
所以作者會提出他的論述，證明他的說理是成立的，我覺得很有趣。

02:21:22 - 02:21:23
這篇你們可以去看。

02:21:23 - 02:21:26
這本書很久了，十幾年了，圖書館應該都借得到。

02:21:26 - 02:21:27
我還蠻喜歡這本書的。

02:21:29 - 02:21:33
好，所以總之，現行法之下，員工流產它就是一個阻卻違法的事由。

02:21:33 - 02:21:36
那第六款呢，讓大多數人流產都合法。

02:21:37 - 02:21:41
就第六款來說，法律上會有一些限制，來第二點這邊。

02:21:43 - 02:21:44
現行法的限制是這樣。

02:21:45 - 02:21:50
優生保健法，如果要進行人工流產的話，有幾個限制。

02:21:51 - 02:21:53
第一個是24週以內。

02:21:53 - 02:21:54
第二個要成年。

02:21:55 - 02:21:56
第三個是沒有受監護輔助宣告。

02:21:57 - 02:21:58
第四個是單身。

02:21:58 - 02:22:00
來，這一些限制。

02:22:00 - 02:22:00
我大概講一下

02:22:00 - 02:22:00
王皇玉老師對他的評論。

02:22:03 - 02:22:05
第一個，24週內的限制。

02:22:06 - 02:22:09
這個一般比較不會有什麼質疑的聲音。

02:22:09 - 02:22:15
因為懷孕如果超過24週還要人工流產的話，第一個這個對孕婦自己是危險的。

02:22:16 - 02:22:20
那再來另外一方面，超過24週，那個胎兒已經逐漸有人形了。

02:22:20 - 02:22:22
那可能有一些人道的考量。

02:22:22 - 02:22:25
所以24週的限制，一般覺得還可以，還算合理。

02:22:26 - 02:22:29
再來，未成年人不能墮胎這個限制。

02:22:29 - 02:22:31
未成年人墮胎要經過法代的同意。

02:22:31 - 02:22:34
這個限制，王皇玉老師認為說立法上不合理。

02:22:35 - 02:22:36
對啊，這個限制其實有問題。

02:22:37 - 02:22:38
很多人說，為什麼？

02:22:38 - 02:22:39
對這個當然有問題啊。

02:22:40 - 02:22:41
我想大家都同意一件事。

02:22:42 - 02:22:46
未成年人如果懷孕了，她還把小孩生下來當媽媽。

02:22:47 - 02:22:48
這應該不是什麼好事吧。

02:22:49 - 02:22:50
自己都沒有準備好嘛。

02:22:50 - 02:22:52
自己還是個小孩嘛，對也沒有錯。

02:22:53 - 02:22:57
未成年人不適合懷孕當媽媽這件事，大家應該都有共識。

02:22:57 - 02:23:01
那為什麼我們反而要增加未成年人人工流產的法律門檻？

02:23:02 - 02:23:02
對吧？

02:23:02 - 02:23:05
既然她不適合當媽媽，不適合懷孕的話，那我們在法律上去刁難她人工流產。

02:23:09 - 02:23:10
要他的法定代理人同意才可以。

02:23:11 - 02:23:12
那你想結果是什麼？

02:23:14 - 02:23:15
未成年人意外懷孕。

02:23:15 - 02:23:17
是不是可能不敢跟法定代理人講？

02:23:18 - 02:23:19
那不敢講的話呢？

02:23:19 - 02:23:20
幾條路嘛。

02:23:20 - 02:23:22
要麼找密醫墮胎。

02:23:23 - 02:23:24
要麼自己去黑市買墮胎藥墮胎。

02:23:25 - 02:23:27
那是不是反而增加未成年人身體的危險？

02:23:28 - 02:23:28
是啊。

02:23:29 - 02:23:29
那再來。

02:23:30 - 02:23:33
有些未成年人呢,就不敢跟法代講。

02:23:33 - 02:23:35
最後就一直拖拖拖,拖到最後小孩生下來了。

02:23:36 - 02:23:37
這不是大家最不樂見的結果嗎？

02:23:38 - 02:23:38
是啊。

02:23:38 - 02:23:43
所以這一款是由表面上立法者想保護未成年人。

02:23:43 - 02:23:45
可是設下這個限制的結果，反而增加未成年人的風險。

02:23:48 - 02:23:50
所以學者會認為說這一款根本就不應該存在。

02:23:51 - 02:23:54
大家既然認為未成年人不適合當媽媽的話，

02:23:55 - 02:23:58
那為什麼反而是法律上增加她人工流產的限制？

02:23:58 - 02:23:59
這是問題。

02:24:00 - 02:24:02
最後最莫名其妙的是

02:24:02 - 02:24:05
有配偶者要用第六款人工流產的話

02:24:05 - 02:24:07
要經過他配偶同意，

02:24:08 - 02:24:10
這個真的很荒謬，我不知道該說什麼，真的超荒謬。

02:24:11 - 02:24:16
我之前在上面看到一篇貼文，去年吧，看到一篇貼文。

02:24:17 - 02:24:18
那個貼文大概是這樣說。

02:24:19 - 02:24:23
這個女生，她結婚之後啊，跟她老公對生育沒有什麼共識。

02:24:24 - 02:24:26
為什麼這樣會結婚，我也不太懂。

02:24:26 - 02:24:28
就這麼重要的事沒有共識還結婚，我也不太懂，好，這不管怎麼樣。

02:24:30 - 02:24:31
他們婚就結了嘛。

02:24:31 - 02:24:32
然後啊。

02:24:33 - 02:24:36
男生想要小孩，但女生不要。

02:24:36 - 02:24:39
然後女生就上去問說，那她該怎麼辦？

02:24:39 - 02:24:41
當時我就回他。

02:24:41 - 02:24:42
我跟他說啊。

02:24:42 - 02:24:48
因為我們優生保健法，現行法之下，那個惡法還存在。

02:24:49 - 02:24:53
已婚者要用第六款，是人工流產，要請配偶同意。

02:24:54 - 02:24:55
這個法還存在。

02:24:55 - 02:24:56
所以我就跟那個女生講。

02:24:57 - 02:25:02
在正式跟老公離婚前，拜託你，不要跟老公發生性關係。

02:25:02 - 02:25:03
真的啊。

02:25:04 - 02:25:04
你想啊。

02:25:05 - 02:25:11
單身的人，他只要已經成年了，他意外懷孕的，他要人工流產，沒有人有權力去阻擋他。

02:25:12 - 02:25:14
對吧，我們講我都看過嘛，對不對？

02:25:14 - 02:25:19
單身成年的女生，她懷孕了，她不想要小孩的話，人工流產是法律絕對保護她的權利。

02:25:20 - 02:25:21
沒有人有資格去擋她。

02:25:22 - 02:25:26
可是已婚的人要用第六款去人工流產，要經過她配偶同意。

02:25:27 - 02:25:30
我看到想說莫名其妙，這到底是誰的子宮啊？

02:25:30 - 02:25:31
吧。

02:25:31 - 02:25:32
可是這個惡法還在呀，所以我就跟那個女生講。

02:25:33 - 02:25:35
你不要跟你老公有性行為，不然發生什麼意外。

02:25:36 - 02:25:38
那個爛男人說他想要小孩。

02:25:39 - 02:25:41
他是不是有可能會制止他老婆墮胎？

02:25:41 - 02:25:42
對，有可能。

02:25:42 - 02:25:45
所以這種情況，如果他老婆還想人工流產。

02:25:46 - 02:25:46
那怎麼辦？

02:25:48 - 02:25:48
我找文書啊。

02:25:49 - 02:25:50
我找密醫啊，不然怎麼辦？

02:25:50 - 02:25:52
但這個有法律風險，也對自己的健康有風險。

02:25:52 - 02:25:55
所以才說，這種情況就不要再跟老公發生性關係。

02:25:55 - 02:25:56
所以很莫名啦。

02:25:57 - 02:25:59
到2025年的今天。

02:26:00 - 02:26:01
這個惡法依然存在。

02:26:02 - 02:26:05
太太要人工流產，竟然要經過先生的同意。

02:26:05 - 02:26:06
到底是誰的子宮啊？

02:26:07 - 02:26:11
有些人說，可是小孩的基因先生也有一半。

02:26:11 - 02:26:12
這不是理由啦。

02:26:13 - 02:26:14
太太的子宮欸。

02:26:14 - 02:26:17
對啊，如果男生真的那麼想當爸爸，

02:26:17 - 02:26:18
現在老婆不想，

02:26:19 - 02:26:22
那為什麼不是男生離婚，然後再去找另外一個女生？

02:26:23 - 02:26:26
為什麼是男生有權力逼著他老婆繼續懷孕就一定要當媽媽？

02:26:27 - 02:26:28
很有問題的法律。

02:26:28 - 02:26:30
應該沒有人支持他啦。

02:26:30 - 02:26:30
哦。

02:26:30 - 02:26:33
5年前就有人連署提案，要把他修掉。

02:26:34 - 02:26:36
可是直到現在這個法條都還活著。

02:26:36 - 02:26:38
我不知道這個法條是不是要修。

02:26:39 - 02:26:42
好，所以這個是很莫名的條文，我們就帶各位看到這邊。

02:26:43 - 02:26:45
來,接著往下,184頁。

02:26:46 - 02:26:48
我們接下來看到其他的主權法是有。

02:26:48 - 02:26:51
第五節,公務員一,上級命令的行為。

02:26:54 - 02:26:56
剛剛我們看的是依法令21條第一項,

02:26:56 - 02:27:00
再來是21條第二項,公務員一,上級命令。

02:27:00 - 02:27:00
好。

02:27:00 - 02:27:06
這個條文說，依所屬上級公務員的命令行為不法，但明知違法者，不在此限。

02:27:07 - 02:27:10
這個東西考試不常出現，我們大致上看一下就好。

02:27:10 - 02:27:11
第一個。

02:27:12 - 02:27:15
它的要件呢，所謂啊，具有拘束力的命令。

02:27:16 - 02:27:18
具有拘束命令的命令,

02:27:19 - 02:27:25
也就是這個命令，真的要在上下級公務員的事務範圍之內。

02:27:26 - 02:27:27
所以比如說，

02:27:28 - 02:27:35
拆除大隊的隊員，在接受隊長的建議之後，拆除了違建，OK，這可以職權違法。

02:27:37 - 02:27:40
但如果是上級的公務員叫下級，

02:27:40 - 02:27:41
去

02:27:41 - 02:27:43
比如說跟蹤別的老婆之類的,

02:27:43 - 02:27:45
這個當然不行,因為這個已經超過了命令的範圍。

02:27:46 - 02:27:47
好,這是第一個。

02:27:48 - 02:27:50
再來第二個,命令要具備法定的程序。

02:27:50 - 02:27:53
所以法定的這一合法性要件，書面的鑰匙啊什麼的都要符合。

02:27:55 - 02:27:59
那第三個，命令當然不能越過原本的授權範圍之內，這個是必然。

02:28:00 - 02:28:01
的，如果逾越的話，

02:28:01 - 02:28:02
那就不能阻卻違法。

02:28:02 - 02:28:03
最後第四點呢，

02:28:03 - 02:28:06
不能明知命令違法。

02:28:06 - 02:28:07
這個東西啊,

02:28:07 - 02:28:08
過去有一個爭議。

02:28:10 - 02:28:10
就是在講,

02:28:10 - 02:28:13
所謂的明知命令違法,

02:28:14 - 02:28:15
是指形式的部分，

02:28:15 - 02:28:17
還是也包括實質的部分。

02:28:18 - 02:28:20
就是你們學行政法都會學到，

02:28:20 - 02:28:22
一個行政行為的合法性，

02:28:22 - 02:28:25
有所謂形式合法性跟它的實質合法性。

02:28:25 - 02:28:26
包含這兩個部分。

02:28:26 - 02:28:26
好，

02:28:26 - 02:28:27
這個問題是這樣。

02:28:28 - 02:28:28
學者是說啊，

02:28:28 - 02:28:32
因為公務員上下的這種行政倫理的關係，

02:28:32 - 02:28:38
你不可能要下級的公務員去審查上級公務員的命令實質上合不合法,

02:28:38 - 02:28:39
不可能。

02:28:40 - 02:28:40
所以學者會說呢,

02:28:40 - 02:28:42
這裡所謂的明知,

02:28:42 - 02:28:45
應該僅限於明知這個命令,

02:28:45 - 02:28:48
形式上違法。

02:28:49 - 02:28:51
因為實質的部分你不可能要下級去審上級嘛，

02:28:51 - 02:28:51
對不對？

02:28:51 - 02:28:52
這個違反行政倫理。

02:28:54 - 02:28:55
所以學者認為說呢，

02:28:55 - 02:28:59
只有形式合法性的部分才是明知的對象。

02:28:59 - 02:29:16
可是實務

02:29:16 - 02:29:41
沒有在管喔。

02:29:41 - 02:29:43
實務覺得說不管形式或實質,

02:29:43 - 02:29:46
只要明知命令違法,

02:29:46 - 02:29:48
就不能阻卻違法。

02:29:48 - 02:29:50
有這樣的說法，

02:29:50 - 02:29:51
所以這是一個以前的爭議。

02:29:52 - 02:29:53
實務說，

02:29:53 - 02:29:53
只要知道，

02:29:53 - 02:29:55
不管是形式或實質，

02:29:55 - 02:29:57
通通都不能阻卻違法。

02:29:58 - 02:29:58
好,

02:29:58 - 02:29:59
所以這個簡單的東西,

02:29:59 - 02:30:00
我們就大概帶過。

02:30:00 - 02:30:01
或者比如說

02:30:02 - 02:30:04
那個醫師為病患進行醫療行為

02:30:05 - 02:30:09
醫療行為的話,你除了可以講業務上正當行為

02:30:09 - 02:30:12
你是不是可以講被害人同意的超法規阻卻事由

02:30:13 - 02:30:15
或者可以講,比如說緊急避難,你也可以過,對不對

02:30:16 - 02:30:17
所以跟你說

02:30:17 - 02:30:22
真的會只能適用業務上正當行為的狀況其實不多

02:30:23 - 02:30:23
真的不多

02:30:24 - 02:30:27
就只能適用業務上正當行為的情況

02:30:27 - 02:30:29
大概我能想到的

02:30:30 - 02:30:31
就記者啦

02:30:31 - 02:30:33
記者的採訪行為啦

02:30:33 - 02:30:34
我覺得有可能啦

02:30:35 - 02:30:36
我以前舉過例證

02:30:37 - 02:30:39
記者為了揭發黑心的食品工廠

02:30:40 - 02:30:43
所以記者喬裝成員工去應徵

02:30:43 - 02:30:46
應徵之後，他面試上，他進去臥底

02:30:46 - 02:30:52
臥底的期間，這個記者用密錄器錄下了黑心食品工廠，他們每天運作的情況

02:30:53 - 02:30:55
那這種的話，你找不到別的阻卻法是有吧

02:30:55 - 02:30:57
你只能用業務上正當行為，知道嗎

02:30:57 - 02:30:58
所以我說

02:30:58 - 02:31:03
真正會只有業務上正當行為可以用，而沒有別種可以適用的情況

02:31:03 - 02:31:04
說真的不多

02:31:04 - 02:31:11
因為很多這種業務上正當行為，比如說公務員執法，或者比如說這個

02:31:11 - 02:31:11
醫療行為

02:31:11 - 02:31:14
其實都可以有機會走二一啊，走二四啊，或什麼的

02:31:14 - 02:31:16
真的會用這種運用這個阻卻法的情況是不多的

02:31:17 - 02:31:18
好，我們翻過來

02:31:21 - 02:31:22
我們來看86頁

02:31:22 - 02:31:23
要件

02:31:25 - 02:31:27
那個業務上的正當行為

02:31:27 - 02:31:29
首先第一個要講的是要件的部分

02:31:29 - 02:31:32
我們採的叫做事實業務說，什麼意思

02:31:33 - 02:31:38
因為我們條文寫的是業務上的正當行為

02:31:39 - 02:31:41
各位，中文的問題

02:31:42 - 02:31:44
業務上的正當行為，所以重點是什麼？正當

02:31:46 - 02:31:47
是行為正當

02:31:48 - 02:31:50
而不是業務正當，知道嗎

02:31:50 - 02:31:51
重點是行為正當

02:31:52 - 02:31:57
所以如果業務本身不正當，不管喔，重點是行為正當

02:31:58 - 02:31:59
好，比如說

02:31:59 - 02:32:00
各位這我看牙醫

02:32:00 - 02:32:01
的經驗。

02:32:02 - 02:32:03
好，各位我剛看牙醫的經驗。

02:32:04 - 02:32:04
那

02:32:06 - 02:32:07
舉個例子來講。

02:32:08 - 02:32:10
當你去看牙醫的時候啊。

02:32:11 - 02:32:13
那個，比如說你去找牙醫。

02:32:14 - 02:32:16
正常的牙醫。

02:32:16 - 02:32:19
他會寫某某牙醫或某某牙科。

02:32:20 - 02:32:20
可是你們知道嗎？

02:32:21 - 02:32:23
早期啊，現在應該很少。

02:32:24 - 02:32:26
早期有一種人，他們不是牙醫。

02:32:27 - 02:32:29
但他們會假裝自己是。

02:32:30 - 02:32:32
然後在做牙醫的工作，那個叫做齒模師。

02:32:33 - 02:32:36
齒模師照理來說當然不能做這種醫療行為啊，不行啊。

02:32:36 - 02:32:38
可是我老家附近有啊。

02:32:38 - 02:32:40
他就叫什麼美齒啊。

02:32:40 - 02:32:43
那個美齒啊，然後招牌就畫了一口牙，但他又不是牙醫啊。

02:32:45 - 02:32:46
可是你想喔。

02:32:47 - 02:32:49
這種人會不會做一些基本的治療。

02:32:49 - 02:32:50
搞不好他們會，對不對。

02:32:50 - 02:32:52
說不定技術還比剛出來的牙醫好，有可能嘛。

02:32:53 - 02:32:58
這種無照的密醫，幫病患做手術、做治療的行為。

02:32:59 - 02:33:02
只要他的處置是符合醫療常規的。

02:33:03 - 02:33:04
那就可以阻卻違法喔，知道嗎？

02:33:05 - 02:33:07
至於他無照行醫，那個是其他法律的問題，知道嗎？

02:33:08 - 02:33:10
不影響這個阻卻法適用。

02:33:10 - 02:33:11
好。

02:33:11 - 02:33:11
所以我們這邊講說啊。

02:33:13 - 02:33:14
這個業務呢，指的是事實業務。

02:33:15 - 02:33:17
再來這邊講，正當行為。

02:33:18 - 02:33:20
這個行為本身要正當，所以這個行為正當是要怎麼樣呢？

02:33:22 - 02:33:23
最低的限度。

02:33:24 - 02:33:26
不能抵觸其他法領域的規定。

02:33:28 - 02:33:29
密醫為病患拔牙。

02:33:30 - 02:33:30
好,OK。

02:33:31 - 02:33:34
因為沒有其他的法律去禁止這個拔牙的行為本身,所以這個行為是正當的。

02:33:35 - 02:33:35
再來喔。

02:33:36 - 02:33:38
警察訊求被告。

02:33:39 - 02:33:42
警察訊求被告可不可以講，義務上當行為。

02:33:42 - 02:33:44
警員講學長就教我這樣做啊。

02:33:45 - 02:33:46
我們老學長都這樣幹的啊。

02:33:47 - 02:33:48
所以正當,不行喔。

02:33:48 - 02:33:50
因為行訴就禁止這個行為了,知道嗎?

02:33:50 - 02:33:55
所以這邊我們講,必須這個行為呢,不能跟其他法領域相抵觸喔。

02:33:55 - 02:33:56
好。

02:33:56 - 02:33:59
至於醫療行為的話，醫療行為本身說。

02:34:00 - 02:34:04
原則上要得到患者或家屬的事前同意。

02:34:05 - 02:34:07
要得到事前同意哦，這才可以阻卻違法。

02:34:08 - 02:34:13
如果沒有得到事前同意的話，這個頂多啦，推測的承諾。

02:34:13 - 02:34:15
好，這個頂多是推測的承諾。

02:34:15 - 02:34:19
那有一種情況第二點，違反病患意識的意思，這個叫專斷醫療啦。

02:34:21 - 02:34:24
這種專斷醫療，通常他不能阻卻違法。

02:34:24 - 02:34:29
因為醫療行為不管怎麼樣，你要經過人家同意嘛，對方有病就不想醫，你不能去強迫人家嘛。

02:34:29 - 02:34:32
所以這種專斷醫療呢，原則上不能阻卻違法。

02:34:32 - 02:34:34
然後啊，我們翻過來看一個東西。

02:34:42 - 02:34:43
168頁。

02:34:44 - 02:34:47
這個東西，國考曾經有出現過，但次數不多。

02:34:47 - 02:34:50
我跟你們講，醫療刑法通常考在研究所。

02:34:51 - 02:34:52
真的，考在研究所。

02:34:52 - 02:34:57
因為像國內有幾位老師對醫療刑法可能比較有興趣的，王皇玉老師啊，曾淑偉老師啊，幾位。

02:34:58 - 02:34:59
這比較容易考在研究所。

02:34:59 - 02:35:01
國考偶爾出現，我們還是當嘗試聽一聽啦。

02:35:03 - 02:35:08
醫療行為會不會該當傷害罪？

02:35:09 - 02:35:10
對啊，醫療行為怎麼評價？

02:35:10 - 02:35:11
來，這邊兩種不同的說法。

02:35:12 - 02:35:15
有一種傳統的說法叫醫療行為傷害說。

02:35:16 - 02:35:17
什麼意思？

02:35:18 - 02:35:20
好，比如說講一個大家都有的經驗喔，拔智齒。

02:35:21 - 02:35:22
因為大部分人都拔過嘛，對不對？拔智齒。

02:35:24 - 02:35:27
那個你智齒發炎了，你智齒長歪了。

02:35:29 - 02:35:32
造成你的牙齦經常發炎。

02:35:32 - 02:35:36
所以你去牙科診所，要醫師幫你把那顆爛掉的智齒拔掉。

02:35:36 - 02:35:37
來，醫師的行為怎麼論罪？

02:35:38 - 02:35:38
兩種說法。

02:35:39 - 02:35:44
有人說醫師把你的智齒拔掉，讓你少一顆牙，讓你出血，他該當傷害罪。

02:35:45 - 02:35:48
只是呢，這裡有阻卻違法事由，義務上正當行為啦。

02:35:49 - 02:35:50
被害人承諾啊，什麼的。

02:35:50 - 02:35:52
有阻卻違法事由，醫師不曉得你犯罪。

02:35:53 - 02:35:55
這是一種說法，叫醫療行為傷害說。

02:35:55 - 02:35:59
所以這種說法會認為一個成功的醫療行為

02:36:00 - 02:36:02
他是該當傷害罪的

02:36:02 - 02:36:03
只是可以阻卻違法

02:36:03 - 02:36:03
知道嗎?

02:36:04 - 02:36:04
這叫傷害說。

02:36:05 - 02:36:08
反過來說，現在有另外一種說法越來越成為主流，

02:36:08 - 02:36:10
另外一種說法叫做非傷害說。

02:36:11 - 02:36:13
非傷害說跟你講，

02:36:13 - 02:36:16
醫療行為根本不該當傷害罪，

02:36:16 - 02:36:17
當然有前提啦。

02:36:18 - 02:36:21
你看醫療行為幾個要件，第一個要出於醫療的目的。

02:36:22 - 02:36:23
第二個，要告知後同意。

02:36:24 - 02:36:26
第三個，要符合醫療常規。

02:36:27 - 02:36:28
還有第四個，

02:36:28 - 02:36:33
要以緩解疼痛、緩解疾病為目的。

02:36:33 - 02:36:34
這個當然要符合啦。

02:36:34 - 02:36:42
另外一種說法是說，能符合醫療常規等等要件的醫療行為，根本不該當傷害罪。

02:36:43 - 02:36:43
為什麼？

02:36:44 - 02:36:47
這個說法，他會跟你講說醫療行為你要看整體，

02:36:48 - 02:36:50
你不能糾結那一刀一針一線。

02:36:50 - 02:36:51
怎麼說呢？

02:36:51 - 02:36:53
你想喔，你智齒長歪了，

02:36:54 - 02:36:55
它壓迫到你的臼齒，

02:36:56 - 02:36:59
它造成你的牙齦三不五時就發炎。

02:36:59 - 02:37:17
你在這種情況之下

02:37:17 - 02:37:29
去跟醫生說

02:37:29 - 02:37:42
你要拔智齒。

02:37:43 - 02:37:43
所以各位,

02:37:44 - 02:37:51
原本你的智齒長歪，你進到牙科診所，當時你整口牙是處於怎麼樣呢？處於不健康的狀態。

02:37:52 - 02:37:55
那麼醫師把你長歪的智齒拔掉之後，

02:37:55 - 02:37:58
雖然你少了一顆牙，雖然過程當中有出血，

02:37:59 - 02:38:00
但是其實就醫療行為的整體來講，

02:38:00 - 02:38:01
等一下我下午再來說。

02:38:02 - 02:38:05
這應該是109的考題吧，看一下。

02:38:11 - 02:38:12
那個12頁第27題。

02:38:13 - 02:38:15
這一題裡面中午休息時間來看一下。

02:38:15 - 02:38:16
12頁27題。

02:38:16 - 02:38:18
我們兩點上課再來，講這一題。

02:38:19 - 02:38:21
這一題就近年來跟醫療刑法有關，就這一題而已。

02:38:21 - 02:38:22
我們看一下。

02:38:22 - 02:38:23
好，我們先中場休息一個小時，等一下再說這一題。